

제16장

소의 제기

-
- 제1절 총 설 2
제2절 소장의 기재사항 및 첨부서류 4
제3절 소장의 심사 33
제4절 소장부분의 송달 57
제5절 소송요건의 심사 69

제1절 총 설

1. 소의 의의

민사소송사건의 제1심 절차는 소의 제기에 의하여 개시된다. 소는 원고가 피고를 상대로 법원에 특정한 청구(소송물)에 관한 판결을 구하는 소송행위이다. 소는 심판의 개시라는 효과를 목적으로 하는 법원에 대한 소송행위이고 직접 피고에 대하여 하는 사법상의 의사표시가 아니다. 소의 제기가 시효 중단(민법 168조) 등 사법상의 효과를 수반하는 때가 있지만 이는 법이 인정한 종된 효과이지 소제기 본래의 효과는 아니다.

소는 법원에 대하여 판결을 요구하는 행위이므로 판결 이외의 것을 요구하는 행위, 예컨대 조정 신청(민조 2조), 지급명령 신청(민소 462조), 경매 신청(민집 80조, 264조), 가압류·가처분 신청(276조, 300조)은 소가 아니다. 소는 특정한 청구에 관한 심판을 구하는 행위이고, 여기서 ‘청구’란 원고가 소에 의하여 그 당부에 관한 심판을 구하는 구체적인 이익 주장을 지칭하는 것으로서 원칙적으로 특정한 권리 또는 법률관계의 존부에 관한 주장이어야 한다.

소는 청구의 성질과 내용을 기준으로 일반적으로 이행의 소, 확인의 소, 형성의 소 세 가지로 분류된다. 위 세 가지 소의 형태, 그 당사자적격과 판결의 효력에 관하여는 제9장(당사자) 제4절 참조.

2. 소제기의 방식

민사사건의 소송절차는 소의 제기에 의하여 개시되는데, 소제기의 방식은 아래와 같이 세 가지 유형으로 나누어 볼 수 있다.

첫째로, 소의 제기는 소장을 작성하여 법원에 제출하는 방법에 의하는 것이 원칙이다(민소 248조 1항). 독립의 소뿐만 아니라 소송중의 소의 경우에도

마찬가지로 소장에 준하는 서면(전자문서 포함)의 제출이 원칙적으로 필요하다.

둘째로, 소액사건에 관하여는 간단하고 편리한 방법에 의하여 소를 제기할 수 있는 특례가 마련되어 있다. 당사자가 법원에 출석하여 구술에 의하여 소를 제기하거나(소액 4조) 또는 쌍방이 임의 출석하여 변론함으로써 소를 제기할 수 있고(5조), 법원에 비치되어 있는 사건 유형별 소장 양식을 이용하여 직접 소장을 작성하여 소를 제기할 수도 있다.

셋째로, 지급명령·제소전화해·조정 등 다른 절차로부터 소송절차로 이행되는 경우에는 소가 제기된 것으로 간주된다.

3. 소제기로 간주되는 경우

지급명령사건에서, ① 채권자가 법원으로부터 채무자의 주소를 보정하라는 명령을 받고 소제기신청을 한 경우(민소 472조 1항, 466조 1항), ② 지급명령을 공시송달에 의하지 아니하고는 송달할 수 없거나(다만 은행법에 의한 은행 등이 그 업무 또는 사업으로 취득하여 행사하는 대여금, 구상금, 보증금 및 그 양수금 채권에 대하여 지급명령을 신청하는 경우에는 공시송달에 의하여 송달해야 하는 사건에 대하여도 지급명령을 발령할 수 있다. 소촉 20조의2) 외국으로 송달하여야 할 때에 법원이 사건을 소송절차에 부치는 결정을 한 경우(민소 472조 1항, 466조 2항), ③ 채무자가 지급명령에 대하여 적법한 이의신청을 한 경우(이의신청된 청구목적의 값에 한한다) 지급명령을 신청한 때에 각각 소가 제기된 것으로 본다(472조 1항, 2항).

제소전화해가 성립되지 아니한 때에는 당사자는 소제기신청을 할 수 있고(민소 388조 1항), 적법한 소제기신청이 있으면 당초 화해신청을 한 때에 소가 제기된 것으로 본다(2항).

조정사건에서 민사조정법 26조에 따라 조정을 하지 아니하기로 하는 결정이 있거나, 27조에 따라 조정이 성립되지 아니한 것으로 사건이 종결된 경우 또는 30조에 따른 조정을 갈음하는 결정이 이의신청에 의하여 효력을 상

실한 경우에는 조정신청을 한 때에 소가 제기된 것으로 본다(민조 36조 1항).

형사사건에서 피해자의 배상명령신청도 민사소송에서의 소제기와 동일한 효력이 있으며, 인지를 붙일 필요가 없다(소촉 26조 1항, 8항. 다만 배상명령신청으로부터 소송절차로 이행되지는 아니하고 배상신청이 각하되거나 일부만 인용되더라도 불복을 신청할 수 없다. 소촉 32조 4항).

제2절 소장의 기재사항 및 첨부서류

1. 총 설

소장은 소송서류의 하나이므로 간결한 문장으로 분명하게 작성하여야 한다(민소규 4조 1항). 소장은 특별한 사정이 없으면 A4(가로 210mm×세로 297mm) 크기의 용지를 세워서 적고, 위로부터 45mm, 왼쪽 및 오른쪽으로부터 각각 20mm, 아래로부터 30mm(장수 표시 제외)의 여백을 두며, 글자크기는 12포인트(가로 4.2mm×세로 4.2mm) 이상으로 하고, 줄 간격은 200% 또는 1.5줄 이상으로 한다(2항). 다만 도면·통계표·계산서 등 특별한 사유가 있는 때에는 다른 규격의 용지를 쓸 수도 있다.

소장은 이를 지참하여 법원에 직접 또는 우송의 방법으로 제출할 수 있고, 법원 전자정보처리시스템을 이용하여 전자문서로 제출할 수 있다(민전 5조 1항). 제출된 소장의 접수사무는 접수담당자로 지정된 법원사무관등(사무과, 민사과 또는 종합민원실 소속)이 담당하게 된다. 접수사무에 관한 구체적인 설명은 제6장(접수사무) 참조.

소장에 기재할 사항은 법규에 의하여 반드시 기재하여야 하는 ‘필수적 기재사항’과 기재할 경우 준비서면으로서의 효력을 갖는 ‘임의적 기재사항’ 및 그 밖에 증거방법의 표시 등 편의상 관계적으로 기재하는 사항이 있다.

소장의 맨 끝에는 당사자 또는 대리인이 기명날인 또는 서명한다(민소

249조 2항, 274조 1항). 간인은 필요 없으나, 간인이 없는 때에는 문서 전체에 쪽 번호를 적도록 유도하는 것이 좋다.

2. 소장의 필수적 기재사항

가. 총 설

민사소송은 원고와 피고 사이에 다툼이 생겨 원고의 권리주장의 당부를 심판하는 것을 목적으로 하기 때문에 소장에 소송의 주체인 당사자와 심판의 대상인 청구를 특정하여야 한다. 민사소송법은 소장에 필수적으로 기재하여야 할 사항으로 당사자·법정대리인·청구취지 및 청구원인 등 네 가지를 들고 있다(민소 249조 1항). 그리고 당사자와 법정대리인의 주소를 적어야 하며(255조 1항, 민소규 2조 1항 2호), 소송대리인이 있는 때에는 그의 성명과 주소도 적어야 한다(민소 249조 2항, 274조 1항 2호).

나. 당사자

(1) 당사자의 표시

소장에는 원고 및 피고가 누구인가를 다른 사람과 구별할 수 있을 정도로 표시하여야 한다. 어떤 당사자 사이에 소송절차가 개시되었는가를 구체적으로 특정하여 판결의 기판력이 미치는 주관적 범위(민소 218조)를 명확히 할 필요가 있기 때문이다.

당사자표시의 방법은 원고·피고 등 당사자의 지위를 기재한 다음, 자연인의 경우에는 성명과 주소를, 법인 또는 법인이 아닌 사단·재단(민소 52조)의 경우에는 명칭(회사의 경우에는 상호)과 주된 사무소(회사의 경우에는 본점)의 소재지를 기재하는 것이 보통이다.

그 밖에 당사자의 표시에서 주의할 점과 당사자의 확정, 당사자능력과 소송능력, 당사자적격과 제3자의 소송담당, 당사자의 변경과 피고의 경정 등에 관한 자세한 설명은 제9장(당사자) 참조.

(2) 실무상 통용되는 당사자의 호칭

① 통상의 소: 원고 / 피고

② 반소: 원고(반소피고) / 피고(반소원고)

③ 민사소송법 70조: 예비적·선택적 공동소송의 경우에는 모든 공동소송인에 관한 청구에 대하여 판단하여야 하고 공동소송인 중 일부만 상소한 경우 상소하지 아니한 당사자에 대한 부분도 상소심으로 이심되므로, 예컨대 피고가 복수인 예비적 공동소송의 경우에는 ‘주위적 피고 ○○○ / 예비적 피고 ○○○’로, 선택적 피고가 있는 경우에는 ‘선택적 피고 1. ○○○ / 2. ○○○’로 표시한다.

④ 참 가

- 민사소송법 71조: 보조참가인
- 민사소송법 78조: 공동소송적 보조참가인
- 민사소송법 79조: 독립당사자참가인 또는 당사자참가인
- 민사소송법 81조: 승계참가인 / 원고 ○○○ 승계참가인(원고들 중 1인 승계)
- 민사소송법 82조: 승계인수인(실무상 ‘인수참가인’이라고도 한다)
승계참가 및 승계인수(실무상 ‘인수참가’라고도 한다)의 경우 피승계인이 민사소송법 80조에 의하여 소송에서 탈퇴하였다고 하더라도 피승계인을 여전히 기재하되, ‘원고(탈퇴)’의 방식으로 괄호 안에 탈퇴하였다는 표시를 병기한다.
- 민사소송법 83조: 공동소송참가인

⑤ 소송수계

- 사망의 경우: 원고 망 ○○○의 소송수계인 / 1. ○○○ / 2. ○○○
- 합병의 경우: 원고 합병된 주식회사 ○○○의 소송수계인 주식회사 ○○○
- 회생의 경우: 원고 회생채무자 주식회사 ○○○의 소송수계인 (법률상)관리인 ○○○

- 파산의 경우: 원고 파산채무자 이을수의 소송수계인 파산관재인 김갑동
- 파산관재인 변경의 경우: 원고 파산채무자 이을수의 파산관재인 김갑동의 소송수계인 파산채무자 이을수의 파산관재인 박병서(회생의 경우도 같다)
- 개인회생의 경우: 원고 주식회사 ○○○의 소송수계인 개인회생채무자 ○○○(사해행위취소소송이 부인소송으로 전환 시)

⑥ 항소심

- 통상의 경우: 원고, 항소인 / 피고, 피항소인
- 보조참가인이 항소한 경우: 원고 / 보조참가인, 항소인 / 피고, 피항소인
- 양쪽 당사자 항소의 경우: 원고, 항소인 겸 피항소인 / 피고, 피항소인 겸 항소인
- 반소가 있는 경우: 원고(반소피고), 피항소인 / 피고(반소원고), 항소인
- 부대항소가 있는 경우: 원고, 피항소인 겸 부대항소인 / 피고, 항소인 겸 부대피항소인
- 특수한 경우: 독립당사자참가인 또는 예비적 피고가 있는 제1심판결에 대하여 참가인이나 예비적 피고가 항소를 제기하지 않은 경우 및 참가인이나 예비적 피고에 대해 항소가 제기되지 않은 경우에는, 합일확정의 필요상 소의 전부가 항소심에 이심되기는 하지만 그러한 참가인이나 예비적 피고는 항소인이나 피항소인은 아니므로 항소심에서의 지위를 병기하지 않는다.

⑦ 상고심: 원고, 상고인 / 피고, 피상고인

⑧ 재심

- 제1심판결에 대한 재심: 원고(재심피고) / 피고(재심원고)
- 항소심판결에 대한 재심: 원고(재심피고), 항소인 / 피고(재심원고), 피항소인
- 반소가 있는 항소심판결에 대한 재심: 원고(반소피고, 재심피고), 항소인 / 피고(반소원고, 재심원고), 피항소인

⑨ 항고사건: 항고인, 재항고인, 특별항고인 / 상대방

다만 소송구조신청과 같이 상대방의 관념을 상정할 수 없어 상대방을 기재할 필요가 없는 경우도 있다.

⑩ 지급명령사건: 채권자 / 채무자

다만 채권자의 소제기신청이나 채무자의 이의신청 또는 법원의 소송절차에 부치는 결정에 의해 소송으로 이행된 때에는(민소 472조), 그 호칭이 ‘원고 / 피고’로 변한다.

⑪ 공시최고사건: 신청인

⑫ 제소전화해사건: 신청인 / 상대방

다만 당사자의 소제기신청에 의해 소송으로 이행된 때에는(민소 388조), 그 호칭이 ‘원고 / 피고’로 변한다.

⑬ 강제집행사건, 담보권 실행 등을 위한 경매사건: 채권자, 채무자, 소유자, 제3채무자(채권에 대한 집행사건에서 집행대상채권의 채무자를 가리킴) 등

⑭ 가압류·가처분사건: 채권자 / 채무자

한편 가압류·가처분에 대한 이의사건(민집 283조)에서는 이의신청에 관한 호칭(이의신청인 등)을 따로 사용하지 않고 당초의 호칭을 그대로 사용하고, 반면 가압류·가처분에 대한 취소사건(287조 3항, 288조, 301조, 307조)에서는 당초 보전처분에서의 기재 순서와는 정반대로 취소신청을 한 채무자를 신청인, 상대방인 채권자를 피신청인이라 부르게 된다.

⑮ 그 밖에 본안사건에 부수하는 각종 신청사건

소송비용액 확정, 소송구조, 판결경정, 기피, 이송, 증거보전, 특별대리인 선임 등 본안사건에 부수하는 각종 신청사건에는 ‘신청인 / 피신청인’의 호칭을 사용한다. 이때 괄호 속에 본안사건의 호칭을 병기할 필요는 없다.

⑯ 각종 조정사건

조정신청에 따라 조정에 회부된 경우에는 ‘신청인 / 피신청인’으로 하고 조정에 직권회부된 경우에는 ‘원고 / 피고’ 명칭을 그대로 쓴다.

(3) 제3자의 소송담당 자격을 표시하는 경우**① 선정당사자(민소 53조)**

원고(선정당사자) / 원고 겸 선정당사자 김갑동

이 경우에는 소장의 맨 끝에 선정자들의 주소, 성명을 기재한 선정자명단을 작성 첨부한다. 그와 별도로 선정당사자를 포함한 선정자 전원이 날인한 당사자선정서를 법원에 제출하고, 판결서에도 선정당사자가 포함된 선정자명단을 작성하여 별지로 첨부하는 것이 일반적이다. 판례는 선정자명단에 선정당사자인 원고를 선정자로 표시하는 것에 관하여, “선정당사자 자신도 공동의 이해관계를 가진 사람으로서 선정행위를 하였다면, 선정행위를 하였다는 의미에서 선정자로 표기하는 것이 허용되지 않는다고 할 수 없으므로, 그 선정당사자를 선정자로 표기하는 것이 위법하다고 볼 수 없다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결).”라고 하였다. 한편 선정이 소송계속 후에 된 때에는 피선정자 이외의 선정자는 당연히 소송에서 탈퇴한다(민소 53조 2항).

② 파산관재인(채무자회생 359조)

원고 파산채무자 이을수의 파산관재인 김갑동

원고 파산채무자 주식회사 ○○저축은행의 파산관재인 예금보험공사

파산관재인이 2인 이상 선임된 경우 공동의 파산관재인 상호 간에는 필수적 공동소송의 관계에 있으므로 ‘원고 파산채무자 이을수의 파산관재인 / 1. 김갑동 / 2. 박병서’와 같이 표시하고, 주문이나 이유에서도 ‘원고들’로 표현한다. 다만 법원이 복수의 파산관재인 중 한 사람에게 소송수행의 직무분장을 허가한 경우(채무자회생 360조 1항 후문)에는 그 파산관재인이 단독으로 대표자가 될 수 있다.

③ 회생채무자의 관리인(채무자회생 78조)

원고 회생채무자 ○○○ 주식회사의 (법률상)관리인 김갑동

원고 회생채무자 주식회사 ○○○의 관리인 주식회사 □□□

이와 달리, ‘피고 채무자 주식회사 화창물산’이라 표기하고 그 주소를 쓴 다음에 ‘관리인 김상표’라고 기재하는 방식은 피고가 채무자 주식회사 화창물산이고 그 소송수행자가 관리인 김상표라는 뜻의 기재로 보게 되어 당사자적격을 그르치게 되므로(대법원 1985. 5. 28. 선고 84다카2285 판결 참조), 회생채무자의 재산에 관한 소에서 당사자표시는 특히 주의를 요한다.

④ 유언집행자(민법 1101조)

원고 망 이을수의 유언집행자 김갑동

⑤ 상속인의 존부가 불분명한 경우 법원이 선임한 상속재산관리인(민법 1053조)

피고 망 이을수의 상속재산관리인 김갑동

⑥ 피성년후견인의 친생부인의 소에서의 성년후견인(민법 848조 1항)

청구인 피성년후견인 이을수의 성년후견인 김갑동

⑦ 해난구조료청구에서의 선장(상법 894조 2항)

피고 선장 김갑동

다. 법정대리인 및 대표자

(1) 총 설

당사자가 미성년자·피성년후견인 등 소송무능력자인 때에는 친권자 또는 미성년후견인·성년후견인 등 법정대리인을, 법인·국가·지방자치단체인 때에는 대표자를, 민사소송법 52조의 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 대표자나 관리인을 각각 기재하여야 한다. 민사소송법 249조 1항의 소장 필수적 기재사항에는 대표자에 관한 규정이 없지만 법인이나 법인 아닌 사단·재단의 대표자 또는 관리인은 법정대리인과 같이 취급되므로(민소 64조), 소장에 대표자 또는 관리인을 기재하여야 한다.

회사에 공동대표의 정함이 있을 때(상법 208조, 389조 2항)에는 공동대표자 전원을 기재하여야 하나, 그렇지 않을 때에는 현실적으로 소송을 수행할 1인을 기재하면 된다. 주식회사의 이사가 회사에 대하여 또는 회사가 이사에 대하

여 소를 제기하는 경우에 회사를 대표할 권한이 있는 자는 감사이다(394조).

국가소송의 법률상 대표자는 법무부장관이고(국당 2조), 지방자치단체는 독립된 법인격을 가지므로 그 장이 대표자이다(지방자치법 3조 1항, 114조). 다만 지방자치단체의 교육·학예에 관한 사무로 인한 소송에 대하여는 특별시·광역시 및 도의 교육감이 그 대표자가 된다(지방자치법 135조, 지방교육자치에 관한 법률 18조 2항).

(2) 법정대리인 및 대표자의 표시 방식

법정대리인이나 대표자 등의 기재방식은 당사자의 표시 아래에 소송법상 및 실체법상의 대리 또는 대표자격을 표시하고 이름과 함께 그 주소를 기재한다.

다만 법정대리인의 주소를 기재하는 것은 당사자가 소송무능력자인 경우에 그에 대한 송달을 위한 것이므로, 그 주소가 본인의 주소와 같을 때나 소송대리인으로 변호사가 선임되어 있는 때에는 따로 기재하지 않는다. 법정대리인의 표시는 당사자의 특정을 위한 것이라기보다는 소송이 소송수행권이 있는 대리인에 의하여 적법하게 이루어짐을 명백하게 나타내고 송달을 용이하게 하기 위한 것이다.

법인이 당사자인 경우 송달받을 사람은 법인의 대표자이고 그 대표자의 주소지로 송달하는 것이 원칙이므로(민소 183조 1항, 송달예규 8조 1항, 대법원 2003. 4. 25. 선고 2000다60197 판결), 대표자의 주소지를 기재한다. 다만 법인의 주소지(본점 소재지)도 대표이사의 영업소로서 적법한 송달장소가 되므로(민소 64조, 183조 1항 단서) 법인의 주소지도 함께 기재하는 것이 바람직하다. 실무상으로는 오히려 법인의 주소지만 기재하는 것이 보통이고 대표자의 주소지를 기재할 경우에도 이를 '송달장소'로서 기재하는 것이 관행이다.

(3) 법정대리인 및 대표자 표시의 정정

법정대리권, 대표권 또는 소송행위에 필요한 권한의 수여에 흠이 있는 경우에는 그 흠을 보정할 수 없음이 명백한 때가 아닌 한 법원은 기간을 정하여 이를 보정하도록 명하여야 한다(민소 64조, 59조 전단). 따라서 법정대리

권 혹은 대표권에 관한 사항을 보정하거나 그에 따라 법정대리인 혹은 대표자의 표시를 정정하여 보충·변경하는 것은 소송계속 후 사실심 변론 종결 시까지는 언제라도 가능하다(대법원 2024. 4. 12. 선고 2023다313241 판결, 대법원 2024. 7. 11. 선고 2023다301941 판결).

예컨대 회사의 이사인 원고가 피고회사를 상대로 소를 제기하면서 상법 394조를 위반하여 대표자를 피고회사의 대표이사로 한 경우 피고회사의 대표자를 감사로 정정하면 그 흠은 보정될 수 있다(대법원 1990. 5. 11. 선고 89다카15199 판결).

나아가 법원이 당사자인 사건에서 그 법인의 대표자에게 적법한 대표권이 있는지 여부는 소송요건에 관한 것으로서 법원의 직권조사사항이므로, 법원 으로서는 그 판단의 기초 자료인 사실과 증거를 직권으로 탐지할 의무까지는 없다 하더라도, 이미 제출된 자료들에 의하여 그 대표권의 적법성에 의심이 갈 만한 사정이 엿보인다면 상대방이 이를 구체적으로 지적하여 다투지 않더라도 이에 관하여 심리·조사할 의무가 있고, 이는 당사자가 비법인사단인 경우에도 마찬가지이다(대법원 1997. 10. 10. 선고 96다40578 판결, 대법원 2024. 4. 12. 선고 2023다313241 판결).

예컨대 원고가 단체를 상대로 직무집행정지가처분 결정이 내려진 대표자의 대표자 지위 부존재 확인의 소를 제기하면서 그 대표자를 단체의 대표자로 표시한 소장을 제출하고 법원도 그 대표자를 송달받을 사람으로 하여 소장 부분을 송달한 후 소송절차가 진행되었다면, 그 대표자에게는 그 소송에 관하여 단체를 대표할 권한이 없기 때문에 소장 부분이 단체에 적법·유효하게 송달되었다고 볼 수 없고 그 대표자가 단체를 대표하여 한 소송행위나 원고가 그 대표자에 대하여 한 소송행위는 모두 무효가 된다. 따라서 법원은 원고들에게 보정을 명하여 소장에 표시된 피고의 대표자를 적법한 대표권이 있는 사람으로 보정하도록 하고, 보정이 이루어지면 적법한 대표권이 있는 사람에게 소장 부분을 송달함으로써 소송계속의 효과가 발생하도록 하는 등의

조치를 취하여야 한다(대법원 2024. 4. 12. 선고 2023다313241 판결).

라. 청구의 취지

(1) 총 설

원고의 주장은 원칙적으로 일정한 권리 또는 법률관계의 존부에 관한 주장이라는 형식을 취한다. 이것이 바로 청구이고 그 내용이 되는 권리관계를 ‘소송물’이라 한다. 청구의 특징은 청구취지 및 청구원인의 기재에 의하여 행하여진다.

‘청구의 취지’란 원고가 당해 소송에서 소로써 청구하는 판결의 주문 내용을 말하는 것으로서 소의 결론 부분이다. 이는 후술하는 ‘청구의 원인’에 대한 결론으로서 원고가 소로써 달성하려는 목적이 구체적으로 표현되며, 이에 의하여 원고가 어떤 주문의 판결을 구하는가가 표시되는 것이므로 그 내용·범위 등이 간결·명확하지 않으면 안 된다.

청구취지는 소송물의 동일성을 가리는 기준으로서 당사자 처분권주의(민소 203조)에 의하여 법원은 그 범위에 구속되어 재판하여야 하기 때문에 매우 중요한 의미를 가지고 있다. 그 밖에도 청구취지는 소송목적의 값의 산정, 사물관할, 상소이익의 유무, 소송비용의 부담비율, 시효중단의 범위 등에서 표준이 된다.

소장 중 ‘청구의 취지’는 별도의 항목으로 구분하여 기재하는 것이 일반적이다. 다만 예비적 청구취지를 청구취지라는 제목 아래 별도로 표시하지 않고 준비서면에 표시하였다 하여 청구취지를 표시하지 않은 것이라 할 수 없다(대법원 1965. 4. 27. 선고 65다319 판결).

(2) 청구취지의 명확성·확정성·간결성

첫째로, 청구취지의 기재는 청구가 인용되는 경우 이를 판결의 주문으로 그대로 옮겨 적을 수 있을 만큼 정확하여야 한다. 소송의 유형은 청구취지에 따라 정하여지는 것이므로 청구취지는 청구의 형태와 내용 및 범위를 명확

히 알아볼 수 있도록 구체적으로 특정하여야 한다. 금액인 경우에는 그 액수를 명시하여야 하고, 물건인 경우에는 그 물건이 특정되도록 구체적으로 표시하여야 하며, 법률관계인 경우에는 그 동일성을 인식할 수 있을 정도로 특정하여야 한다.

청구취지의 특정 여부는 직권조사사항이므로 청구취지가 특정되지 않은 경우에 법원은 피고의 이의 유무에 불구하고 직권으로 그 보정을 명하고, 그 보정명령에 응하지 아니할 때에는 소를 각하하여야 한다(대법원 2023. 6. 1. 선고 2021다260343 판결). 다만 형식적으로는 청구취지 보정의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 보정명령 없이 소를 각하하더라도 이를 위법하다 할 수 없다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결).

소장에 일응 청구의 특정이 가능한 정도로 청구취지 및 원인이 기재되어 있다면 비록 그것이 불명확하여 파악하기 어렵다 하더라도 그 후는 석명권 행사의 문제로서 민사소송법 254조 1항의 소장심사의 대상이 되지 않는다고 할 것이고, 석명권 행사에 의하여도 원고의 주장이 명확하게 되지 않는 경우에는 비로소 원고의 청구를 기각할 수 있을 뿐이다(대법원 2004. 11. 24. 자 2004무54 결정). 또한 당사자가 부주의 또는 오해로 인하여 청구취지가 특정되지 아니한 것을 명백히 간과한 채 본안에 관하여 공방을 하고 있는 데도 보정의 기회를 부여하지 아니한 채 당사자가 전혀 예상하지 못하였던 청구취지 불특정을 이유로 소를 각하하는 것은 석명의무를 다하지 아니하여 심리를 제대로 하지 아니한 것으로서 위법하다(대법원 2014. 3. 13. 선고 2011다111459 판결). 청구취지 자체가 법률적으로 부당하거나 그 청구원인과 서로 맞지 아니함이 명백한 경우에도, 법원은 원고가 소로써 달성하려는 진정한 목적이 무엇인가를 석명하여 청구취지를 바로잡아야 한다(대법원 2001. 11. 13. 선고 99두2017 판결).

둘째로, 청구취지에서 요구하는 판결의 내용은 확정적이어야 한다. 따라

서 조건부 또는 기한부로 판결을 구하는 것은 절차의 안정을 해하므로 허용되지 않는 것이 원칙이다. 다만 당해 소송절차 내에서 밝혀진 사실을 조건으로 하여 청구취지를 기재하는 예비적 청구나 예비적 반소(대법원 2021. 3. 25. 선고 2019다208441 판결)는 소송절차의 안정을 해할 염려가 없기 때문에 허용되며, 민사소송법은 일정한 요건 하에 예비적 공동소송(민소 70조)도 허용하고 있다. 심판청구 자체에 조건을 다는 것이 아니라, 상환이행 또는 선이행을 구하는 소와 같이 권리의 내용이 조건부인 것을 토대로 심판을 구하는 것이 허용됨은 물론이다.

셋째로, 청구취지는 원고가 소로써 달성하고자 하는 목적만을 간결하게 기재하여야 한다. 예컨대 금전의 지급을 구하는 청구일 때에는 지급할 금전의 액수와 부대금액의 발생기간과 비율 등을 명시하면 충분하고, 그 외에 차용금인지 손해배상금인지, 부대금액이 이자인지 지연손해금인지 따위를 기재할 필요는 없다. 한편 내용이 복잡하거나 다수의 목적물을 표시하여야 할 사건에서는 별지 또는 별표를 작성하여 그것을 청구취지에서 인용하는 방법이 활용되고 있는데, 이러한 별지 또는 별표는 청구취지의 일부가 되므로 오기나 누락이 없도록 유의하여야 한다.

(3) 각종의 소에 관한 청구취지의 기재 요령

(가) 이행의 소에 관한 청구취지

이행의 소에서는 “피고는 원고에게 10,000,000원을 지급하라.”, “피고는 원고에게 ○○건물을 인도하라.”와 같이 이행명령을 구하는 취지를 간결하게 표시하여야 한다. 청구취지에는 이행할 채무의 종류, 법적 성질, 발생원인 등을 나타내지 않는 간결한 표현을 사용한다.

이행판결은 집행력을 가지므로 이행의 소에 관한 청구취지는 강제집행의 단계까지 고려하여 그 집행이 가능하도록 구성하여야 한다.

① 금전의 지급을 구하는 경우에는 그 액수를 명시하여야 하며, 구체적인 액수를 밝히지 않고 ‘현시가 상당의 임대료’ 또는 ‘법원이 적당하다고 인정

하는 금액'을 지급하라는 방식의 청구취지는 허용되지 않는다. 여러 명의 피고들에 대하여 중첩적으로 금전의 지급을 구하는 때에는 각각의 상호관계와 각자의 의무 범위가 명확하게 되도록 '연대하여'(연대채무의 경우), '합동하여'(어음·수표채무자의 합동채무의 경우), '공동하여'(부진정연대채무, 불가분채무와 그 밖에 채무자 각자가 전액에 대하여 책임을 지는 경우, 예전에는 '각자'라는 문구를 사용하였다)와 같은 문구를 부가하여 피고들의 의무 사이에 중첩관계가 있음을 기재하여야 한다. 그러한 중첩관계를 표시하지 아니하면 분할 지급을 구하는 것이 된다.

② 물건의 인도를 구하는 경우에는 집행 대상 물건이 특정되도록 구체적으로 표시하여야 한다. 특정물의 인도를 구하는 경우에는 그 목적물의 특성을 위하여 동일성을 인식하는 데 필요한 사항을 명확하게 표시하여야 한다. 특히 인도 소송의 목적물이 부동산인 경우에 청구취지의 특징에 주의할 필요가 있는데, 토지는 토지대장상 표시에 따라 그 지번, 지목과 면적을(이와 달리 토지에 관한 소유권이전등기청구소송과 같이 의사의 진술을 명하는 판결을 구하는 경우에는 토지대장이 아니라 등기기록상 표시에 따라 특정한다), 건물은 등기사항전부증명서상의 표시에 따라 그 대지의 지번, 건물의 구조·층수·용도·건축면적 등을 빠짐없이 정확히 기재하여야 한다. 이때 해당 건물의 등기사항전부증명서 표제부 기재방식에 따라 지번주소만 있는 경우에는 지번주소를 기재하고, 도로명주소와 지번주소가 모두 있는 경우에는 '서울 서초구 서초대로 219(서초동 967)'와 같이 도로명주소와 지번주소를 병기한다. 나아가 토지의 일부 또는 건물의 일부 등에 대한 인도·철거 등 소송에서는 방위와 거리·척도 등으로 그 부분을 특정하는 도면을 별지로 붙여야 한다. 특정물을 목적으로 하는 이행의 소에서 원고가 그 목적물을 특정하여 청구하고 있는지 여부는 소장(또는 그 정정서)의 청구취지 기재뿐만 아니라 변론의 전 과정에 의하여 판단되어야 한다(대법원 1988. 4. 25. 선고 87다카2819 판결). 그리고 종류물의 인도를 구하는 청구취지는 목적물을 특정할 수 있고

록 수량·품질·종별 등 종류물의 표준을 확정하는 데 필요한 사항을 빠짐없이 표시하여야 한다(대법원 1965. 9. 21. 선고 65다1427 판결).

③ 의사의 진술을 구하는 경우에는 그 판결이 확정되면 일정한 의사의 진술이 있는 것으로 보게 되므로(민집 263조 1항) 의사표시의 내용을 구체적으로 명시하여야 한다. 말소등기나 회복등기 절차의 이행을 구하는 경우에는 원칙적으로 목적부동산, 말소 또는 회복의 대상인 등기의 관할등기소, 접수 연월일, 접수번호, 등기의 종류를 순서대로 명시하면 되고, 그 밖에 등기의 원인이나 등기의 내용까지 표시할 필요는 없다. 다만 유효하던 등기가 후발적 실효사유에 의하여 장래에 향하여 실효됨을 원인으로 말소등기를 구할 경우, 예컨대 변제나 설정계약의 해지로 인한 저당권의 소멸 등의 경우에는 그 소멸 사유를 말소등기의 원인으로 청구취지에 기재하여야 한다. 이전등기절차의 이행을 구하는 소송의 청구취지에는 등기의 종류와 내용뿐만 아니라 등기원인과 그 연월일까지 표시하여야 한다. 등기원인이 달라지면 소송물이 달라지므로 법원은 당사자가 청구한 등기원인에 구속되며 마음대로 등기원인을 달리 표시할 수 없다.

④ 하나의 채권 중 일부만을 청구하는 경우에는 일부 청구임을 명시하여야 한다. 일부 청구라는 취지를 명시하지 아니하면 그 일부 청구에 대한 판결의 기판력은 나머지 부분에 대하여도 미친다. 일부 청구임을 명시하는 방법으로는 반드시 전체 채권액을 특정하여 그중 일부만을 청구하고 나머지에 대한 청구를 유보하는 취지임을 밝혀야 할 필요는 없으며, 일부 청구하는 채권의 범위를 잔부 청구와 구별하여 심리의 범위를 특정할 수 있는 정도의 표시를 하여 전체 채권의 일부로서 우선 청구하고 있는 것임을 밝히는 것으로 충분하다. 그리고 일부 청구임을 명시하였는지 판단할 때에는 소장, 준비서면 등의 기재뿐만 아니라 소송의 경과 등도 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 7. 27. 선고 2013다96165 판결). 한편 소액사건심판법의 적용을 받을 목적으로 청구를 분할하여 그 일부만을 청구할 수 없고(소액 5조의2 1항), 이

에 위반한 소는 판결로 이를 각하하여야 한다(2항).

(나) 확인의 소에 관한 청구취지

확인 소에는 적극적 확인의 소와 소극적 확인의 소가 있는데, “○○부동산이 원고의 소유임을 확인한다.”, “원고의 피고에 대한 2025. 10. 15. 자 소비대차계약에 기한 10,000,000원의 대여금 채무가 존재하지 아니함을 확인한다.”와 같이 확인의 대상이 되는 권리 또는 법률관계가 특정될 수 있도록 그 종류·범위·발생원인 등을 명확히 하고 목적물도 특정하여 표시한 후 그 존재나 부존재의 확인을 구하는 취지를 기재하여야 한다. 특히 토지의 일부가 확인소송의 목적이 된 경우에는 특정물의 인도를 구하는 이행의 소의 경우와 마찬가지로 목적물을 정확하게 특정하여야 한다. 토지와 그 지상 건물의 소유권확인을 구하면서 토지의 지번·지목·면적만을 표시하고 건물에 관하여는 ‘지상 건물 일체 포함’으로만 표시하였다면 건물의 표시가 특정되지 아니하여 부적법하다.

그 표시의 정도는 대상 권리가 물권인가 채권인가에 따라 약간의 차이가 있다. 물권의 확인을 구하는 경우에는 목적물과 주체 및 종류(제한물권의 경우에는 내용까지)만 명백히 하는 것으로 충분하다. 물권의 경우에는 동일 주체가 동일 목적물에 대하여 가지는 동일 종류의 권리가 여러 개 있을 수 없기 때문이다. 그러나 채권의 존재 또는 채무의 부존재의 확인을 구하는 경우에는 채권의 목적, 범위뿐만 아니라 발생원인까지도 명백히 하여야 한다. 왜냐하면, 채권의 경우에는 동일 당사자 사이에 동일한 내용의 권리가 발생원인을 달리하여 여러 개 존재할 수 있기 때문이다. 당사자가 복수인 경우에는 당사자 누구와 누구 사이에 어떠한 권리관계의 확정을 구하는 것인가를 명확히 표시하여야 한다.

확인 청구의 대상은 현재의 권리 또는 법률관계이지만, 예외적으로 법률관계를 증명하는 서면에 대하여는 사실관계임에도 불구하고 그 진부확인 청구가 허용되고 있다(민소 250조). 위와 같은 증서의 진정 여부를 확인하는

소의 청구취지는 확인의 대상이 되는 문서의 작성일자과 내용을 명확하게 하여야 한다. 한편 과거의 법률관계는 현재의 권리 또는 법률관계에 관하여 확정할 이익이 없어 확인의 소의 대상이 될 수 없음이 원칙이지만, 과거의 법률관계라고 하더라도 그에 대한 확인을 구하는 것이 이와 관련된 다수 분쟁을 일거에 해결하는 유효·적절한 수단이 될 수 있는 경우 등에는 예외적으로 확인의 이익이 인정될 수 있다. 또한 당사자가 현재의 권리나 법률관계에 존재하는 불안·위험이 있어 확인을 구하는 소를 제기하였으나 법원의 심리 도중 시간적 경과로 인해 확인을 구하는 대상이 과거의 법률관계가 되어 버린 경우, 법원으로서 확인의 대상이 과거의 법률관계라는 이유로 확인의 이익이 없다고 보아 곧바로 소를 각하할 것이 아니라, 당사자에게 현재의 권리 또는 법률상 지위에 대한 위험이나 불안을 제거하기 위해 과거의 법률관계에 대한 확인을 구할 이익이나 필요성이 있는지 여부를 석명하여 이에 관한 의견을 진술하게 하거나 당사자로 하여금 청구취지를 변경할 수 있는 기회를 주어야 한다(대법원 2022. 6. 16. 선고 2022다207967 판결).

채권자가 채무의 이행을 구하는 소 계속 중 회생절차개시결정으로 인하여 채무자의 관리인이 그 채권을 부인하면서 소송을 수계하는 경우 회생채권자는 회생채권의 확정을 하는 것으로 청구취지 등을 변경하여야 하고, 당사자가 명확한 의사를 밝히지 않는다면 법원이 청구취지를 변경 또는 추가할 의사가 있는지 석명하여야 한다(대법원 2015. 7. 9. 선고 2013다69866 판결). 예컨대 “원고(또는 반소원고)의 채무자 ○○○에 대한 회생채권은 ○○○원임을 확정한다.”라고 청구취지가 정리되어야 한다. 이러한 법리는 파산절차에서도 마찬가지이다(대법원 2020. 12. 10. 선고 2016다254467 판결).

(다) 형성의 소에 관한 청구취지

형성의 소에서는 “피고와 ○○○ 사이에 별지 목록 기재 부동산에 관하여 2025. 4. 1. 체결된 매매계약을 취소한다.” 또는 “피고의 주주총회가 2025. 5. 1.에 한 별지 기재 결의를 취소한다.”와 같이 권리관계의 변동을 구하는

취지를 명확하게 하여야 한다. 청구취지는 확인청구의 그것과 마찬가지로 대체로 형성효과의 발생을 선언하는 형태(…한다)로 표시하여야 하고, 그 효과의 발생을 명하는 형태(…하라)를 취하여서는 아니 된다.

다만 공유물분할의 소, 경계확정의 소, 법정지상권자에 대한 지료청구의 소(민법 366조) 등 형식적 형성의 소에서는 어떠한 내용의 판결을 할 것인가가 법원의 재량에 맡겨지기 때문에 통상의 소에서와 같이 청구취지를 반드시 명확히 특정할 필요는 없고, 법관의 재량권행사의 기초가 될 정도로만 기재하면 된다(대법원 1993. 11. 23. 선고 93다41792 판결, 대법원 2021. 8. 19. 선고 2018다207830 판결).

(4) 소송비용과 가집행에 관한 기재 여부

보통 소장의 청구취지에는 원고가 구하는 판결의 종류와 내용 이외에 “소송비용은 피고가 부담한다.”라는 소송비용에 관한 재판과 가집행선고의 신청을 기재하는 것이 대부분이다. 그러나 소송비용의 재판은 원칙적으로 직권으로 하여야 하고(민소 104조), 또 가집행선고도 상당한 이유가 없는 한 당사자의 신청의 유무를 불문하고 직권으로 하여야 하는 것이기 때문에(213조 1항, 예외: 406조, 435조), 이러한 신청은 직권의 발동을 촉구하는 데 그치는 것이고 이를 기재할 필요는 없다. 그리고 따로 가집행선고의 신청을 하더라도 직권발동을 촉구하는 의미밖에 없기 때문에 인지를 붙일 필요가 없다(인지 10조 단서, 인지액·편철방법예규).

마. 청구의 원인

(1) 총 설

‘청구의 원인’이란 소송상의 청구로서 원고가 주장하는 권리 또는 법률관계(소송물)의 성립원인인 사실을 말한다. 청구원인은 청구취지와 더불어 또는 이를 보충하여 청구를 특정하기에 필요한 사실관계를 뜻한다. 소장에 청구의 원인을 기재하게 하는 것은 청구의 취지와 합쳐서 심판의 대상인 청구

(소송물)를 특정하기 위해서다.

확인의 소에서는 청구취지에 확인의 대상인 권리의무와 그 범위가 표시되므로, 소송물의 특정을 위하여 청구취지 외에 청구원인을 필요로 하는 것은 아니다. 그러나 이행의 소에서는 청구취지가 추상적으로 표시되어 이행청구권을 특정하기 위하여는 청구원인이 필요하고 이는 형성의 소에서도 마찬가지이다. 예컨대 재판상 이혼청구의 경우 민법 840조에서 정한 이혼원인마다 소송물이 달라지므로 청구취지에 나타나지 않는 이혼원인의 표시를 하여야 비로소 소송물이 특정되고(대법원 1963. 1. 31. 선고 62다812 판결), 수 개의 이혼사유를 주장하는 경우 법원은 그중 어느 하나를 받아들여 청구를 인용할 수 있다(대법원 2000. 9. 5. 선고 99므1886 판결).

청구원인 사실은 청구를 특정·식별하는 표준으로서 처분권주의(민소 203조), 청구의 병합 또는 변경의 유무(253조, 262조), 중복제소금지(259조), 기판력의 객관적 범위(216조), 재소금지(267조) 등을 판정하는 기준이 된다.

(2) 청구원인의 기재 사항 및 기재 정도

소장의 청구원인에는, ① 청구를 뒷받침하는 구체적 사실, ② 피고가 주장할 것이 명백한 방어방법에 대한 구체적인 진술, ③ 증명이 필요한 사실에 대한 증거방법을 적어야 한다(민소규 62조). 그러나 위 각 기재사항을 소장 제출 시부터 모두 요구하는 것은 가혹하므로 이는 사실심의 변론 종결 시까지 보완할 수 있다고 보아야 한다.

필요적 기재사항인 청구의 원인사실을 어느 정도로 기재할 것인가에 대하여는 구소송물이론과 신소송물이론 사이에 학설의 대립이 있으나, 적어도 소송상의 청구를 다른 청구와 식별·특정하고 혼동·오인을 일으키지 않는 정도로 기재하여야 한다. 청구를 특정하는 방법은 물권의 경우와 채권의 경우가 다르다.

① 물권이나 그 밖의 절대권(특허권, 상표권, 저작권 등의 지식재산권)을 소송물로 하는 소송에서는 원칙적으로 권리의 종류, 주체 그리고 권리의 대상인

객체를 기재하면 족하다. 물권과 같은 절대권에서는 하나의 물건에 대하여 2개 이상의 권리가 성립할 수 없기 때문이다. 그러나 저당권은 동일한 물건에 대하여 순위를 달리하여 병존할 수 있으므로 등기기록의 기재에 따라 저당권의 내용과 순위를 기재하여 이를 특정하여야 한다. 다른 제한물권의 경우에도 마찬가지로 그 내용까지 기재한다.

② 채권과 같은 상대적·비배타적 권리의 경우에는 같은 내용의 권리가 동일 당사자 사이에 여러 개가 성립할 수 있기 때문에 물권과 같이 권리의 주체와 내용이 될 사실만을 적어서는 소송물이 특정되지 아니하고 발생원인까지 밝혀야 한다. 따라서 계약상의 청구권이면 계약의 당사자, 종류, 내용(금액), 성립 일시·장소 등 그 발생원인인 구체적 사실을 청구의 원인사실로 기재하여야 한다. 동일물의 인도청구도 그 청구권원이 소유권, 점유권 또는 매매나 그 밖의 계약이냐에 따라 각각 별개의 청구로 된다.

특히 불법행위로 말미암아 신체의 상해를 입었음을 원인으로 가해자에게 손해배상을 청구하는 경우에 그 소송물인 손해는 통상의 치료비와 같은 적극적 재산상 손해와 일실수익과 같은 소극적 재산상 손해 및 정신적 고통에 따르는 정신적 손해(위자료)의 3가지로 나누어지므로(손해3분설), 손해를 발생하게 한 가해행위의 일시·장소·내용과 함께 위 세 가지 종류의 손해에 대한 각각의 금액과 산출근거를 기재하여야 소송물의 특징이 가능하고, 이에 따라 각 손해마다 따로 심리·판단되어야 한다(대법원 2022. 4. 28. 선고 2022다200768 판결).

3. 소장의 임의적 기재사항

가. 총 설

소장에는 준비서면에 관한 규정이 준용되므로(민소 249조 2항), 앞에서 설명한 네 가지 필수적 기재사항 이외에도 준비서면의 기재사항으로 규정된 사항(274조)을 기재하는 것이 바람직하다. 이는 소장으로 하여금 원고의 최

초 준비서면으로서의 역할을 하게 하려는 취지이다.

소장의 임의적 기재사항은 기재가 누락되었더라도 재판장에 의한 소장각하명령(제3절 라. 참조)의 사유가 되지 않는 점에서 앞에서 설명한 필수적 기재사항과 구별된다.

나. 기재사항

준비서면의 기재사항으로 규정된 것 중에서 앞에서 설명한 필수적 기재사항과 중복되지 않는 것을 순서대로 설명하면 다음과 같다.

① 표 제

소장에는 관행적으로 서류의 명칭에 해당하는 표제를 기재하는데 일반적인 경우에는 ‘소장’이라고 기재하며, 반소인 경우에는 ‘반소장’, 재심청구인 경우에는 ‘재심소장’ 등으로 기재한다.

② 소송대리인의 성명과 주소(민소 274조 1항 2호)

소송대리권이 위임에 의하여 발생하지 아니하고 법령의 규정에 의하여 발생하는 경우 그 자격, 지위 등과 함께 성명을 기재한다. 소송대리인이 법무법인·법무법인(유한)·법무조합인 경우·당해 사건의 업무를 담당할 것으로 지정된 변호사(변호사법 50조 1항)를 표시하여야 한다.

소송대리인이 변호사인 경우 소송수행상 법원으로부터 송달과 연락의 편의를 도모하기 위하여 주소뿐만 아니라 전화번호·팩시밀리번호·전자우편주소 등 연락처를 함께 적어야 한다(민소규 2조 1항 2호).

한편 법무법인(유한 포함)이 당사자인 경우에는 상법 중 합명회사에 관한 규정에 따라 등기된 법무법인의 대표자만이 법무법인을 대표하여 업무를 수행할 수 있을 뿐 담당변호사가 법무법인을 대표하여 해당 업무를 수행할 수 없으므로(대법원 2022. 5. 26. 선고 2017다238141 판결), 소송대리인 표시 부분에 당사자인 법무법인을 다시 기재하거나 담당변호사를 기재하지 않도록 주의해야 한다.

③ 사건의 표시(민소규 2조 1항 1호)

사건은 사건번호와 사건명이 표시됨으로써 그 동일성이 명확하게 된다. 소장의 사건명은 청구취지 및 원인과 아울러 청구의 성격을 특정시켜 주는 역할을 하고 또한 법원에서 사건명을 부여하거나 분류하는 데 도움을 주므로 일반적으로 기재하고 있다(전자소송의 경우 예시된 여러 사건명 중에 하나를 선택하여 입력할 수 있도록 하고 있다). 법원에서는 대개 소장에 기재된 사건명에 따라 그대로 사건명을 부여하고 있으므로 사건명은 정확하고 간결하여야 한다.

통상 사용되는 사건명에는 대여금·물품대금·매매대금·공사대금·임대차보증금·구상금·약정금·용역비·추심금·임금·부당이득금·손해배상·위자료·보험금·수표금·양수금·건물인도·소유권이전등기·근저당권설정등기말소·소유권확인·공유물분할·주주총회결의부존재확인 등이 있다. 소장에 기재할 사건명이 여러 개인 경우에는 ‘소유권이전등기 등’ 또는 ‘약속어음금 등’의 방식으로 주된 한 가지 사건명만을 간략하게 기재하는 것이 관례이다.

손해배상청구 사건에서 사건명을 기재할 경우 자동차손해배상보장법에서 정한 자동차 및 원동기장치자전거, 철도차량의 운행으로 인한 청구는 ‘손해배상(자)’로, 근로자의 업무상재해로 인한 청구는 ‘손해배상(산)’으로, 의료과오로 인한 청구는 ‘손해배상(의)’로, 공해(토지오염, 수질오염, 공기오염, 소음 등), 그 밖의 환경오염 또는 훼손으로 인한 청구는 ‘손해배상(환)’으로, 지식재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권 및 프로그램 저작권 등)의 침해로 인한 청구는 ‘손해배상(지)’로, 프로그램 저작권 이외의 저작권 침해로 인한 손해배상청구는 ‘손해배상(저)’로, 언론보도로 인한 청구는 ‘손해배상(언)’으로, 건설·건축 관련 청구는 ‘손해배상(건)’으로, 국가 또는 지방자치단체를 상대로 하는 청구는 ‘손해배상(국)’으로, 해사사건으로 인한 손해배상청구는 ‘손해배상(해)’로, 위의 어느 하나에 해당하지 않는 청구는 ‘손해배상(기)’로 구분하여 사건명을 표시하도록 되어 있다(재민 86-5 손해배상 사

건에 대한 사건명 표시의 구분).

사건에 관하여 최초에 붙인 사건번호와 사건명은 그 사건이 종국에 이르기까지 계속하여 사용한다. 다만 사건명은 잘못이 있음이 분명한 때에는 제1심 종국에 이르기까지 재판장의 허가를 받아 정정할 수 있다(재판사무규 19조 3항).

④ 공격방법(민소 274조 1항 4호)

소장에는 청구를 뒷받침하는 구체적 사실을 기재해야 하고(민소규 62조 1호), 이는 소장에 기재하는 임의적 기재사항 중 가장 중요하다. 실무에서는 앞서 본 필수적 기재사항인 협의의 청구원인, 즉 소송물을 특정하는 데 필요한 사실관계 이외에도, 광의의 청구원인, 즉 소송물인 권리관계의 발생원인으로서 원고가 주장·증명하여야 할 구체적 사실관계의 전부를 기재하는 것이 통례이다. 실무상 이것을 요건사실이라 하는데, 협의의 청구원인을 뒷받침하는 최초의 공격방법이 되는 셈이다.

민사소송법은 적시제출주의와 재정기간 제도(민소 146조, 147조)를 채택하여 공격 또는 방어방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 하고, 재판장은 당사자가 주장을 제출하거나 증거를 신청할 기간을 정할 수 있으며, 그 기간을 넘긴 때에는 정당한 사유가 없는 한 추가로 주장을 제출하거나 증거를 신청할 수 없도록 하였다. 특히 증인신문과 당사자신문은 당사자의 주장과 증거를 정리한 뒤 집중적으로 하여야 하므로(293조), 소장에 공격방법을 기재하여 쟁점을 부각시켜 주어야 상대방의 실질적이고 구체적인 답변을 받아낼 수 있을 것이다.

원고는 공격방법으로 변론주의 원칙상 소로써 주장하는 권리의 발생근거가 되는 실체법규의 내용에 따라 정해지는 요건사실을 무변론판결을 할 수 있을 정도로 빠짐없이 기재하여야 하고, 또 이로써 충분하다. 나아가 상대방의 항변이 명백히 예측되는 경우에는 소장에 항변에 대한 재항변이나 다툼이 예상되는 요건사실을 인정할 간접사실 등 추가적인 공격방법까지 미리

기재함으로써, 조기에 쟁점을 부각시켜 소송 진행을 촉진하고 충실한 심리를 도모할 수도 있다(민소규 62조 2호).

⑤ 증거방법으로 소장에 덧붙인 서류의 표시(민소 274조 1항 6호, 민소규 63조 3항)

실무상 소장에는 관행적으로 ‘증거방법’이라고 표시한 다음 청구원인과 관련된 증거서류를 기재하면서 이를 덧붙이고 있다. 그런데 원래 증거방법의 표시는 소장의 필수적 기재사항도 아니고 또 소장에 모든 서증의 사본을 반드시 덧붙여야 하는 것도 아니므로, 그러한 증거방법의 표시나 증거서류가 누락되어도 소장의 기재요건에 어긋나는 것은 아니다.

그렇지만 서증 가운데 적어도 청구원인 사실로 기재한 신분관계 등의 증명에 필요한 ‘기본적 서증’이나 소제기 당시 예상되는 상대방의 방어방법과 관련하여 필요한 서증은 가능한 한 미리 소장에 붙여서 제출하는 것이 좋다. 그렇게 함으로써 상대방의 불필요한 항쟁을 피할 수 있게 됨은 물론 원고 측이 증명의 수고를 더는 결과가 되어 소송촉진에 이바지하게 된다.

⑥ 증거보전 사건의 표시(민소규 62조의2)

소제기 전에 증거보전을 위한 증거조사가 이루어지면 증거보전에 관한 기록은 본안소송에 관한 증거방법의 하나로 사용되는 경우가 많다. 증거보전에 관한 기록은 증거조사를 마친 후 2주일 안에 본안의 소송기록이 있는 법원에 보내야 하며, 증거보전에 따른 증거조사를 마친 후에 본안소송이 제기된 때에는 본안소송 계속 법원의 송부요청을 받은 날부터 1주일 안에 증거보전에 관한 기록을 보내야 한다(민소 382조, 민소규 125조). 그런데 당사자가 증거보전을 위한 증거조사가 실시되었다는 사실을 신고하지 아니하는 이상 본안소송 계속 법원이 기록의 송부를 요청하기 어렵게 된다.

따라서 소제기 전에 증거보전을 위한 증거조사가 이루어진 때에는 증거보전 기록이 확실히 송부될 수 있도록 하기 위하여, 소장에 증거조사를 한 법원과 증거보전사건의 사건번호·사건명을 적어야 한다(민소규 62조의2).

⑦ 작성한 날짜(민소 274조 1항 7호)

소장의 맨 끝에 소를 제기하는 연, 월, 일을 기재한다. 당사자가 작성하는 소송서류는 법원에 제출하여 접수되지 않는 한 무의미한 것이므로 법원에 접수하는 날을 작성일로 기재하여야 할 것이다.

⑧ 법원의 표시(민소 274조 1항 8호)

소장에 표시하는 법원은 당해 소송의 관할법원이다. 소장을 작성, 제출할 때에는 관할법원에 관하여 검토함으로써 관할위반 때문에 입는 소송법상의 불이익을 방지하여야 한다. 특히 전속관할 사건에서는 합의관할이나 변론관할이 허용되지 않으므로 유의하여야 한다.

4. 소장의 첨부서류**가. 총 설**

소장에 덧붙이는 서류에는 위에서 본 증거방법으로 표시하는 서증의 사본 외에도 소제기와 관련하여 필요한 여러 가지 다른 서류가 있다. 통상 소장에는 '첨부서류'라고 하여 소장에 덧붙이거나 함께 제출하는 서류의 이름과 그 통수를 기재하는데, 소장 접수 시에 어떠한 서류를 제출하였는지 나중에 확인하는 자료가 된다.

나. 소송목적의 값의 산정에 필요한 자료

소송목적의 값은 사물관할, 불일 인지액, 소송비용의 부담비율, 보전처분이나 가집행선고 시의 보증금액 등을 결정하는 기준이 되므로, 정확히 계산하여 소장에 기재하여야 한다. 만일 소장에 기재된 청구취지와 청구원인만으로 소송목적의 값을 산정하기 어렵다면, 소장에 그 산정에 필요한 자료를 붙여야 한다(인지규 8조 1항).

예컨대 토지 또는 건물에 관한 소송을 제기하는 경우에는 목적물의 개별공시지가 또는 시가표준액을 알 수 있는 토지대장등본, 공시지가확인원 또는 건

축물대장등본 등을 제출하여야 한다(인지규 8조 2항). 동산이나 그 밖에 공시 가격이 없는 경우에는 이를 인정할 자료로 계약서나 감정서 등을 제출한다.

법원은 소송목적의 값의 산정을 위하여 필요한 때에는 직권 또는 신청에 의하여 공무소나 그 밖의 상당하다고 인정되는 단체 또는 개인에게 사실조사 또는 감정을 촉탁하고, 필요한 사항의 보고를 요구할 수 있다(인지규 8조 3항). 만일 소송목적의 값의 산정을 위하여 비용이 필요한 경우 그 비용은 당사자가 예납하여야 하며, 소송비용의 일부가 된다(4항). 그럼에도 불구하고 소송목적의 값의 산정을 위한 자료의 미비, 그 밖의 사유로 인하여 소송목적의 값을 산정하기 어려운 경우 재판장이 소송목적의 값을 인정한다(3조, 2조 5항 후문).

다. 법정대리권·대표권의 자격을 증명하는 서면

당사자가 소송능력이 없는 때에는 법정대리인, 법인인 때에는 대표자, 법인 아닌 사단이나 재단인 때에는 그 대표자 또는 관리인의 자격을, 선정당사자를 선정하고 바꾸거나 또는 소송대리권을 수여한 경우에는 그 사실을 서면으로 증명하여야 하며(민소 58조, 64조, 97조), 이러한 서면은 소송기록에 붙여야 한다(58조 2항). 따라서 이러한 당사자가 원고가 되어 소를 제기하는 경우에는 위와 같은 증명 서면을 소장에 붙여서 제출하여야 함은 물론, 소제기의 상대방인 피고가 그러한 당사자인 경우에도 원고가 피고의 법정대리인, 대표자 또는 관리인의 자격을 증명하는 서면까지 소장에 붙여서 제출해야 한다(민소규 63조 1항). 나아가 법원은 법인이 아닌 사단 또는 재단이 당사자가 되어 있는 때에는 언제든지 정관·규약, 그 밖에 그 당사자의 당사자능력을 판단하기 위하여 필요한 자료를 제출하게 할 수 있다(12조).

소제기 상대방인 피고가 법인이 아닌 사단이나 재단인 경우에는 그 대표자 또는 관리인의 자격증명서를 원고가 미리 구하기 어려운 경우도 있을 것이나, 가능한 한 소제기 전에 이를 준비하여 소장에 붙이라는 취지이다. 그

렇게 함으로써 소송의 지연을 방지할 수 있고, 특히 답변서 부제출 등의 경우에는 무변론판결이 가능하게 되어 편리하다.

이상의 증명 서면을 구체적으로 보면 다음과 같다.

① 소송무능력자(미성년자·피성년후견인 등)의 법정대리인(친권자 또는 미성년후견인·성년후견인 등)에 관하여는 그 법정대리권을 증명하는 가족관계등록사항증명서, 미성년후견인지정서(민법 931조), 성년후견인선임심판서(936조) 등의 서면 및 후견감독인이 있는 때에는 후견감독인의 동의서(950조)

다만 미성년자가 독립하여 법률행위를 할 수 있을 경우(민소 51조, 민법 8조, 근로기준법 67조, 68조)에는 법정대리인 없이 단독으로 소송행위를 할 수 있으므로 본인이 직접 소를 제기할 수 있다.

② 법인의 대표자(사단법인이나 재단법인의 이사, 회사의 대표사원·대표이사 등)에 관하여는 그 대표권을 증명하는 법인등기사항증명서

여러 명의 대표자에 관하여 공동대표의 정함이 있거나 그 밖의 대표권에 관한 제한이 있을 때에는 이에 위반된 것이어서는 안 된다.

③ 법인이 아닌 사단이나 재단(민소 52조)의 대표자 또는 관리인에 관하여는 그 대표권이나 관리권을 증명하는 서면(정관·규약·선임결의서·재직증명서 등)

④ 제3자의 소송담당의 경우에는 그 제3자의 소제기 자격을 증명하는 서면(등기사항증명서 또는 채무자회생 81조 2항의 선임증명서면, 357조의 자격증명서 등)

⑤ 선정당사자에 관하여는 당사자를 선정하거나 바꾸었음을 증명하는 서면(선정서)

⑥ 소송대리인에 의하여 소가 제기된 경우에는 위임장(민소 87조, 89조)

⑦ 국가가 당사자인 경우에 국가를 대표하는 법무부장관이 소관부처의 직원으로 하여금 소송수행자로 소송을 수행하게 하여 그가 소장을 제출한 때에는 그 지정서(국당 1조, 2조, 5조, 6조)

라. 기본적 서증 및 그 사본

먼저, 기본적 서증은 피고가 답변방향을 결정하는 데 중요한 단서가 되므로 가능한 한 소장 제출 단계에서 그 사본 등을 붙일 필요가 있다. 예컨대 부동산에 관한 사건에서는 그 부동산의 등기사항증명서, 친족·상속관계 사건에서는 가족관계등록사항증명서, 어음 또는 수표사건에서는 그 어음 또는 수표의 사본을 소장에 붙여야 하며, 그 외에도 증거로 될 문서 가운데 중요한 것의 사본을 붙여야 한다(민소규 63조 2항). 정기금판결의 변경을 구하는 소의 소장에는 변경을 구하는 확정판결의 사본을, 재심소장에는 재심의 대상이 되는 판결의 사본을 붙여야 한다(3항, 139조).

다음으로, 원고가 소장에 서증을 인용한 때에는 그 서증의 등본 또는 사본을 붙여서 제출하여야 한다(민소 254조 4항 참조). 또한 쟁점이 조기에 부각되고 쟁점정리가 효율적으로 이루어지기 위해서는 원고가 소장을 접수할 때부터 청구원인을 명확히 하고 그에 대한 증거방법을 함께 제출하는 것이 바람직하다(민소규 62조 3호).

증거방법의 표시 방법은 소장에 서증의 번호와 서증명을 표시함이 보통이며, 서증이 많고 이에 따라 증명취지의 기재가 필요할 때에는 증거설명서를 작성하여 제출함이 좋다. 서증의 번호는 통상 당사자의 신분관계 등 기본적 서증을 최우선으로 하고, 그다음으로 소장의 청구원인 기재 순서에 따라 번호를 붙이되 중요한 서증을 앞 번호로 하며, 같은 종류의 증거서류가 여러 개 있을 때에는 날짜, 지번 등 일정한 기준에 따라 차례로 가지번호를 붙여 중복되지 않도록 하여야 소송의 진행에 편리하다. 특히 전자소송의 경우 위와 같은 증거방법의 분류 및 표시가 심리 및 판단의 신속·용이성과 직결되므로 주의를 요한다.

한편 증거로 제출된 문서의 원본은 증거조사가 끝나면 이를 반환하여야 하므로(민소 353조 참조) 실무상 당사자에게 그 서증의 사본을 제출하게 하여 이를 기록에 가철 또는 접수한다. 따라서 소장에 붙인 증거서류도 피고의 수

에 1을 더한 수의 사본을 함께 제출하도록 하고(민소규 105조 2항) 이를 피고에게 송달하는 것이 원칙이다. 법원사무관등은 소장을 접수할 때 소장부분에 증거서류의 사본이 빠진 것이 확인되면 그 사본을 제출하도록 권고하여야 하며(5조 3항), 만약 사본이 빠진 채 소장이 접수되었다면 소장부분 송달 전에 전화 등으로 연락하여 사본을 제출하도록 한 다음 피고에게 함께 송달하여야 한다.

다만 피고의 수가 많거나 덧붙인 서류의 분량이 많은 경우에 일률적으로 소장 접수 단계에서 모든 서류의 사본을 제출하도록 하는 것은 비경제적일 수 있다. 이러한 특별한 사정이 있는 경우에는 피고로부터 부인취지의 답변서가 접수된 후에 필요한 수의 사본을 제출하도록 하여 이를 다투는 피고에게만 송달하는 방법으로 운영할 수도 있을 것이다(민소규 105조 2항 단서).

전자소송에서는, ① 미리 전산정보처리시스템을 이용한 민사소송등의 진행에 동의한 등록사용자로서 대법원규칙으로 정하는 자인 경우, ② 전자문서를 출력한 서면이나 그 밖의 서류를 송달받은 후 등록사용자로서 전산정보처리시스템을 이용한 민사소송등의 진행에 동의한 자인 경우, ③ 등록사용자가 국가, 지방자치단체, 그 밖에 그에 준하는 자로서 대법원규칙으로 정하는 자인 경우에는 전자문서인 서증 등을 전산정보처리시스템에 의하여 전자적으로 송달·통지할 수 있고(민전 11조 1항. 다만 이 경우 소송대리인이 있으면 그 소송대리인에게 송달·통지하여야 한다(민전 11조 2항)), 그 외의 경우에는 전자문서를 출력한 서면을 송달하여야 한다(민전 12조. 전자우편을 이용한 e-Post 송달도 가능하다(민전규 29조 4항)). 그런데 전자문서를 출력한 서면을 송달해야 하는 경우, 피고의 수가 많거나 덧붙인 서류의 분량이 많은 경우, 제출자에게 그 출력서면의 별도 제출을 명할 수 있으므로(민전 12조 1항 단서, 민전규 29조 2항). 이를 제출하도록 한 다음 피고에게 함께 송달하여야 한다.

마. 송달료납부서

소장 제출 시에 법원은 원고에게 소장과 기일통지서 등의 송달료 납부를 명하여야 한다(민소 116조 1항, 민소규 19조 1항 1호). 소를 제기하고자 할 때에는 대법원장이 각 법원별로 지정한 은행(송달료 수납은행)에 일정액의 현금을 납부하고 그 은행으로부터 송달료납부서(송달료예규 별지 제1호 서식)를 교부받은 다음 이를 소장에 붙여서 법원에 제출하여야 한다(송달료규칙 3조 1항, 2항, 송달료예규 8조 2항, 3항). 송달료 수납은행은 ‘송달료규칙의 시행에 따른 업무처리요령’ [별표 2]에 지정되어 있다(송달료예규 9조 1항). 또한 납부인은 신용카드 등에 의한 결제를 수행하는 기관으로서 미리 지정된 송달료대행기관을 통하여 신용카드 등으로 납부할 수 있고, 그 납부서(송달료예규 별지 제1-1호 서식) 출력물을 제공받을 수 있다(송달료규칙 3조의2 1항, 송달료예규 8조의2 1항).

소송서류의 송달방법은 선택적 우편역무 중 ‘특별송달’의 방법에 의한다(우편법 15조 3항, 우편법 시행규칙 25조 1항 6호, 등기취급을 전제로 배달결과를 발송인에게 통지함). 소장 접수 시 사건별 당사자 1인당 송달료 납부기준은 민사합의사건 및 단독사건은 각 15회분, 민사소액사건은 10회분으로 되어 있다(송달료예규 [별표 1] 참조). 송달료 예납에 관한 자세한 내용은 제6장(접수사무) 제2절 참조.

바. 소장의 부분

소가 제기되면 법원은 상대방인 피고에게 소장부분을 송달하여야 하므로 원고는 피고의 수에 상응한 통수의 부분을 덧붙여 제출하여야 한다(민소 178조, 255조, 민소규 48조 1항). 또한 법원은 필요하다고 인정하는 때에는 소송서류를 제출한 사람에게 그 문서의 전자파일을 전자우편이나 그 밖에 적당한 방법(예전대 CD, USB메모리 등)으로 법원에 보내도록 요청할 수 있다(민소규 48조 2항). 이 경우 문서의 원본 또는 그 부분의 제출을 갈음하여 전자파

일의 제출을 명하는 취지는 아니고, 그 소송서류의 원본 등과는 별도로 전자파일을 제출받아 이를 활용함으로써 법원의 업무에 편의를 기하고자 하는 취지이므로, 이에 불응하더라도 제재를 가할 수는 없다.

전자소송의 경우, 앞서 본 바와 같이 소장부분에 관하여 전자적 송달을 하거나(민전 11조), 전자문서를 출력한 서면을 송달(e-Post 송달 포함)하여야 한다(12조).

사. 인지액을 현금 등으로 납부한 경우 영수필확인서

원고는 소제기 시 인지의 첨부을 갈음하여 당해 인지액 상당의 금액을 현금 또는 신용카드 등으로 납부할 수 있고(인지 1조), 소장에 첨부하거나 보정하여야 할 인지액(이미 납부한 인지액이 있는 경우에는 그 합산액)이 1만 원 이상인 때에는 그 인지의 첨부 또는 보정을 갈음하여 인지액 상당의 금액 전액을 현금으로 납부하여야 하며, 인지액이 1만 원 미만인 경우에도 인지의 첨부를 갈음하여 인지액 상당의 금액을 현금으로 납부할 수 있다(인지규 27조). 따라서 원고가 첨부할 인지에 대신하여 인지액을 현금으로 납부한 경우 수납은행으로부터 교부받은 영수필확인서도 소장에 첨부하여야 한다(29조 1항, 2항). 또한 원고는 인지액 상당의 금액을 인지납부대행기관을 통하여 신용카드등으로 납부할 수 있고(28조의2), 그 영수필확인서 출력물을 소장에 첨부하여야 한다(29조 1항, 2항).

제3절 소장의 심사

1. 총 설

소장의 심사는 재판장의 권한이다. 다만 재판장의 과중한 업무 부담의 해소와 참여사무관에 대한 적절한 역할 부여를 통한 재판부 내 업무분담의 효

올화 등의 차원에서, 재판장은 답변서 제출 이후에 비로소 본격적인 기록심사를 하고 그 이전 단계에서는 참여사무관이 사건관리를 주관하는 구도로 운영할 필요성이 있다.

따라서 소장 접수 단계의 소장심사는 접수사무관등과 참여사무관에게 먼저 위임하여 처리하되, 이 단계에서 형식적 사항의 심사는 재판장의 포괄적 위임에 따라 참여사무관이 정형적으로 처리하고 실질적 사항은 재판장에게 개별적으로 보고하여 그 지시에 따라 처리하는 방식을 활용하고, 그 후 재판장의 최초 기록심사시기인 답변서 심사 단계에서 재판장이 소장을 다시 심사하는 방식을 적절히 활용할 필요가 있다. 이와 관련하여, 민사소송규칙 5조 3항은 “법원사무관등은 접수된 소송서류의 보완을 위하여 필요한 사항을 지적하고 보정을 권고할 수 있다.”라고 규정하고, 민사소송법 254조 1항 후단은 “재판장은 법원사무관등으로 하여금 위 보정명령을 하게 할 수 있다.”라고 규정함으로써 위와 같은 업무방식을 뒷받침하고 있다.

2. 접수사무관등에 의한 심사

소장도 소송서류의 일종이므로 소장이 접수된 때에는 앞의 제6장(접수사무)에서 설명한 바에 따라 접수사무관등이 일차적으로 심사를 하게 된다. 특히 접수사무관등은 민사소송법 248조 2항에 따라 인지가 제대로 납부되지 않은 경우 소장의 접수 자체를 보류할 수 있다(또한 반복하여 제기된 소에 대한 각하판결 또는 소장각하명령에 대한 불복절차에 부수하여 제출하는 소송구조 등의 신청서나 항고장 및 재항고장 등에 대해서도 접수를 보류할 수 있다. 대법원 2024. 11. 5. 자 2024카기172 결정). 접수 보류에 관한 구체적인 설명은 제6장(접수사무) 참조.

그러나 소장의 적법 여부를 판단할 정식의 권한을 가지는 것은 어디까지나 재판장 내지 법원이므로, 접수사무관등이 하는 심사는 재판장 내지 법원을 보조하는 의미에서의 사실상의 조사에 그친다. 따라서 접수사무관등은

소장 접수 시 소장 접수 보류 사유의 존부, 필수적 기재사항과 연락처(전화번호·휴대전화번호·팩시밀리번호·전자우편주소 등)의 기재, 기본적 서증 및 그 사본의 첨부 여부에 유의하여 소장을 심사하여야 한다(사건관리예규 3.). 접수 사무관등의 구체적 심사 범위는 아래 표와 같다.

- 소송목적의 값 산정과 첨부 인지액의 적정 여부
 - 소장 접수 보류 사유의 존부(민소 248조 2항, 인지규칙 4조의2)
- 필수적 기재사항의 기재 여부
 - 전화번호·휴대전화번호·팩시밀리번호·전자우편주소 등 연락처 기재 여부
- 관할의 유무
- 필수적 첨부서류의 구비 여부
 - 소송대리인이 있는 때에는 소송대리위임장
 - 당사자가 소송능력이 없는 사람인 때에는 가족관계등록사항증명서
 - 당사자가 법인 또는 법인 아닌 사단이나 재단인 때에는 법인등기사항증명서 또는 규약, 정관
 - 소송목적의 값 산정에 필요한 자료
- 기본적 서증의 첨부 여부
 - 부동산에 관한 사건: 부동산등기사항증명서
 - 친족 상속관계 사건: 가족관계등록사항증명서
 - 어음 수표 사건: 어음 또는 수표 사본
 - 계약관계 사건: 계약서 사본

접수사무관등이 소장을 접수하면서 흠을 발견하였다 하더라도 위와 같은 접수 보류 사유 외에는 정당한 이유 없이 접수를 거부하여서는 안 되며(민소규 5조 1항), 제출자에게 그 흠의 보완을 위하여 필요한 사항을 지적하고 보정을 권고함이 바람직하다(3항). 위와 같은 권고에도 불구하고 제출자가 흠을 보정하지 않는 경우 또는 우편제출이나 당직접수로 인하여 그러한 권고를 하지 못한 경우 등에는 소장 중 그 흠이 있는 위치에 흠의 내용을 간명하게 기술한 부전지(전자소송의 공용부전지 포함)를 붙이고(접수예규 2조 4항, 6조), 접수처리를 한 다음 재판부로 기록을 넘겨야 한다.

아울러 민사소송 등 인지규칙의 개정에 따라 위 심사사항 중 소송인지의

확인이 원칙적으로 접수사무관등의 업무가 되었다는 점을 유의해야 한다(인지규 2조 1항). 따라서 접수사무관등은 소장의 첨부인지액 또는 인지액 상당의 현금납부액을 조사·확인한 후 소장 여백에 고무인을 찍고(2항), 소송목적의 값, 첨부하여야 할 인지액과 첨부한 인지액 등을 적고 날인하며, 첨부된 인지 또는 현금영수필확인서에 소인하여야 한다(3항 본문). 다만 소장등의 접수를 보류하는 경우에는 별지 양식의 고무인 비고란에 민사소송 등 인지법 13조 2항 각 호 중 해당 소장등에 적용되는 금액을 추가로 기재하고, 첨부된 인지는 미달액의 사후 납부에 따라 소장등을 접수할 때 소인한다(3항 단서). 만일 인지액을 초과하여 첨부되거나 현금납부된 경우에는 이를 반환하거나 또는 반환청구포기를 받은 뒤에 첨부된 인지 또는 현금영수필확인서에 소인하여야 한다(5조).

접수사무관등은 원고가 산정·신고한 소송목적의 값 또는 첨부인지액이나 현금납부액이 상당하지 아니하다고 인정한 때에는 원고에게 보정을 권고하거나 재판장의 명을 받아 직접 보정명령을 하고 그 사유를 소장에 날인된 고무인의 ‘비고’란에 적어야 한다(인지규 2조 5항). 소송목적의 값의 산정을 위한 자료의 미비나 그 밖의 사유로 소송목적의 값을 산정하기 어려운 경우에도 같다.

3. 참여사무관등의 심사와 보정권고

가. 심사의 대상

참여사무관등은 사건이 배당되면 바로 접수사무관등이 심사한 형식적 기재사항의 구비 여부 등을 다시 심사한다. 심사한 결과 소장에 흠이 있으면 바로 보정권고를 하거나 참여사무관등 또는 재판장의 명의로 보정명령을 하여야 한다.

참여사무관등은 위와 같은 사항 외에 소장의 청구취지와 청구원인의 부합 여부, 별지도면, 기본적 서증의 첨부 여부 등 실질적인 사항에 대하여도 심사

하여야 한다(사건관리예규 4-2. 가.). 특히 제출된 소장의 기재 상태로는 무변론판결이나 자백간주판결을 할 수 없을 정도의 흠이 있는 때에는 바로 재판장에게 보고함으로써 적시에 보정명령이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

또한 참여사무관등은 ‘적시처리 필요 중요사건’으로 선정할 필요가 있다고 보이는 사건을 발견한 경우에는 곧바로 재판장에게 보고해야 한다(사건관리예규 4-2. 라.). ‘적시처리 필요 중요사건’은 ① 사안의 내용이 정치, 경제, 사회적으로 파장이 크고, 선례로서의 가치가 있는 사건 또는 ② 그 밖에 당사자의 수, 사안의 내용, 국민적 관심의 정도, 처리시한 등에 비추어 적시처리가 필요하다고 인정되는 사건 등을 말한다(적시처리가 필요한 중요사건의 선정 및 배당에 관한 예규 2조).

한편 소장심사 단계에서 재판장과 참여사무관의 적절한 역할분담과 협력이 긴요하므로, 재판부 구성원 전원은 재판부 구성 초기에 소장 및 답변서의 실질적 심사범위, 공시송달처분의 기준, 분쟁성 사건에 대한 사건관리 방향 등 업무처리방향에 대해 협의하여야 하고, 이 경우 사전 업무협의서(전산양식 A2933)를 활용할 수 있다. 또한 재판장과 참여사무관 사이의 정보공유와 의사소통을 위한 수단으로서 재판사무시스템의 ‘업무연락사건’ 메뉴, 전자소송의 기록캐비닛 메뉴 등 협업기능을 적절히 활용할 필요가 있다.

나. 보정권고

소장심사권은 재판장에게 속하므로 소장에 소장각하의 대상이 되는 형식적 기재사항에 관한 흠이 있는 경우나 법률의 규정에 따른 인지가 붙어 있지 아니한 경우 이에 대한 보정명령도 재판장의 권한에 속한다.

한편 참여사무관도 재판장의 위임을 받아 접수된 소장의 심사업무를 처리함이 바람직하며, 소장에 흠이 있는 경우의 보정절차에서도 법에 규정된 위와 같은 원칙적인 방식 외에 참여사무관이 적극적으로 보정권고를 하는 탄력적인 업무처리방식이 필요하다. 민사소송규칙 5조 3항은 “법원사무관등은

접수된 소송서류의 보완을 위하여 필요한 사항을 지적하고 보정을 권고할 수 있다.”라고 규정하여 참여사무관에 의한 보정권고에 명확한 법적 근거를 부여하고 있다.

먼저, 소장각하 등의 불이익을 전제로 하지 않는 경미한 사항의 보정에 관해서는 굳이 재판장 등의 보정명령 형식을 갖추지 않더라도 소장을 심사한 참여사무관이 바로 그 보정을 권고하는 것이 업무처리상 효율적일 뿐 아니라, 소송절차의 신속한 진행에도 도움이 된다. 또 소장에 기본적 서증의 사본이 붙어 있지 아니한 경우에는 재판장이 그 등본 또는 사본을 붙이도록 명할 수 있지만(민소 254조 4항 참조), 이에 불응하더라도 소장 각하의 제재를 가할 수 있는 것은 아니므로 이 경우에도 보정권고를 적절히 활용할 필요가 있다.

한편 인지보정과 같이 소장각하의 제재가 따르게 되는 흠이 있는 경우에는 보정명령을 하는 것이 원칙이지만, 예컨대 원고 측에 변호사가 선임되어 있는 등의 사정으로 보정권고만으로도 바로 그 흠을 보정할 것으로 기대되는 때에는 보정명령을 하는 정식절차를 거칠 필요가 없는 경우도 있을 것이다.

따라서 소장에 경미한 보정사항이 있거나 보정을 하지 아니하더라도 소장 각하를 할 수 없는 경우, 원칙적으로 보정명령의 대상이 되지만 보정권고만으로 바로 보정될 수 있다고 기대되는 특별한 사정이 있는 경우 등에는 참여사무관이 그 이름으로 당사자 또는 대리인에게 보정권고를 하는 방식이 유용하다. 보정권고양식은 [전산양식 A1130]과 같다.

참여사무관의 보정권고는 강제성은 없어 이에 따르지 않았다고 하더라도 제재할 수단이 없으므로, 만일 참여사무관의 보정권고를 따르지 않은 경우 참여사무관은 곧바로 보정명령이 이루어지도록 해야 한다.

[전산양식 A1130] 보정권고(원고용)

○ ○ 지 방 법 원

제○민사부

보정권고

사 건 20 가
 [원고 ○○○ /피고 ○○○]

원 고 ○○○ 귀하

다음 사항을 보정기한까지 보완하여 주시기 바랍니다.

보정기한: 송달된 날로부터 일 이내

보완할 사항

1. 소장에 인용한 서증사본 제출
2. 소가 산정을 위한 자료(개별공시지가 확인원 1통) 제출
3. 대표자의 자격을 증명하는 서면(법인등기부등본) 제출

20 . . .

법원사무관 ○○○ ㉠

※ 문의사항 연락처 : ○○지방법원 민사○단독 법원사무관 ○○○
 전 화 (○○) ○○○-○○○○
 팩 스 (○○) ○○○-○○○○ e-mail :

다. 보정권고 등의 고지

보정권고 또는 뒤에서 설명하는 보정명령을 당사자 또는 대리인에게 고지하는 때에는 우편(전자적 송달 포함)에 의한 송달방식 외에도 전화나 팩시밀

리, 전자우편 등 다양한 수단을 활용할 필요가 있다. 특히 보정권고의 경우에는 소장각하 등의 제재와 무관할 뿐 아니라 신속하고 효율적인 업무처리가 요청되므로 전화 등 간이한 수단을 활용할 필요성이 더욱 절실하다. 다만 전화를 사용하는 방식은 편리하기는 하지만, 당사자 또는 대리인이 전화통지를 받은 사실을 부인하는 경우 나중에 논란의 소지가 될 수 있으며, 기록상으로 보정명령의 흔적을 남기기 어렵다는 등의 단점이 있으므로 운영상 유의할 필요가 있다.

따라서 소장각하의 대상이 되는 사항에 대한 보정명령의 경우, 소장의 실제적 내용에 관한 사항으로서 보정명령의 내용이 원문 그대로 전달되었다는 사실을 기록상 명백히 할 필요가 있는 경우 등에는 우편으로 송달하거나 팩시밀리, 전자우편 등을 활용하는 것이 상당하다.

한편 이러한 보정명령 또는 보정권고를 전화·팩시밀리 또는 전자우편으로 당사자 또는 대리인에게 고지한 때에는 그 보정명령서 또는 보정권고서의 여백에 그 취지를 적어[예: “2025. . . 원고 대리인 ○○○에게 전화로 통지”] 기록에 편철한다(전자소송의 경우 공용부전지를 통해 기록한다). 한편 소장각하를 하여야 할 사항에 대한 보정명령을 하는 경우에는 고지사실의 증거가 문제될 수 있으므로 우편으로 송달하는 방식이 우선적으로 활용된다.

그 밖에도 변호사나 법무법인에 대해서는 전화, 팩시밀리, 전자우편 또는 휴대전화 문자전송을 통한 고지방법을 널리 활용함이 상당하다(민소규 46조). 이러한 방식을 활용하는 경우에는 고지사실이 기록에 분명하게 표시되도록 유의할 필요가 있는바, 팩시밀리로 송달하는 경우에는 영수증을 보정명령과 함께 팩시밀리로 송부하였다가 그 영수증[전산양식 A1405]을 반송받아 기록에 편철하고(송달예규), 전자우편으로 고지하는 경우에는 발신메일에 대한 답신메일로 위와 같은 영수증을 송부받아 기록에 편철하는 방식 등으로 처리한다.

[전산양식 A1405] 영수증(팩스)

영 수 증

사 건 20 가

위 사건에 관하여 다음과 같이 팩스로 송달받았음을 확인합니다.

1. 송달서류

- (1) 피고의 20 . . . 자 준비서면
 (2) 귀원의 20 . . . 자 보정명령

2. 송달수령일 : 20 . . .

20 . . .

원고 소송대리인 ○○○ ㉠

주 : 송달받은 즉시 위 영수증에 기명날인하여 ○○지방법원 제○민사부 팩스
 (○○) ○○○ - ○○○○ 로 다시 전송하여 주시기 바랍니다.

※ 문의사항 연락처 : ○○지방법원 제○민사부 법원사무관 ○○○

전화 (○○) ○○○ - ○○○○

팩스 (○○) ○○○ - ○○○○

e-mail : @scourt.go.kr

4. 재판장에 의한 심사와 보정명령

가. 심사의 대상

소장심사권은 궁극적으로 재판장에게 속한다(민소 254조 1항, 2항). 따라서 접수사무관등이나 참여사무관의 보정권고에도 불구하고 소장에 소장각하의 대상이 되는 형식적 기재사항에 관한 흠이 보정되지 않았거나 또는 법률의 규정에 따른 인지가 붙어 있지 아니한 경우에는, 곧바로 보정명령을 하도록 하여야 한다.

소장의 인지확인인 접수담당 직원이 하지만(인지규 2조 1항), 소송목적의 값의 산정을 위한 자료의 미비, 그 밖의 사유로 인하여 소송목적의 값을 산정하기 어려운 때에는 재판장이 소송목적의 값을 인정하며, 이 경우 재판장은 소장 등의 소송목적의 값 표시 기재 오른쪽에 소송목적의 값 인정 양식 고무인을 찍고 해당사항을 기입한 후 날인하여야 한다(3조).

재판장이 소장심사 단계에서 소가 소송요건을 구비한 적법한 것인가 또는 청구가 이유 있는가 등의 실질적 심사를 할 수는 없다. 이러한 사항은 소장의 송달에 의하여 소송계속이 이루어진 이후에 법원에 의하여 판결로써 가려져야 할 사항이기 때문이다. 다만 재판장이 소장의 형식적 사항에 대한 심사(이는 재판장 단독의 권한임)와 함께 그 밖의 실질적 사항(법원에 의한 심사대상에 속하는 사항)에 대하여 법원의 한 구성원으로서의 심사를 행하는 것은 무방하다.

이러한 소장심사 우선의 원칙을 예외 없이 관철시킬 것인가에 대하여는 이견이 있다. 예컨대 소장에 첨부된 인지가 부족한데 더욱이 보정불능인 소송요건의 흠이 있는 경우(소제기기간 경과 후의 소제기나 변론종결 후의 반소 제기 등)까지 인지 보정명령을 하여 인지를 더 붙이게 한 뒤 소를 각하하는 것은 가혹하기 때문에, 이러한 경우에는 순서를 바꾸어 소장심사를 생략하고 곧바로 소송요건의 흠을 이유로 소를 각하하는 것이 옳다는 견해도 있다.

나. 소장의 충실화를 위한 조치

민사소송법은 집중심리방식을 강화하기 위하여, 변론 없이 판결하는 경우를 제외하고는 특별한 사정이 없는 한 답변서가 제출되면 바로 변론기일을 지정하되(민소 258조 1항), 당사자의 주장과 증거의 정리가 완료된 후에 증인 신문과 당사자신문을 집중적으로 실시하도록 규정하고 있으며(293조), 원고의 청구를 다투는 피고에게는 답변서 제출의무를 부과하고 있다(256조 1항).

따라서 법원으로서의 피고로부터 쟁점에 대한 실질적 답변을 유도하기 위하여 소장 접수 시부터 구체적인 사건의 내용이나 당사자의 증명 정도를 파악할 필요가 있다.

이를 위하여 민사소송법은 재판장이 소장을 심사하면서 필요하다고 인정하는 경우에는 원고에게 청구하는 이유에 대응하는 증거방법을 구체적으로 적어 내도록 명할 수 있으며, 원고가 소장에 인용한 서증의 등본 또는 사본을 붙이지 아니한 경우에는 이를 제출하도록 명할 수 있도록 하였다(민소 254조 4항). 그 밖에도 재판장은 심리를 개시하기 전에 청구원인의 요건사실을 염두에 두면서 소장의 기재를 검토하여 청구취지나 청구원인이 불분명하거나 미비점이 있는 경우에는 적극적으로 석명권을 행사하여 원고에게 그 주장을 정정 또는 보충하도록 촉구함이 바람직하다.

재판장은 소장을 심사하는 단계에서부터 이와 같이 원고에게 구체적인 주장 및 증거방법을 표시하도록 보정명령을 함으로써 집중심리방식이 활성화 되도록 하여야 할 것이다. 다만 재판장의 위와 같은 실질적인 사항에 대한 보정명령은 아래에서 설명하는 형식적 기재사항이나 인지에 관한 흠에 대한 보정명령과는 달리, 그 명령에 따르지 않았다고 하더라도 소장을 각하할 수 있는 것은 아닌 점을 주의할 필요가 있다.

다. 재판장 등의 보정명령

앞에서 설명한 형식적 사항의 흠이 있는 경우, 즉 필수적 기재사항이 누락되었거나 법정의 인지가 첨부되지 않은 경우에는 재판장은 지체 없이 원고에게 상당한 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다(민소 254조 1항 전단, 인지규 4조 전단). 또 주소 기재가 없거나 불분명하여 소장을 피고에게 송달할 수 없음이 소장 자체에 의하여 명백한 경우에도 마찬가지로 그 보정을 명하여야 한다(민소 255조 2항).

다만 신속하고 충실한 본안심리를 위해 ‘참여사무관등의 절차참여’가 갈

수록 중요해지고 있고, 2014년 개정을 통해 민사소송법에도 법원사무관등의 보정명령권이 도입되었으므로(민소 254조 1항 후단. 2023. 8. 31. 개정된 인지규 4조 후단도 마찬가지이다), 위와 같은 형식적 사항 흠결의 경우 참여사무관등이 사전 심사 단계에서 적극적으로 보정명령을 발령하고 재판장이 각 하명명 발령 여부를 검토하는 단계에서 재차 보정할 기회를 부여할 것인지를 검토하는 것으로 재판부 내에서 협의할 필요가 있다.

한편 재판장은 소장심사 단계에서 필요하다고 인정하는 경우에는 원고에게 청구하는 이유에 대응하는 증거방법을 구체적으로 적어 내도록 명할 수 있고, 원고가 소장에 인용한 서증의 등본 또는 사본을 붙이지 아니한 경우에는 이를 제출하도록 명할 수 있다(민소 254조 4항).

보정명령의 고지 또는 송달은 앞에서 설명한 보정권고 등의 고지 요령에 따라 처리하면 될 것이다. 나아가 보정명령에는 시기적인 제한이 없으므로, 변론이 개시된 뒤라도 소장에 흠이 발견되면 그 보정을 명할 수 있다(대법원 1969. 12. 26. 선고 67다1744 판결). 그러나 원고가 당사자를 정확히 표시하지 못하고 당사자능력이나 당사자적격이 없는 자를 당사자로 잘못 표시하였다면 법원은 당사자를 소장의 표시만에 의할 것이 아니고 청구의 내용과 원인사실을 종합하여 확정된 후 확정된 당사자가 소장의 표시와 다르거나 소장의 표시만으로 분명하지 아니한 때에는 당사자의 표시를 정정보정시키는 조치를 취하여야 하고 이러한 조치를 취함이 없이 단지 원고에게 막연히 보정명령만을 명한 후 소를 각하하는 것은 위법하다(대법원 2013. 8. 22. 선고 2012다68279 판결).

보정명령은 보정할 사항, 예컨대 흠의 내용, 부족인지의 액수를 명시하여야 한다. 보정명령서에 보정기간이 공란으로 되어 있어 보정기한이 지정된 바 없다면 이는 적법한 보정명령이라고 볼 수 없다(대법원 1980. 6. 12. 자 80마160 결정). 실무상 보정기간은 통상 5일 또는 7일로 하고 있다. 보정기간은 불변기간이 아니므로(대법원 1978. 9. 5. 자 78마233 결정), 원고가 보정기

간 내에 보정이 어려우면 그 연장신청을 할 수 있으나 이에 대한 허부는 재판장의 재량에 속한다(대법원 1969. 12. 19. 자 69마500 결정).

구치소 등에 수감 중이거나 외국에 거주하는 당사자에 대하여 보정명령을 하는 경우에는 보정기간을 위와 같이 5일 또는 7일로 일률적으로 정할 것이 아니라 당사자가 그 명령을 송달받고 이를 보정하는 데에 충분한 기간이 되도록 정하여야 한다(재일 88-2 보정명령을 함에 있어서 보정기간의 적정).

재판장 등의 보정명령에 대하여는 이의신청이나 항고 등(특별항고 포함)으로 독립하여 불복할 수 없다(대법원 2015. 3. 3. 자 2014그352 결정). 보정명령 미이행에 따른 소장각하명령 등에 관하여 즉시항고 등으로 다룰 수 있을 뿐이다. 따라서 재판장의 인지보정명령에 대하여 이의신청 등 불복이 있더라도 이는 소송법상의 권리에 터 잡은 신청으로 볼 수 없고 법원의 직권에 의한 시정을 촉구하는 것에 불과하다 할 것이어서 소장각하명령에 이에 대한 판단을 명시할 필요도 없다(대법원 1993. 8. 19. 자 93재수13 결정).

일반적인 보정명령 양식은 [전산양식 A1131]과 같고, 인지액·송달료에 대한 보정명령 양식은 [전산양식 A1132]와 같으며, 법원사무관등의 보정명령 양식은 [전산양식 A1131-1], [전산양식 A1132-3] 등과 같다[법원사무관등의 보정명령에는 '유의사항'란에 "이 보정명령은 재판장의 명에 따른 것으로 위 기한 안에 보정하지 아니하면 소장이 각하될 수 있습니다(민사소송법 제254조 제2항)."라는 문구를 기재한다].

[전산양식 A1131] 보정명령

○ ○ 법 원
보 정 명 령

사 건 20 가
[원고: /피고:]

원고(대리인) 귀하

이 명령을 송달받은 날부터 일 안에 다음 사항을 보정하시기 바랍니다.

보정할 사항

- 1.
- 2.

20 . . .

판 사 (인)

◇ 유의사항 ◇

1. 이 사건에 관하여 제출하는 서면에는 사건번호를 기재하시기 바랍니다.
2. 위 기한 안에 보정하지 아니하면 소장이 각하될 수 있습니다(민사소송법 제254조 제2항).

※ 문의사항 연락처 : ○○지방법원 제○단독 법원주사 ○○○
전화: ○○○-○○○○
팩스: ○○○-○○○○ e-mail:
주소:

민소 254①

[전산양식 A1132] 보정명령(인지대, 송달료)

○ ○ 법 원
보 정 명 령사 건 20 가
원 고
피 고

원고 (귀하)

원고는 이 명령의 보정기한까지 다음 흠결사항을 보정하시기 바랍니다.
보정기한: 송달된 날로부터 7일 이내

흠결사항

인지대 원
송달료 원

20

판 사 (인)

- ※ 이 명령에 응하지 않을 경우에는 민사소송법 제254조 제2항에 의하여 소장이 각하될 수 있습니다.
- ※ 인지액을 납부한 때에는 수납은행 등에서 받은 “영수필확인서”를, 송달료를 납부한 때에는 수납은행 등에서 받은 “송달료납부서”를, 지체 없이 관할법원에 제출하여야 합니다.

[전산양식 A1131-1] [참]보정명령

○ ○ 지 방 법 원
보 정 명 령

사 건 20 가
[원고 : /피고 :]

원고(대리인) 귀하
이 명령을 송달받은 날부터 일 안에 다음 사항을 보정하시기 바랍니다.

보정할 사항

- 1.
- 2.

20 . . .

법원사무관 ①

◇ 유 의 사 항 ◇

- 1. 이 사건에 관하여 제출하는 서면에는 사건번호를 기재하시기 바랍니다.
- 2. 이 보정명령은 재판장의 명에 따른 것으로 위 기한 안에 보정하지 아니하면 소장이 각하될 수 있습니다(민사소송법 제254조 제2항).

※ 문의사항 연락처 : ○○지방법원 제○단독 법원주사 ○○○
전화(○○) ○○○ - ○○○○
팩스(○○) ○○○ - ○○○○ e-mail : @scourt.go.kr

[전산양식 A1132-3] [참]보정명령(인지대/송달료)

○ ○ 법 원

보 정 명 령

사 전 20 가단1000 대여금
[원고: /피고:]

원고(대리인) (귀하)

이 명령이 송달된 날부터 일 안에 다음 사항을 보정하시기 바랍니다.

다 음

1. 인지대 원
2. 송달료 원 (송달료 납부방법: 예납, 추납)

20 . . .

법원사무관 (인)

※ 이 보정명령은 재판장의 명에 따른 것으로 명령에 응하지 않을 경우에는 민사소송법 제 254조 제2항에 의하여 소장이 각하될 수 있습니다.

※ 인지액을 납부한 때에는 수납은행 등에서 받은 “영수필확인서”를, 송달료를 납부한 때에는 수납은행 등에서 받은 “송달료납부서”를 지체 없이 관할법원에 제출하여야 합니다.

라. 소장각하명령

(1) 소장각하명령의 성격

원고가 보정명령에서 정해진 기간 내에 소장의 흠을 보정하지 아니할 때에는 재판장은 명령으로 소장을 각하한다(민소 254조 2항). 그러나 기간 경과 후라도 각하명령 전에 흠이 보정되면 각하명령을 할 수 없다.

소장각하명령은 소장이 부적법하다 하여 수리할 수 없다는 취지의 재판이므로 소장을 수리한 후 소가 부적법하다 하여 각하하는 소각하판결과는 다르다. 피고에게 소장을 송달한 후에는 소송계속이 이루어져 당사자 쌍방 대

립관계의 절차가 개시되기 때문에 명령에 의한 소장각하를 할 수 없고, 종국 판결로 소를 각하하여야 한다. 일단 소장이 송달되면 소송계속의 효과로 원고·피고 쌍방이 관여하는 소송절차로 발전하기 때문에 그때는 소장각하명령의 고지만으로 소송을 종료시킬 수 없다.

또한 소장에 일응 청구의 특징이 가능한 정도로 청구취지 및 원인이 기재되어 있다면 비록 그것이 불명확하여 파악하기 어렵다 하더라도 그 후는 석명권 행사의 문제이므로, 소장각하의 대상이 아니다(대법원 2004. 11. 24. 자 2004무54 결정).

이 소장각하명령은 원고에게만 고지하는데, 보통은 명령의 정본을 송달하는 방법에 의하여 고지한다. 소장각하명령의 양식은 [전산양식 A1135]와 같다.

[전산양식 A1135] 소장각하명령

○ ○ 법 원 명 령

사 건 20○○가단1000 대여금
원 고
피 고

주 문

이 사건 소장을 각하한다.

이 유

이 사건 소장에 관하여 원고에게 피고 의 송달 가능한 주소를 보정할 것을 명하였으나 원고가 위 명령에서 정한 기간 이내에 이를 이행하지 아니하므로 민사소송법 제255조 제2항, 제254조 제2항에 따라 주문과 같이 명령한다.

20 . . .

판 사 ㉠

(2) 주소보정명령 불이행으로 인한 소장각하명령

재판장이 원고에게 주소보정명령을 발한 경우에 원고가 정해진 기간이 지나도록 보정을 하지 않으면 재판장이 소장각하명령을 하여야 한다(민소 255조 2항, 254조 2항. 항소장의 송달불능과 관련된 항소장 각하명령에 대하여는 대법원 2021. 4. 22. 자 2017마6438 전원합의체 결정). 보정기간 내에 보정을 하지 못한 것이 주소를 알 길이 없었던 탓이라 하여도 소장각하명령이 위법한 것은 아니다(대법원 1968. 9. 24. 자 68마1029 결정). 또한 주소보정명령에 대하여 원고가 아무런 소명 없이 다만 소재불명이란 이유로 공시송달을 신청하였다면 이를 보정하였다고 할 수 없다. 그러나 일단 소명자료를 첨부하여 공시송달신청을 한 경우 그에 대한 허부재판을 도외시한 채 주소보정 흠을 이유로 소장각하명령을 하는 것은 위법하다(대법원 2003. 12. 12. 자 2003마1694 결정).

한편 법인에 대한 소송 서류는 그 대표자의 주소·거소에 송달하는 것이 원칙이고(대법원 1976. 4. 27. 선고 76다170 판결, 대법원 2003. 4. 25. 선고 2000다60197 판결) 법인의 영업소나 사무소에서도 할 수 있다(민소 64조, 183조 1항 단서). 따라서 법인인 피고의 대표자 주소지가 아닌 소장에 기재된 피고의 주소지로 발송하였으나 이사불명으로 송달불능된 경우에는, 원칙으로 되돌아가 소재지 시에 제출된 법인등기사항증명서 등에 나타나 있는 피고의 대표자 주소지로 소장부분 등을 송달하여 보고, 그곳으로도 송달되지 않을 때에 주소보정을 명하여야 할 것이므로, 1심 재판장이 단지 법인의 주소지로 소장부분 등을 송달하였으나 송달불능되었다는 이유만으로 그 주소보정을 명한 것은 잘못이고, 결국 피고가 주소보정을 하지 않았다는 이유로 한 소장각하명령도 위법하다(송달예규 8조, 대법원 1997. 5. 19. 자 97마600 결정).

또한 항소심에서 항소장 부분을 송달할 수 없는 경우 항소심재판장은 민사소송법 402조 1항, 2항에 따라 항소인에게 ‘상당한 기간’을 정하여 그 기간 이내에 피항소인의 주소를 보정하도록 명하여야 하고, 항소인이 그 기간 이내에 피항소인의 주소를 보정하지 아니한 때에는 명령으로 항소장을 각하

하여야 한다. 여기서 ‘상당한 기간’이란 항소인이 상대방의 주소를 알아내어 보정하거나 또는 상대방의 주소를 조사하여 보았으나 알 수 없어서 공시송달을 신청하는 데 필요한 적절하고도 합당한 기간을 가리키는 것으로, 주소 보정명령이 항소인에게 받아들이지 못할 정도의 과중한 부담이 되어서는 안 된다. 따라서 항소심재판장이 상당한 기간을 주지 아니하고 주소보정을 명하고 이와 같은 상당한 기간이 지나지 아니하였는데도 항소장을 각하하는 것은 위법하다고 보아야 할 것이다(대법원 2025. 8. 14. 자 2024마8774 결정).

그 밖에 주소보정과 관련한 자세한 설명은 제4절 참조.

(3) 인지보정명령 불이행으로 인한 소장각하명령

부족인지의 보정명령을 받고 소송관계인이 민사소송 등 인지규칙에 따라 수납은행에 인지액을 현금 또는 신용카드 등으로 납부했다면 송달료 수납은행에 현금을 납부한 때 또는 인지납부대행기관의 승인을 받은 때에 인지보정의 효과가 발생되고, 이 납부에 따라 발부받은 영수필확인서를 보정서 등 소송서류에 첨부하여 접수사무관등에게 제출하고 또 그 접수사무관등이 이를 소장 등 소송서류에 첨부하여 소인하는 등 행위는 소송기록상 그 납부 사실을 확인하게 하기 위한 절차에 불과하다. 따라서 소송관계인이 수납은행에 인지액을 납부하기만 하고 그 수납은행으로부터 받은 영수필확인서를 보정기간 내에 법원에 제출하지 아니하였다고 하여, 제1심 재판장이 소장각하명령을 내리는 것은 잘못이다(대법원 2000. 5. 22. 자 2000마2434 결정). 따라서 인지보정명령 불이행을 이유로 소장각하명령을 하는 때에는 반드시 그 직전에 인지의 보정(납부) 여부를 확인할 필요가 있다.

민사소송법에 의한 소송구조신청이 있는 경우는 민사소송 등 인지법 1조 본문의 ‘다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우’에 해당되므로 그에 대한 기각결정이 확정될 때까지는 인지첨부의무의 발생이 저지되어 그 의무의 이행이 정지 또는 유예된다 할 것이어서, 재판장은 소장 등에 인지가 첨부되어 있지 아니함을 이유로 인지보정명령을 발하거나 같은 이유로 소장 등을 각

하할 수 없다(대법원 2002. 9. 27. 자 2002마3411 결정). 다만 그 경우 소송구조신청이 있었다고 하여 종전에 이루어진 인지보정명령의 효력이 상실되는 것은 아니므로, 종전의 인지보정명령에 따른 보정기간 중에 제기된 소송구조신청에 대하여 기각결정이 확정되면 재판장으로서 다시 인지보정명령을 할 필요는 없지만 종전의 인지보정명령에 따른 보정기간 전체가 다시 진행되어 그 기간이 경과된 때에 비로소 소장 등에 대한 각하명령을 할 수 있다(대법원 2018. 5. 4. 자 2018무513 결정). 또한 처음 소송구조신청에 대한 기각결정이 확정된 후 재차 소송구조신청이 있었다고 하더라도 이 구조신청이 이유 있어 받아들여졌다면 모르되 그렇지 아니하는 한 다음의 구조신청에 대한 기각결정의 확정 여부와는 상관없이 소장을 각하할 수 있다(대법원 1993. 1. 25. 자 92마1134 결정, 대법원 2008. 7. 1. 자 2008마547 결정).

제소전화해 또는 조정이 성립되지 아니하여 소송으로 이행된 경우에 원고가 보정명령을 어기고 부족인지를 추가첨부하지 아니할 경우에는 실무상 소장에 해당하는 지급명령신청서나 화해신청서 혹은 조정신청서를 재판장의 명령으로 각하하는 방법으로 처리하는 것이 일반적이다.

그 밖에 자세한 설명은 제6장(접수사무) 제3절 참조.

(4) 송달료예납명령 불이행으로 인한 소장각하명령

만약 원고가 송달료를 예납하지 않은 경우(다시 말하면 접수사무관등의 송달료 납부 안내에도 불구하고 소장에 송달료납부서가 첨부되지 않은 경우)에는 송달료의 예납을 명하여야 한다.

원고가 예납명령에 응하지 아니할 경우에는, 일단 소송계속이 이루어진 후 개개의 절차진행에 필요한 비용이 예납되지 않은 경우와 달리, 소송계속 자체를 위한 최초의 소송절차인 소장의 송달에 필요한 비용이 예납되지 않은 것으로서 이를 소장의 송달불능의 한 형태로 보아 소장각하명령을 할 수 있다. 따라서 위 송달료의 예납명령 자체를 보정명령의 형식으로써 발령해야 할 것이다(전산양식 A1132). 판례도 항소장의 송달에 필요한 비용이 예납

되지 않은 경우에는 이를 항소장의 송달불능의 상태로 보아 항소심 재판장은 상당한 기간을 정하여 그 기간 내에 그 흠을 보정할 것을 명할 수 있고, 그 기간 내에 보정이 없는 경우에는 항소장각하명령을 할 수가 있으며, 항소심 재판장이 그 송달비용을 국고에서 대납지급받아 지출하지 아니하고 항소장각하명령을 하였다고 하여 위법하다고 할 수 없다고 한다(대법원 1995. 10. 5. 자 94마2452 결정).

송달료가 전혀 예납되지 아니하여 송달료 예납을 명하는 보정명령 자체를 송달할 비용도 없고 또한 소장에 팩시밀리번호나 전자우편주소의 기재가 없어 이를 이용한 보정명령도 불가능한 경우에는, 민사소송규칙 20조에 의하여 소송비용을 국고에서 대납받아 보정명령을 송달한 다음 보정기간 내에 보정이 없는 경우에 소장각하명령을 한다.

(5) 소장각하명령에 대한 즉시항고

소장에 관한 재판장의 보정명령에 대하여는 독립하여 이의신청이나 항고를 할 수 없으며, 보정명령 불이행을 이유로 한 소장각하명령에 대하여는 즉시항고에 의하여만 불복할 수 있다(민소 254조 3항, 대법원 1995. 6. 30. 자 94다39086 결정, 대법원 2015. 3. 3. 자 2014그352 결정).

소장의 적법 여부는 각하명령을 발한 때를 기준으로 판단하여야 한다. 여기서 명령을 발한 때는 명령이 적법하게 성립한 때를 말하고, 전자문서로 작성된 결정이나 명령은 법관이 사법전자서명을 완료한 때 성립한다. 결정이나 명령이 일단 성립하면 취소 또는 변경을 허용하는 별도의 규정이 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 법원 스스로 이를 취소·변경할 수 없는 구속력을 가지게 된다(대법원 2025. 7. 24. 자 2021마6542 전원합의체 결정). 따라서 즉시항고를 제기하고 동시에 부족한 인지를 추가로 붙였다 하여도 그 흠은 보정되지 아니한다(대법원 1996. 1. 12. 자 95두61 결정, 대법원 2013. 7. 31. 자 2013마670 결정). 또한 재판장이 소장상의 흠을 이유로 소장각하명령을 한 경우 원고가 즉시항고와 더불어 그 흠을 보정하였을 경우라도 소장각하

명령을 민사소송법 446조에 의한 경정결정에 의하여 취소할 수 없다(대법원 1968. 7. 29. 자 68사49 전원합의체 결정). 심지어 각하명령과 같은 날 미보정 인지가 보정되었더라도 그 보정시점이 각하명령 성립 후라면 그 각하명령은 위법한 것이 아니고 재도의 고안으로 취소될 수도 없다(대법원 2025. 7. 24. 자 2021마6542 전원합의체 결정).

마. 소송대리허가신청의 처리

실무상 원고가 금융기관인 경우 등에는 소장과 함께 소송대리허가신청서를 제출하는 경우가 자주 생기고 있다. 이와 같은 경우에 허부의 결정을 하지 아니한 채 오래 방치하는 것은 대리권 유무가 불투명한 상태에서 절차를 진행하는 결과가 되어 바람직하지 아니하다. 다만 이 경우에도 소장은 원고의 대표이사나 지배인 등의 이름으로 제출하는 것이 보통이므로 특별한 사정이 없는 한 소장 접수 단계에서 그 허가 여부를 바로 결정할 필요는 없고, 답변서 심사 단계 등 재판장이 기록을 심사하는 기회에 그 허부를 함께 결정하는 방식으로 운영하는 것이 효율적일 것이다.

소송대리허가신청에 대한 허부결정은 별도로 결정문을 작성할 필요는 없고 허가신청서의 ‘허부’란에 날인을 하고 그 밑에 결정일자를 적는 방식을 활용하면 충분하다.

소송대리허가신청을 불허한 때에는 신청인에게 전화로 고지하거나 허부의 날인이 되어 있는 신청서의 사본을 팩시밀리로 보내는 등 적당한 방법으로 고지하고, 신청서에 그 취지를 표시한다. 상대방에게는 별도로 고지할 필요가 없다.

반면 소송대리 허가결정을 한 경우에는 이를 일일이 고지하도록 할 경우 업무가 과중해질 뿐 아니라, 허가신청이 주로 문제 되는 금융기관사건의 경우에 준비서면이나 증거신청서는 보통 원고의 대표이사나 지배인 명의로 제출되는 것이 보통이기 때문에 굳이 사전에 허가사실을 고지할 필요도 없다.

따라서 이와 같은 경우에는 별도의 고지절차를 거칠 필요 없이 변론기일에 이를 고지하고 그 취지를 조서에 적는 방식[예: “○○○를 원고의 소송대리인으로 허가”]으로 운영하는 것이 실무상 효율적이다.

그 밖에 자세한 설명은 제12장(소송상의 대리인) 제3절 참조.

5. 전자소송에서의 소장 심사

‘민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률’ 시행에 따라 전자문서로 제출되는 소장은 제출 시에 법원의 접수담당자를 거치지 않고 전자소송 시스템에 전자적으로 접수되어 기본적 기재사항이나 첨부서류 등의 오류에 대한 접수창구에서의 최초 보정기회가 없으므로 흠이 발생할 가능성이 크고, 따라서 소장 심사의 필요성도 더욱 높다. 접수사무관등은 전자적으로 제출된 소장에 대하여 관할 위반 여부, 정확한 인지의 납입 여부, 당사자의 표시, 법정대리인이나 대표자의 기재 여부와 대표자, 관리인의 자격을 증명하는 서면의 첨부 여부, 기본적 서증의 첨부 여부 등의 사항을 심사한 후 그 심사결과를 전자소송시스템의 ‘소장심사체크리스트(SJJ010_42)’에 전자적으로 표시하여 담당재판부에 인계한다(민전예규 18조 1항). 특히 사건번호가 시스템에 의하여 자동으로 부여되기 때문에 사건번호의 오류 가능성이 큰데, 사건부호(‘가합’, ‘가단’, ‘가소’ 등)가 잘못 부여된 경우 접수사무관등은 이러한 취지를 공용부전지에 입력하고 일단 배당이 실시된 후에 법원사무관등이 재배당조치를 취한다(2항).

사건이 배당되면 법원사무관등은 접수사무관등이 심사한 사항을 재심사하고, 그 외에 청구취지의 흠결 여부, 별지 목록·도면의 누락 여부, 청구취지와 청구원인의 부합 여부, 인용된 서증과 첨부서류의 첨부 여부 등을 심사하여 심사결과를 ‘소장심사체크리스트(SJJ010_42)’에 전자적으로 표시하고, 흠결사항이 있는 경우 제출자에게 보정을 권고한다.

한편 전자적으로 제출된 소장에서는 서증 첨부에 오류가 발생하는 사례가

빈번하므로, 법원사무관등은 서증명과 그에 대한 서증이 제대로 연결되어 있는지, 서증번호가 적절하게 기재되었는지, 중복된 서증이 제출되었는지 등을 점검하고 오류가 있으면 서증수정 작업을 실시한다. 다만 사건의 특성 및 수정대상인 서증의 분량 등 여러 가지 사정으로 인하여 서증수정 작업에 상당한 노력이 필요한 경우에는 제출자에게 다시 방식에 맞게 제출하도록 보정을 권고할 수 있다(민전예규 18조 5항).

제4절 소장부분의 송달

1. 총 설

가. 송달의 시기

법원은 소장이나 소장에 준하는 서면이 접수되면 특별한 사정이 없는 한 바로 피고에게 소장 등의 부분을 송달하여야 한다(민소 255조 1항, 민소규 64조 1항). 반소와 중간확인의 소의 소장이나, 필수적 공동소송인의 추가, 참가, 피고의 경정, 청구의 변경 신청서 등 소장에 준하는 서면이 제출된 때에도 같은 방법으로 그 부분을 송달하여야 한다(민소규 64조 2항).

그러므로 참여사무관은 접수된 소장이 인계되면 신속하게 소장심사를 하여 흠이 없는 것으로 인정되면 바로 피고에게 소장부분을 송달하여야 한다.

나. 소장에 흠이 있는 경우의 처리

소장에 흠이 있는 경우에 이에 대하여 먼저 보정명령이나 보정권고를 거쳐 보정이 된 후에 소장부분을 피고에게 송달할 것인지, 아니면 바로 소장부분을 피고에게 송달하고 나서 보정명령을 할 것인지 문제 된다.

우선, 소장의 형식적 사항에 흠이 있어 이를 보정하지 아니하면 소장각하의 대상이 되는 경우에는 흠을 보정시킨 다음 소장부분을 피고에게 송달하

여야 한다. 이에 반하여 소장각하의 대상이 되지 아니하는 흠이 있는 때에는, 청구취지와 청구원인이 모순되어 무변론판결을 선고할 수 없는 경우 등의 특별한 사정이 없는 한, 피고에게 바로 소장부분을 송달한 후 원고에게 보정명령 또는 보정권고 등을 하여 흠을 보정하도록 함이 좋다.

2. 송달할 서류

가. 소장부분

소장의 경우에는 원고가 제출한 부분을 송달한다. 원고가 피고에게 송달할 소장부분을 제출하지 않은 경우에는 민사소송규칙 48조를 근거로 보정권고를 하여 부분을 제출받아 송달하여야 할 것이다.

소장부분을 송달하면서 그 부분에 사건번호, 담당재판부의 표시가 없으면 당사자가 법원에 답변서 등을 제출하면서 사건번호 등을 알기 위하여 문의하는 불편이 생긴다. 그러므로 소장을 상대방 당사자에게 송달하는 경우에는 주소안내문[전산양식 A1403]을 출력하여 함께 송달하되, 그 주소안내문에 표시된 사건번호와 담당재판부 및 그 연락처가 정확한지 여부를 확인한 후 송달하여야 한다(송달예규 6조 1항).

전자소송에서는, ① 전자소송에 동의한 자 등(국가, 지방자치단체 등 포함)에 대한 전자적 송달(송달할 전자문서를 전산정보처리시스템에 등재하고 그 사실을 송달받을 자에게 전자우편 등을 통해 전자적으로 통지하는 방식으로 실시한다. 민전 11조 1항, 3항)과 ② 그 외의 자에 대한 전자문서를 출력한 서면의 우편 송달(12조)로 소장부분을 송달하게 된다. 따라서 법원사무관 등은 해당 사건의 소장부분 송달이 위 ① 전자적 송달로 가능한지 여부를 먼저 심사할 필요가 있다. 또한 법원사무관 등은 위 ② 우편 송달을 위해 우편법 15조 3항, 우편법 시행규칙 25조 1항 12호에서 정한 전자우편을 이용('e-Post 송달방식'으로, 법원에서 우정사업본부에 전자문서를 전송하고 우정사업본부에서 전자문서를 출력하여 수취인에게 배달하는 방식)할 수 있다(민전규 29조 4항). 그리고

② 우편 송달의 경우 피고의 수가 많거나 덧붙인 서류의 분량이 많은 경우, 제출자에게 그 출력서면의 별도 제출을 명한 다음(민전 12조 1항 단서, 민전규 29조 2항). 이를 제출받아 피고에게 함께 송달할 수 있다.

법원과 참여사무관 등은 재판사무시스템을 통하여 소장부분을 발송하지 아니한 사건이 있는지 여부를 주기적으로 점검함으로써 사건이 방치되지 않도록 관심을 기울일 필요가 있다.

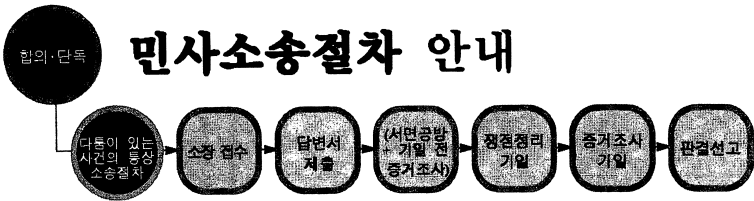
나. 소송절차안내 양식 등

소장부분을 송달할 때에는 소송절차 안내서(합의·단독)[전산양식 A1176]와 같은 양식으로 인쇄된 소송절차 안내 서면을 함께 송달하여야 한다. 다만 각급 법원은 당해 법원의 실정, 사건의 특수성 등을 감안하여 위 소송절차안내서 양식을 변형하여 사용할 수 있다(소송절차 안내서 양식에 관한 예규).

민사소송법은 피고에게 소장부분을 송달할 때 소장부분을 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출하여야 한다는 취지를 알리도록 규정하고 있고(민소 256조 2항), 피고가 위 기한 내에 답변서를 제출하지 아니하면 법원은 변론 없이 판결을 선고할 수 있으므로(257조), 피고에 대한 소송절차안내서의 송달은 법정절차의 준수 및 무변론판결 선고의 요건이라는 중요한 의미를 갖는다.

한편 참여사무관은 재판장의 요구가 있거나 필요하다고 판단하는 경우 소장부분과 함께 답변서 요약표[전산양식 A1510]를 피고에게 송달하여 그 제출을 요구할 수 있다(사건관리예규 5.). 답변서요약표는 사건관리보조자로서의 참여사무관이 서면에 의한 변론준비절차를 효율적으로 관리하기 위한 것이다.

[전산양식 A1176] 소송절차 안내서(합의·단독)



01 재판준비

조사의무 소송기록에 관한 자료	사실관계에 관한 자료를 제출할 책임은 당사자에게 있으므로, 당사자는 주장과 입증에 충실히 할 수 있도록 사건에 사실과 증거를 충실히 조사하여야 합니다.
소송대리 소송기록에 관한 자료	원칙적으로 소송취임에 따른 소송대리인은 변호사 또는 법무법인 등이어야 합니다. 다만, 단독판사가 심리하는 사건 중 수표금·약속어음금, 은행 등이 원고인 대어금·구상금·보증금, 자동차손해배상보장법에 따른 손해배상 등, 소송액의 값이 1억 원 이하인 청구 사건 등에서는 배우자 또는 4촌 안의 친족, 고용 등 계약관계를 맺고 그 사건에 관한 통상사무를 처리·보조하는 사람 등을 소송대리인으로 허가하여 달라는 신청(소송 대리허가신청 및 소송위임장 제출)을 할 수 있습니다.
소송구조 소송기록에 관한 자료	소송비용을 지불할 자금능력이 부족한 사람은 변호사 비용 등 재판비용의 납입을 유예하여 달라고 신청할 수 있고, 법원은 자금능력과 패소가능성 요건을 심사한 후 소송구조 여부를 결정합니다.
송달장소 송달명수인 신고 소송기록에 관한 자료	당사자·법정대리인 또는 소송대리인은 주소 등 외의 장소(대한민국 인의 장소로 한정함)를 송달받을 장소로 정하여 법원에 신고할 수 있고, 이 경우에는 송달명수인을 정하여 신고할 수 있습니다. 외국에 거주하는 경우에도 대한민국 안에 송달받을 장소와 송달명수인을 정하여 신고할 수 있습니다.
송달장소 변경신고 소송기록에 관한 자료	▶ 법원에 처음 제출하는 사건에는 도로명 주소, 송달장소, 전화번호·팩시밀리번호 또는 전자우편주소 등 연락처를 기재하여야 합니다. ▶ 그 후 주소나 송달장소가 변경된 경우 반드시 그 사실을 법원에 신고하여야 하고, 그 신고를 하지 않을 경우 소송서류를 종전 송달장소로 발송송달을 하는 등의 불이익을 받을 수 있습니다(무제극에 주소이전 신고를 하였더라도 법원에 변경된 주소를 신고하여야 합니다).

02 재판진행

기일출석 소송기록에 관한 자료	법원이 정한 재판기일에 출석하여야 하고, 기일에 출석하지 않을 경우 불이익을 받을 수 있습니다 특히 배당이의의 소에서 원고가 첫 변론기일에 출석하지 않으면 소를 취하한 것으로 봅니다.
답변서 또는 준비서면 소송기록에 관한 자료	▶ 피고가 원고의 청구를 인정하지 않을 때에는 소장을 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출 하여야 하고, 제출 기한 안에 답변서가 제출되지 않으면 원칙적으로 판결선고기일이 지정됩니다. ▶ 이때 답변서에는 '청구취지에 대한 답변'을 적고(예: "원고의 청구를 기각한다."), '청구원인에 대한 답변'으로서 원고가 주장하는 사실 하나하나에 대하여 인정하는지 여부를 밝히고, 인정하지 않는 경우 그 사유를 구체적으로 적고 뒷받침하는 자료를 첨부하여야 합니다. ▶ 상대방의 주장을 다투거나 변론에서 진술하고자 하는 사항이 있을 경우에는 상대방에게 기일 7일 전까지 송달될 수 있도록 주장과 증거방법을 적은 준비서면을 미리 제출하여야 합니다.
증거신청 소송기록에 관한 자료	▶ 증거는 늦어도 제1회 재판기일 전에 일괄하여 제출·신청하여야 합니다. ▶ 기본적 서류(예: 계약서, 등기부등본, 가족관계증명서 또는 어음·수표 사본 등)과 후속절차가 필요하거나 기간이 오래 걸리는 증거방법(예: 문서송부촉탁, 감정·검증·사실조회)은 소송절차 초기 단계에 신청하여야 합니다.
부분제출 소송기록에 관한 자료	상대방에게 송달하여야 하는 서류를 제출할 때 송달에 필요한 수의 부분을 함께 제출 하여야 합니다. 특히 답변서·준비서면은 '상대방 수+1' 등의 부분, 서증은 '상대방 수+1' 등의 사본, 증인신문 사항은 '상대방 수+4(단독사건은 3)' 등을 제출하여야 합니다.
화해적 해결 시도 소송기록에 관한 자료	법원은 소송절차의 어느 단계에서든 분쟁의 원만한 해결을 위하여 화해권고 또는 조정회부 등을 할 수 있습니다.

03 재판안내

각종 안내 소송기록에 관한 자료	▶ 대한민국법원 홈페이지(www.scourt.go.kr, 대국민서비스 → 전자원심센터) 에서 사건 진행 상황을 쉽게 확인할 수 있고, 그 밖의 재판절차에 관하여 상세히 안내받을 수 있으며, 각종 서류의 양식도 내려받을 수 있습니다.
--	--

일의 지정·통지에 관한 자세한 설명은 제22장(사건관리 및 변론의 진행) 참조.

라. 전자소송 안내서

원고가 소장을 전자적으로 제출한 사건이든 종이로 제출한 사건이든, 소장을 송달받는 피고로 하여금 전자소송 동의를 하고 전자소송방식을 이용할 수 있도록 안내하기 위하여, 법원사무관등은 소장 등 서류를 최초로 송달할 때에는 전자소송 동의의 방식과 인증번호 등이 기재된 전자소송안내서를 함께 보내야 한다(민전예규 60조 본문).

3. 소장부분 송달의 시기 및 효과

소장부분은 적법한 수령자인 피고 등이 서류를 영수한 때에 송달된 것으로 인정된다. 다만 송달·통지가 전자적으로 이루어진 경우에는 수송달자가 전산정보처리시스템에 접속하여 ‘등재된 전자문서를 확인한 때’에 송달의 효력이 발생하고, 만일 확인하지 않은 경우에는 ‘등재사실을 통지한 날로부터 1주가 지난 날’에 송달된 것으로 간주된다(민전 11조 4항). 법원사무관등은 송달할 전자문서를 시스템에 등재하고 그 사실을 송달받을 자에게 전자적으로 통지하는데(3항), 그 통지는 등록사용자가 시스템에 입력한 전자우편주소로 전자우편을 보내고 휴대전화번호로 문자메시지를 보내는 방법으로 하나, 통지의 효력은 전자우편이 전자우편주소로 전송된 때 또는 문자메시지가 휴대전화번호로 전송된 때 발생한다(민전규 26조 1항, 2항). 다만 송달받을 자가 시스템의 장애로 인하여 전자문서를 확인할 수 없는 기간이 1일당 1시간을 초과하는 경우에는 해당 일을 ‘송달이 간주되는 1주 기간’에 산입하지 않고, 그 기간의 마지막 날 오전 9시 이후에 시스템의 장애로 인하여 전자문서를 확인할 수 없게 된 때에도 1일을 그 기간에 산입하지 아니한다(28조 1항). 그 밖의 자세한 설명은 제20장(송달) 참조.

소장부분이 송달됨으로써 소송계속의 효과가 발생하며, 그중 가장 중요한

것은 중복제소금지이다(민소 259조). 소장에 피고에 대한 최고, 계약의 해제, 해지의 통지, 그 밖의 실체법상 의사표시가 기재되어 있는 때에는 그 부분이 피고에게 송달됨으로써 최고나 그 밖의 의사표시를 한 것으로 된다(대법원 1982. 5. 11. 선고 80다916 판결). 어음금의 지급을 구하는 소장의 송달은 그 어음의 지급제시와 동일한 효력이 있다(대법원 1970. 7. 24. 선고 70다965 판결). 그 밖에 소송촉진 등에 관한 특례법 3조에 의하여 지연손해금의 법정 비율이 소장부분 송달 다음 날부터는 연 12%로 되는 효과가 있어 소송촉진에 도움이 된다.

일단 소장이 피고에게 송달된 후에는 필수적 기재사항의 흠, 인지의 부족 등이 나중에 판명되어 원고가 보정명령에 불응하였더라도, 재판장이 소장각 하명령을 할 수는 없고 반드시 법원이 소각하판결을 하여야 한다.

4. 소장부분이 송달불능된 경우의 처리

가. 재판장의 주소보정명령 등

피고에 대한 소장 송달이 불능으로 되는 경우는 여러 가지가 있는데, 그 중 소장 심사 단계에서 이미 송달불능임이 분명한 경우의 처리에 관하여는 앞에서 설명하였다(제3절 참조).

소장의 심사단계에서는 피고에 대한 송달이 가능한 것으로 되어 있었으나(주소와 송달수령권자가 명시되고 송달료도 예납된 경우) 송달을 시행하여 본 결과 송달실시기관(주로 우편집배원)의 보고서에 의하여 송달불능임이 드러난 경우에는 다음과 같이 처리하게 된다.

(1) 재송달의 실시

주소불명 또는 수취인불명으로 반송된 경우에는 먼저 송달 시행 당시의 우편봉투에 기재된 주소 및 성명에 오기가 없었는지를 조사한 후 오기가 있었음이 확인되면 올바르게 기재하여 재송달을 실시하여야 한다. 폐문부재로 반송된 경우에도 일단 재송달을 실시하는 것이 원칙이나, 재송달을 하여도

반송될 만한 사정이 엿보일 때에는 바로 아래 (2)항의 보정명령으로 나아갈 수도 있다. 한편 등기우편 등 대법원규칙이 정하는 방법으로 하는 발송송달(민소 187조)은 적어도 소장의 송달에서는 신중을 기하여야 할 것이다(대법원 2022. 3. 17. 선고 2020다216462 판결).

반송된 서류에 다른 주소(이사한 곳 또는 장기체류지 등)가 기재되어 있을 때에는 우선 그곳으로 재송달을 실시하여야 한다.

(2) 주소보정명령

주소불명 또는 수취인불명으로 반송되었으나 주소·성명에 오기가 없는 경우, 폐문부재로 재송달하였으나 재송달에서도 같은 사유로 반송된 경우 등에는 재판장 등이 원고에게 피고에 대한 송달가능한 주소의 보정을 명하여야 한다(민소 255조 2항, 254조 1항). 이 경우에는 주소보정명령[전산양식 A1133](항소장의 경우 [전산양식 A1134])에 송달불능 사유를 표시하여 송달하여야 하며, 변론기일에 법정에서 주소보정명령을 발하는 경우에도 당사자에게 송달불능 사유를 알려 주어야 한다(송달예규 6조 2항). 변호사인 소송대리인에 대해서는 전화, 팩시밀리, 전자우편 또는 휴대전화 문자전송 등을 활용하여 주소보정명령을 송달하는 방식도 적극 활용한다(민소규 46조).

주민등록법상 주민등록표의 열람 또는 등·초본 교부는 본인 또는 세대원에 한정되어 있으나, 주소보정명령서를 제시하여 소송수행상 필요한 경우임이 증명되면 피고의 주민등록표등본의 신청이 가능하다(주민등록법 29조 2항 2호, 주민등록법 시행령 47조 5항, 주민등록법 시행규칙 13조 1항 별표).

[전산양식 A1133] 주소보정명령/보정서

○ ○ 법 원

보 정 명 령

사건 20 가소 신용카드이용대금

[원 고 ○○○/ 피 고 ○○○]

원고 ○○○ (귀하)

소장에 기재된 피고 ○○○에 대하여 소장부분이 송달되지 않습니다.

[피고 ○○○ 송달불능사유 :]

원고는 이 보정명령을 받은 날로부터 ○일 안에 아래와 같은 요령으로 주소보정을 하시기 바랍니다. 송달료의 추가납부가 필요한 경우에는 주소보정과 함께 그 금액을 납부하여야 합니다.

위 기한 안에 주소보정을 하지 아니하면 소장이 각하될 수 있습니다(민사소송법 제255조 제2항 참조).

20 . . .

판 사 ○ ○ ○ (인)

주소 변동 유무	☐ 주소변동 없음	종전에 적어낸 주소에 그대로 거주하고 있음	
	변 동 있 음	☐ 주소 (주민등록상 주소 가 변동) ☐ 송달장소 (주민등록상 주소 는 변동 없음)	
송달 료 필 요 신 청	송 달 료 필 요	☐ 재송달신청	종전에 적어낸 주소로 다시 송달
		☐ 특별송달신청 (특별송달료는 지 역에 따라 차이가 있을 수 있음)	☐ 통합송달(주간+야간+휴일) ☐ 주간송달 ☐ 야간송달 ☐ 휴일송달 ☐ 종전에 적어낸 주소로 송달 ☐ 새로운 주소로 송달 ☐ 송달장소로 송달
	☐ 공시송달신청	주소를 알 수 없으므로 공시송달을 신청함 (첨부서류 :)	
20 . . . 원고 ○○○			

[주소보정요령]

1. 상대방의 주소가 변동되지 않은 경우에는 주소변동 없음란의 □에 “✓” 표시를 하고, 송달이 가능한 새로운 주소가 확인되는 경우에는 주소변동 있음란의 □에 “✓” 표시와 함께 새로운 주소를 적은 후 이 서면을 주민등록표초본 등 소명자료와 함께 법원에 제출하시기 바랍니다.(상대방의 주소가 변동되지 않은 경우에도 주민등록표 초본 등 제출요함)
2. 법인 대표자의 주소로 송달장소를 보정할 경우에는 주소변동 있음란의 □에 “✓” 표시와 함께 새로운 송달장소를 적은 후 이 서면을 대표자의 주민등록표 초본 등의 소명자료와 함께 법원에 제출하시기 바랍니다.
3. 상대방이 종전에 적어 낸 주소에 그대로 거주하고 있으면 재송달신청란의 □에 “✓” 표시를 하여 이 서면을 주민등록표 초본 등 소명자료와 함께 법원에 제출하시기 바랍니다.
4. 수취인부재, 폐문부재 등으로 송달되지 않는 경우에 특별송달(집행관송달 또는 법원 경위송달)을 희망하는 때에는 특별송달신청란의 □에 “✓” 표시를 하고, 통합송달·주간송달·야간송달·휴일송달 중 희망하는 란의 □에도 “✓” 표시를 한 후, 이 서면을 주민등록표 초본 등의 소명자료와 함께 법원에 제출하시기 바랍니다.(특별송달에 필요한 송달료 추가납부와 관련된 문의는 재판부 또는 접수계로 하시기 바랍니다).
5. 통합송달은 원고가 복수의 송달방법(주간송달, 야간송달 및 휴일송달)을 한 번에 신청할 수 있는 집행관송달 방식을 말합니다.
6. 공시송달을 신청하는 때에는 공시송달신청란의 □에 “✓” 표시를 한 후 주민등록말 소자등본 기타 공시송달요건을 소명하는 자료를 첨부하여 제출하시기 바랍니다.
7. 읍·면사무소 또는 동주민센터 등에 이 서면 또는 주소보정권고 등 법원에서 발행한 문서를 제출하여 상대방의 주민등록표 초본 등의 교부를 신청할 수 있습니다(주민등록법 제29조 제2항 제2호, 동법 시행령 제47조 제5항 참조).

(3) 반송된 서류에 피고가 사망하였다는 뜻이 기재되어 있을 경우

이 경우에는 만약 그 사망 사실이 진실이라면 소 자체가 부적법하게 되므로, 사망 사실이 첨부자료 등에 의하여 명백히 확인되면 변론 없이 소각하판결을 하고, 사망 사실이 분명히 확인되지 않는 경우에는 변론을 열어서 확인한 후에 소각하판결을 하는 것이 원칙이다. 다만 원고가 사망 사실을 모르고 사망자를 피고로 표시하여 소를 제기한 경우에, 청구의 내용과 원인사실, 당해 소송을 통하여 분쟁을 실질적으로 해결하려는 원고의 소제기 목적 내지는 사망 사실을 안 이후의 원고의 피고표시정정신청 등 여러 사정을 종합하여 볼 때 사망자의 상속인이 처음부터 실질적인 피고이고 다만 그 표시를 잘못된 것으로 인정된다면, 사망자의 상속인으로 피고의 표시를 정정할 수 있다(대법원 2006. 7. 4. 자 2005마425 결정). 이러한 법리는 채권자가 채무자

의 사망 이후 그 1순위 상속인의 상속포기 사실을 알지 못하고 1순위 상속인을 상대로 소를 제기한 경우에도 채권자가 의도한 실질적 피고의 동일성에 관한 위 전제요건이 충족되는 한 마찬가지로 적용된다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다49964 판결). 법원에서도 소송경제를 위해 미리 원고에게 피고표시정정신청을 권고하는 것이 바람직할 것이다. 따라서 이러한 경우에는 주소보정명령을 발할 것이 아니라 위와 같은 중용의 뜻을 적절한 서면으로 원고에게 통지하면 되는데, 그 양식은 앞서 본 보정명령 양식의 여백을 적절히 활용하여 기재하면 될 것이다. 피고표시정정에 관한 명령에 불응하면 그 소송을 사망자를 상대로 한 부적법한 소라 하여 판결로 각하하는 것이 타당하다.

(4) 공시송달 또는 집행관·법원경위에 의한 송달 신청이 있는 경우

원고가 보정명령에서 정해진 기간 내에 피고의 새 주소를 적어내지 않았더라도 공시송달 또는 집행관·법원경위에 의한 송달을 신청한 경우에는, 바로 소장각하명령을 하지 않고 그 신청에 따른 절차를 진행하여야 한다.

먼저, 공시송달의 신청이 있는 경우에는 공시송달의 요건 해당 여부를 조사하여(사유에 대한 소명자료의 보충이 필요할 때에는 원고에게 서면으로 그 소명자료를 특정하여 제출을 명하기도 한다) 공시송달을 명할 수 있다. 구체적인 사항은 제20장(송달) 참조.

다음, 집행관·법원경위에 의한 송달의 신청이 있는 경우(보통 피고가 실제로는 소장상의 주소에 거주하고 있으면서도 불거주를 가장하여 송달수령을 회피하고 있다고 원고가 주장하는 경우에 이러한 신청이 있게 된다), 원래 송달에 관하여 어떠한 방법을 택할 것인가는 송달사무처리기관인 법원사무관등이 재판장의 허가 등 절차를 거칠 필요 없이 직권으로 결정하는 것인데, 법원사무관등이 그러한 신청(엄밀한 의미에서는 신청이 아니라 법원사무관등의 송달사무처리에 관한 일종의 희망에 불과하다)을 불허할 사유는 거의 없을 것이므로, 집행관등에게 지급할 비용이 예납되어 있는 이상 법원사무관등으로서는 집행관·법원경위를 통한 송달절차를 취하여야 한다. 자세한 설명은 제20장(송달) 참조.

한편 평일이나 주간에는 송달이 되지 않고(폐문부재의 경우에 그런 일이 많다) 공휴일 또는 해뜨기 전이나 해진 뒤에만 송달이 될 수 있는 사정이 있는 경우에 당사자의 신청에 의하여 공휴일 또는 해뜨기 전이나 해진 뒤에 집행관 등에 의한 송달을 하는 때에는 법원사무관등은 송달할 서류(소장부분 등)에 그 사유를 덧붙여 적어야 한다(민소 190조 2항).

(5) 일부 피고에 대하여 소장부분이 송달불능된 경우

여러 명의 피고들 중 일부 피고에 대하여 소장부분이 송달불능된 사건에서는 주소보정 등을 통하여 모든 피고에 대한 송달이 완료된 뒤 다음 절차를 진행함으로써 가능한 한 비효율적인 기일운영을 막아야 하며, 소장부분이 송달되면 그 후 송달서류가 송달불능되더라도 발송송달이 가능하므로 그 이후의 재판진행이 가능하다. 물론 피고가 매우 많아 당사자 모두에게 소장 송달이 완료되기를 기다리기에 장시간이 소요되는 경우에는 당사자별로 변론을 분리하거나 송달된 피고와 먼저 변론준비절차를 진행하여 다른 피고들의 상황을 청취하는 등 적절한 소송지휘로 재판을 진행할 수도 있다.

나. 주소보정 불이행 시의 소장각하명령

재판장이 원고에게 주소보정명령을 발한 경우에 원고가 정해진 기간이 지나도록 보정을 하지 않으면 재판장이 소장각하명령을 하여야 한다(민소 255조 2항, 254조 2항).

보정명령에 따라 보정된 주소로 행한 송달도 다시 불능으로 된 경우에도 즉시 소장을 각하할 것이 아니라 거듭 보정을 명하여야 한다. 다만 여러 차례에 걸쳐 송달이 불능된 곳임이 명백한데도 계속하여 같은 주소로 보정하는 경우와 같이, 형식적으로만 보정서를 제출하였을 뿐 실질적인 보정의무의 이행이 없다고 볼 수 있는 경우에는 소장각하명령을 할 수 있을 것이다.

제5절 소송요건의 심사

1. 총 설

소장부분이 피고에게 송달되면 원고와 피고 사이에 소송계속이 이루어진다. 이때 본안판결을 받기 위한 전제로서 소가 적법한 취급을 받기 위하여 구비하지 않으면 안 될 사항을 ‘소송요건’이라 한다.

소송요건의 조사시기는 논리상 소장심사 이후 본안 심리 이전이 되므로, 통상 피고의 답변서 제출기한이 지난 후 재판장이 최초로 기록에 대한 실질적 심사를 하게 될 때 소송요건에 대한 조사를 하게 될 것이다. 그렇지만, 실무에서는 반드시 이에 구애될 것은 아니라 소장심사를 할 때에 소송요건에 대한 조사를 할 수도 있고, 반드시 본안 심리에 앞서 조사를 끝내야 하는 것도 아니므로 본안 심리 중에도 수시로 심사하여 그 흠이 드러나면 더 이상의 본안심리를 그치고 보정을 명하여야 하며, 소장심사 또는 본안심리의 어느 단계에서든지 보정이 불가능함이 밝혀졌거나 또는 보정명령에 불응한 경우에는 판결로 소를 부적법 각하해야 한다.

소송요건에 대하여는 소송법에 통일적인 규정이 없고 여러 곳에 흩어져 있다. 중요한 소송요건을 몇 개의 유형으로 정리하면 법원에 관한 사항, 당사자에 관한 사항 및 소송물에 관한 사항의 세 가지로 나누어 볼 수 있는데, 이하 차례로 살펴본다.

2. 법원에 관한 사항

가. 피고 및 사건이 우리나라의 재판권에 속할 것

피고에게 재판권이 미치고 국제관할권이 있어야 한다. 우리나라 법원이 재판권을 행사할 수 없는 경우로 재판권의 대인적 제약(재판권 면제자에 대한 재판권의 배제), 대물적 제약(국내법원과 외국법원 사이의 재판권의 분장 한계에

따른 재판권의 배제) 등이 있다. 자세한 설명은 제2장(법원) 참조. 한편 외국법이 우리나라 재판권에 복종할 의사로 우리나라 법원에 스스로 소를 제기한 이상 그 소는 적법하다(대법원 1978. 2. 14. 선고 77다2310 판결). 피고가 북한(조선민주주의인민공화국)인 경우, 우리 헌법 3조(영토조항)에 근거하여 북한도 대한민국의 영토이고 북한주민도 대한민국의 국민으로 보는 입장을 취하면, 우리나라 법원에 재판관할권이 전면적으로 인정될 것이다. 반면 북한을 내국도 외국도 아닌 '준외국'으로 보고 일정한 경우 북한 관련 민사소송을 외국적 요소가 있는 국제민사사건으로 보아, 국제사법을 유추 적용하여 재판관할권 존부를 판단할 여지도 있다. 한편 대한민국 법원은 개성공업지구 현지기업 사이의 민사분쟁에 대하여 당연히 재판관할권을 가지고, 이는 소송의 목적물이 개성공업지구 내에 있는 건물 등이라고 하여 달리 볼 것이 아니다(대법원 2016. 8. 30. 선고 2015다255265 판결).

나. 법원이 관할권을 가질 것

법원이 토지·사물 및 직분관할권을 가지고 있어야 하며, 민사소송사항이어야 한다. 다만 법원의 관할은 소송요건이기는 하지만, 관할위반은 소각하 판결을 할 사유가 아니며 결정으로 관할법원에 이송하여야 한다(민소 34조). 이는 전속관할의 경우에도 동일하다.

한편 행정소송법상 항고소송으로 제기하여야 할 사건을 민사소송으로 잘못 제기한 경우에 수소법원이 그 항고소송에 대한 관할도 동시에 가지고 있다면, 전심절차를 거치지 않았거나 제소기간을 도과하는 등 항고소송으로서의 소송요건을 갖추지 못했음이 명백하여 항고소송으로 제기되었더라도 어차피 부적법하게 되는 경우가 아닌 이상, 원고로 하여금 항고소송으로 소 변경을 하도록 석명권을 행사하여 행정소송법이 정하는 절차에 따라 심리·판단하여야 한다(대법원 2020. 1. 16. 선고 2019다264700 판결). 나아가 공법상 당사자소송을 민사소송으로 변경할 수 있는지에 관하여 명문의 규정을 두고

있지 않으나, 공법상 당사자소송에서 민사소송으로의 소 변경이 금지된다고 볼 수 없다(대법원 2023. 6. 29. 선고 2022두44262 판결).

자세한 설명은 제3장(관할) 참조.

3. 당사자에 관한 사항

가. 당사자가 실재하고 당사자능력이 있을 것

허무인을 상대로 한 소, 사망자를 상대로 한 소, 민사소송법 52조의 요건에 해당되지 않는 단체·시설 등을 상대로 한 소는 모두 이러한 소송요건이 결여되어 부적법하다. 소제기 후 소장부분이 송달되기 전에 피고가 사망한 경우에도 마찬가지이다(대법원 2015. 1. 29. 선고 2014다34041 판결).

한편 소장이 1심법원에 접수되기 전에 원고가 사망한 경우에 그 원고 명의의 소제기는 부적법하나(대법원 1990. 10. 26. 선고 90다카21695 판결), 당사자가 사망하더라도 소송대리인의 소송대리권은 소멸하지 아니하므로(민소 95조 1호), 당사자가 소송대리인에게 소송위임을 한 다음 소제기 전에 사망하였는데 소송대리인이 당사자가 사망한 것을 모르고 그 당사자를 원고로 표시하여 소를 제기하였다면 그 소제기는 적법하고, 시효중단 등 소제기의 효력은 상속인들에게 귀속되며, 이 경우 민사소송법 233조 1항이 유추적용되어 사망한 사람의 상속인들은 소송절차를 수계하여야 한다(대법원 2016. 4. 29. 선고 2014다210449 판결). 자기가 자기 자신을 상대로 제기한 소는 부적법하므로 각하하여야 한다(대법원 2001. 5. 8. 선고 99다69341 판결, 도 교육감이 도를 대표하여 도지사가 대표하는 도를 상대로 제기한 소유권확인의 소에 관한 사안).

북한의 당사자능력은 앞서 본 바와 같이 북한의 법적 지위를 어떻게 보느냐에 따라 달라질 수 있다. 북한을 대화·협력의 동반자나 ‘준외국’으로 보는 측면에서는 적어도 법인이 아닌 사단으로서의 실질은 인정하여 당사자능력을 인정할 수 있고, 반국가단체로 보는 측면에서는 북한을 비법인사단으로

도 인정하지 않고 당사자능력을 부정할 수 있다. 하급심 판결례는, 북한을 국가로 인정하지는 않으면서도 북한의 당사자능력을 인정하는 입장과 부정하는 입장으로 나뉘어 있고, 이에 대한 대법원 판결은 아직 없다.

자세한 설명은 제9장(당사자) 제2절, 제3절 참조.

나. 당사자적격이 있는 정당한 당사자일 것

고유필수적 공동소송에서는 관계 당사자 전원이 공동으로 원고가 되거나 피고가 되지 않으면 당사자적격이 결여되어 부적법하게 된다. 다만 민사소송법 68조는 일정한 요건 아래 누락된 공동소송인의 추가를 허용하고 있다.

추심채권자의 제3채무자에 대한 추심소송 계속 중에 채권압류 및 추심명령이 취소되어 추심채권자가 추심권능을 상실하게 되면 추심소송을 제기할 당사자적격도 상실한다(대법원 2021. 9. 15. 선고 2020다297843 판결). 채권자가 대위권을 행사할 당시 이미 채무자가 그 권리를 재판상 행사하였을 때에는 설사 때소의 확정판결을 받았더라도 채권자는 채무자를 대위하여 채무자의 권리를 행사할 당사자적격이 없다(대법원 2020. 6. 25. 선고 2019다218684 판결).

그리고 집행권원상의 청구권이 양도되어 양수인이 승계집행문을 부여받은 경우 집행채권자는 양수인으로 확정되는 것이므로, 승계집행문의 부여로 인하여 양도인에 대한 기존 집행권원의 집행력은 소멸하는 것이어서, 그 후 양도인을 상대로 제기한 청구이의의 소는 피고적격이 없는 자를 상대로 한 소이거나 이미 집행력이 소멸한 집행권원의 집행력 배제를 구하는 것으로 권리보호의 이익이 없어 부적법하다(대법원 2008. 2. 1. 선고 2005다23889 판결).

당사자적격에 관한 더 자세한 내용은 제9장(당사자) 제4절 참조.

다. 소송능력, 법정대리권, 소송행위에 필요한 수권, 법인 등의 대표권이 있을 것

원래 소송능력·법정대리권·소송대리권은 개개 소송행위의 유효요건이지만 소제기 단계에서 그 흠이 있으면 소제기가 유효한 것으로 되지 않기 때문에 소송능력·대리권의 존재는 소송요건이 된다. 이러한 흠이 있을 때에는 법원은 일단 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 하며(민소 59조 전단), 그 기간 내에 보정이 되지 않을 때에 한하여 소각하판결을 하게 된다.

다만 소송능력·법정대리권 또는 소송행위에 필요한 권한의 수여에 흠이 있는 사람이 소송행위를 한 뒤에 보정된 당사자나 법정대리인이 이를 추인한 경우에는 그 소송행위는 이를 한 때에 소급하여 효력이 생긴다(민소 60조). 선정행위에 흠이 있는 선정당사자가 소송행위를 한 경우에도 마찬가지이다(61조). 자세한 내용은 제12장(소송상의 대리인) 참조.

라. 원고에게 소송비용담보 제공의무가 있는 경우에는 이를 이행할 것

원고가 대한민국에 주소·사무소와 영업소를 두지 아니한 때 또는 소장·준비서면, 그 밖의 소송기록에 의하여 청구가 이유 없음이 명백한 때 등 소송비용에 대한 담보제공이 필요하다고 판단되는 경우에 피고의 신청이 있으면 법원은 원고에게 소송비용에 대한 담보를 제공하도록 명하여야 하고, 또한 신청이 없더라도 직권으로 담보의 제공을 명할 수 있는데, 이와 같이 법원이 담보제공명령을 한 때에는 원고는 그 담보를 제공하여야 한다(민소 117조). 소송비용의 담보제공 신청권은 피고에게 있을 뿐 원고가 위와 같은 담보제공 신청을 할 수는 없고, 이는 상소심 절차에서도 동일하게 적용되므로, 원고가 본안소송의 항소심에서 승소하여 피고가 그에 대한 상고를 제기함에 따라 원고가 피상고인으로 되었다고 하여 원고에게 소송비용 담보제공 신청권이 인정되는 것은 아니다(대법원 2017. 9. 14. 자 2017카담507 결정). 만일 원고가 담보를 제공하여야 할 기간 이내에 이를 제공하지 아니하는 때에는

법원은 변론 없이 판결로 소를 각하할 수 있다(124조). 자세한 내용은 제14장(민사소송법상의 담보) 참조.

4. 소송물에 관한 사항

가. 총 설

소의 이익이 있어야 한다. 널리 소의 이익은 국가적·공익적 입장에서는 무익한 소송제도의 남용을 통제하는 원리이고, 당사자의 입장에서는 소송제도를 이용할 정당한 이익 또는 필요성을 말한다.

각종의 소에 공통적인 소의 이익으로 ① 청구가 소구할 수 있는 구체적인 권리 또는 법률관계이어야 하고, ② 법률상 또는 계약상의 소제기 금지사유가 없어야 하며, ③ 소제기 장애사유가 없어야 하고, ④ 원고가 동일 청구에 대하여 승소확정판결을 받은 경우가 아니어야 하며, ⑤ 신의칙에 위반한 소제기가 아니어야 한다.

소의 이익과 관련하여 실무상 주로 문제 되는 몇 가지 경우를 살펴본다.

나. 각종의 소에 공통된 소의 이익

(1) 행정상·사업상 작성 비치된 장부상의 명의변경을 구하는 소의 이익

(가) 행정상의 편의 또는 사업상의 목적을 위하여 행정관청 또는 기업이 비치하여 일정한 권리자를 기재하는 장부(시영아파트의 수분양자대장, 시영임대아파트의 임차인명부, 골프장의 회원명부 등)에 등재된 권리의 양도나 명의변경이 허용되어 있는 경우, 그 권리자로부터 권리를 양수한 사람이 양도인을 상대로 그러한 장부상의 명의변경에 관한 협력의무의 이행을 구하는 소의 이익이 문제 된다.

판례는 원칙적으로 이러한 경우 소의 이익을 인정한다. 먼저, 사업상 목적을 위하여 기업이 비치하는 장부에 관하여 보면, 임대아파트의 임차권을 양도한 경우 임차인(양도인)은 양수인을 위하여 임대인의 동의를 받아 줄 의무

가 있으므로, 양수인은 임대인의 동의를 받아달라는 취지에서 임대인이 보관하고 있는 임차인명부상의 명의변경을 구할 수 있고 그에 의하여 임차인과 양수인 사이의 분쟁을 해결할 수 있으므로 소의 이익이 있다고 하고(대법원 1986. 2. 25. 선고 85다카1812 판결), 아파트 수분양자대장상의 수분양자 명의변경절차의 이행을 구하는 소(대법원 1987. 3. 24. 선고 86다카802 판결), 농업진흥공사가 매도한 토지에 대한 매수인명의변경절차의 이행을 구하는 소(대법원 1990. 3. 13. 선고 88다카100 판결), 산업기지개발사업에 따른 이주 택지에 관한 수분양자대장상의 명의변경절차의 이행을 구하는 소(대법원 1991. 7. 26. 선고 91다14017 판결), 토지개발공사에 비치된 주택피공급자명부상의 명의변경절차의 이행을 구하는 소(대법원 1991. 10. 8. 선고 91다20913 판결)가 소의 이익이 있는 적법한 것이라고 판시하고 있다. 또한 골프클럽회원권을 양수한 자가 직접 골프장업자를 상대로 골프클럽회원권의 명의변경절차의 이행을 구하는 소도 소의 이익이 있다고 하였다(대법원 1986. 6. 24. 선고 85다카2469 판결. 다만 회원권 양수도에 골프장업자의 승인이 필요한 경우, 골프장업자가 명의변경을 통해 그의 승인 의사를 외부에 확정적으로 표시하는 것으로 볼 수 있으므로 회원권에 관한 입회승인을 청구하는 부분은 회원명부의 회원 명의를 원고로 변경할 것을 별도로 청구하는 이상, 소의 이익이 없어 부적법하다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2009다71312 판결)).

(4) 다음으로, 행정관청이 관리하는 허가권 등 양도절차이행청구의 소에서의 소의 이익에 관하여 보면, 건축중인 건축물을 양수한 자가 건축주 명의변경에 동의하지 않는 양도인을 상대로 그 의사표시를 갈음하여 건축허가서의 건축주 명의변경절차 이행을 구하는 소(대법원 1989. 5. 9. 선고 88다카6754 판결), 건축허가서의 건축주 명의를 타인에게 신탁한 자가 이를 해지하고 건축주 명의변경에 동의하지 않는 수탁자를 상대로 그 의사표시를 갈음하여 건축허가서의 건축주 명의변경절차이행을 구하는 소(대법원 1996. 10. 11. 선고 95다29901 판결)는 소의 이익이 있다. 또한 학원의 수인가자의 지위를 양

도받은 자가 양도인을 상대로 학원인가에 관한 설립자 명의변경절차의 이행을 구하는 소(대법원 1992. 4. 14. 선고 91다39986 판결), 당사자 사이에 다방 영업허가명의를 변경하여 주기로 하는 약정이 있는 경우 그 명의변경절차의 이행을 청구하는 소(대법원 1997. 4. 25. 선고 95다19591 판결)도 모두 소의 이익이 있다고 한다. 한편 허가 등에 관한 건축주 명의를 수인으로 되어 있을 경우에, 그 허가 등은 해당 건축물의 건축이라는 단일한 목적을 달성하기 위하여 이루어지고 그 허가 등을 받은 지위의 분할청구는 불가능하다는 법률적 성격 등에 비추어 보면, 공동건축주 명의변경에 대하여는 변경 전 건축주 전원으로부터 동의를 얻어야 하나, 그 명의변경에 관한 동의의 표시는 변경 전 건축주 전원이 참여한 단일한 절차나 서면에 의하여 표시될 필요는 없고 변경 전 건축주별로 동의의 의사를 표시하는 방식도 허용되므로, 동의의 의사표시를 갈음하는 판결도 반드시 변경 전 건축주 전원을 공동피고로 하여 받을 필요는 없으며 부동의하는 건축주별로 피고로 삼아 그 판결을 받을 수 있다(대법원 2015. 9. 10. 선고 2012다23863 판결).

그러나 행정관청의 허가나 특허 명의를 관하여 해당 법에서 양도를 허용하는 취지의 규정도 두고 있지 아니하고 그러한 명의의 변경절차도 규정하고 있지 아니한 경우에는, 양수인이 양도인을 상대로 양도인 명의의 면허를 양수인 명의로 직접 변경할 것의 이행을 구하는 소는 허용되지 않으므로, 온천관리대장의 온천발견자 명의변경절차 이행청구의 소(대법원 2002. 2. 26. 선고 2001다53622 판결), 주류제조면허의 명의변경 청구의 소(대법원 1992. 7. 14. 선고 91다45950 판결), 산림법상 토석채취허가의 명의변경 청구의 소(대법원 1990. 12. 26. 선고 88다카8934 판결) 등은 모두 소의 이익이 없어 부적법하다.

(다) 그 밖에 구체적 법률관계에 관한 민사상의 쟁송인지 여부가 문제된 사례들을 보면, 임야대장의 소유명의 기재의 말소를 구하는 청구의 소(대법원 1979. 2. 27. 선고 78다913 판결), 토지대장의 소유명의자의 주소를 기입하

라는 청구의 소(대법원 1994. 6. 14. 선고 93다36967 판결), 부동산등기기록의 '사항'란에 기재된 근저당권설정등기의 접수일자 변경을 구하는 소(대법원 2003. 10. 24. 선고 2003다13260 판결), 중증의 대동보나 세보에 기재된 사항의 변경이나 삭제를 청구하는 소(대법원 1992. 10. 27. 선고 92다756 판결) 등은 모두 구체적인 권리 또는 법률관계에 관한 쟁송이라고 할 수 없어 소의 이익이 없다고 하고, 건축주 명의의 착오 기재를 이유로 건축허가상 건축주의 명의경정을 구하는 소는 민사소송의 대상이 될 수 없다고 한다(대법원 1993. 9. 28. 선고 92다52689 판결). 다만 무허가건물에 관하여는 무허가건물 대장이 건물의 소유권에 관한 권리변동을 공시하는 것은 아니라 할지라도 일률적으로 소의 이익이 없다고 단정할 수는 없고 개별적 사건에 있어 구체적 사정을 고려하여 이를 판단하여야 한다는 것이 판례의 입장이다(소의 이익이 있다고 본 예: 대법원 1991. 11. 12. 선고 91다21244 판결, 대법원 1998. 6. 26. 선고 97다48937 판결, 반면에 소의 이익이 없다고 본 예: 대법원 1992. 2. 14. 선고 91다29347 판결).

(2) 중복제소의 금지

중복제소의 금지(민소 259조)란 이미 계속된 사건과 동일한 사건에 대하여 당사자가 다시 소를 제기하지 못한다는 것이다. 후소가 중복제소에 해당되면 후소가 전소와 당사자·청구에 있어서 동일하여야 한다. 이 경우 전소·후소의 판별기준은 소송계속의 발생 시기의 선후, 즉 소장이 피고에게 송달된 때의 선후에 의하고, 소제기에 앞서 가압류나 가처분 등 보전절차가 있더라도 이를 기준으로 가릴 것은 아니다(대법원 1994. 11. 25. 선고 94다12517 판결). 여기서 전후 양소의 당사자가 동일하지 아니하더라도 후소의 당사자가 기판력의 확장으로 전소 판결의 효력을 받게 될 경우에는 동일사건이라 할 수 있다.

가장 문제가 되는 것은 채권자대위권에 기하여 채권자가 소를 제기한 경우에 채무자가 동일한 권리에 대하여 다시 소를 제기한 경우나 그 반대의

경우에 동일 사건인가 하는 점이다. 판례는 대위소송이 제기된 후 채무자가 같은 내용의 별소를 제기하는 것은 채무자가 대위소송이 제기된 사실을 알았건 몰랐건 가리지 않고 중복소송으로서 금지된다고 하고 있다(대법원 1992. 5. 22. 선고 91다41187 판결). 반대로 채무자 자신이 자기 권리에 관한 소송을 하고 있는 중에 채권자가 제3채무자를 상대로 채권자대위소송을 제기한 경우에도 후소는 중복소송에 해당하고(대법원 1981. 7. 7. 선고 80다2751 판결), 채권자대위소송 계속 중 다른 채권자가 채무자를 대위하여 제3채무자를 상대로 소를 제기하는 것도 중복제소로서 금지된다(대법원 1994. 11. 25. 선고 94다12517 판결).

그러나 채권자대위권의 경우와는 달리, 채권자취소권의 요건을 갖춘 각 채권자는 고유의 권리로서 채무자의 재산처분 행위를 취소하고 그 원상회복을 구할 수 있는 것이므로, 각 채권자가 동시 또는 이시에 채권자취소 및 원상회복 소송을 제기한 경우 이들 소송이 중복제소에 해당하지는 않는다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2003다19558 판결).

전소의 소송요건에 흠이 있어 부적법하더라도 후소의 변론 종결 시까지 전소가 취하·각하 등에 의하여 그 계속이 소멸하지 않는 한 후소는 중복제소에 해당되어 각하를 면하지 못한다(대법원 1998. 2. 27. 선고 97다45532 판결). 종래 판례는 채무자가 제3채무자를 상대로 제기한 이행의 소가 법원에 계속되어 있는 경우에도 압류채권자는 제3채무자를 상대로 압류된 채권의 이행을 청구하는 추심의 소를 제기할 수 있고, 이는 중복제소가 아니라고 하였으나(대법원 2013. 12. 18. 선고 2013다202120 전원합의체 판결), 추심명령 채무자의 당사자적격이 유지된다고 한 대법원 2025. 10. 23. 선고 2021다252977 전원합의체 판결로 인하여 재검토가 필요하다.

중복된 소제기에 해당하는 경우에도 전소가 취하·각하되어 중복 상태가 해소되면 후소는 적법하게 된다(대법원 1967. 11. 21. 선고 67누76 판결, 대법원 2021. 5. 7. 선고 2018다259213 판결). 그러나 만약 후소에 관하여 먼저 제

1심판결이 선고된 후 항소되었다가 원고가 항소심에서 그 소를 취하한 때에는 전소가 종국판결 후에 소를 취하한 자의 재소금지(민소 267조 2항)에 해당하게 되어 원고는 전소마저 유지할 수 없게 되며 각하를 면할 수 없다는 것이 판례이다(대법원 1967. 10. 31. 선고 67다1848 판결).

(3) 종국판결 후 소를 취하한 자의 재소(再訴)금지

본안에 대한 종국판결이 있는 뒤에 소를 취하한 사람은 같은 소를 제기하지 못한다(민소 267조 2항). 이는 소취하로 인하여 그동안 판결에 들인 법원의 노력이 무용화되고 종국판결이 당사자에 의하여 농락당하는 것을 방지하기 위한 제재적 취지의 규정이므로, 본안에 대한 종국판결이 있는 후 소를 취하한 자라 할지라도 이러한 규정의 취지에 반하지 아니하고 소제기를 필요로 하는 정당한 사정이 있다면 다시 소를 제기할 수 있다(대법원 2009. 6. 25. 선고 2009다22037 판결). 또한 여기서 말하는 ‘같은 소’는 반드시 기판력의 범위나 중복제소금지의 경우와 같이 풀이할 것은 아니므로, 재소의 이익이 다른 경우에는 ‘같은 소’라 할 수 없다(대법원 2023. 3. 16. 선고 2022두 58599 판결). 따라서 부동산 공유자들이 제기한 인도청구 소송에서 1심판결 선고 후 공유자 중 1인이 자신의 공유지분을 다른 공유자에게 양도하고 소를 취하한 뒤에 그 공유지분 양수인이 다시 같은 인도청구 소송을 제기하는 것(대법원 1998. 3. 13. 선고 95다48599 판결) 또는 종국판결 후 소를 취하였다가 피고가 그 소 취하의 전제조건인 약정을 위반하여 약정이 해제 또는 실효되는 사정변경이 생겼음을 이유로 다시 동일한 소를 제기하는 것(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000다46399 판결)은 권리보호의 이익이 달라 재소금지의 원칙에 위반되지 않는다.

반면 후소가 전소의 소송물을 선결적 법률관계 내지 전제로 하는 것일 때에는 비록 소송물은 다르지만 위 제도의 취지와 목적에 비추어 후소에 대하여도 같은 소로서 판결을 구할 수 없다(대법원 1989. 10. 10. 선고 88다카 18023 판결). 또한 재소가 금지되는 종국판결 선고 후 소를 취하한 자(민소

267조 2항)에는 포괄승계인은 물론 변론종결 후의 특정승계인을 포함한다.

채권자대위소송의 기판력의 적용과 관련하여, 판례는 채권자가 채무자를 대위하여 제3채무자를 상대로 받은 확정판결의 기판력은 피대위자인 채무자가 그 대위소송의 제기사실을 알았을 경우에 한하여 채무자에게도 미친다는 것이다(대법원 1975. 5. 13. 선고 74다1664 전원합의체 판결). 따라서 채무자가 대위소송제기 사실을 안 이상 그 대위소송의 제1심판결 후 항소심에서 소가 취하된 때에는 채무자에게도 재소금지규정이 적용된다(대법원 1981. 1. 27. 선고 79다1618 판결).

(4) 원고승소 확정판결의 기판력에 저촉되는 경우

기판력 있는 원고승소 확정판결의 존재는 소극적 소송요건이 된다(대법원 1979. 9. 11. 선고 79다1275 판결). 확정판결이 원고승소 판결인 경우 신소는 이미 권리보호를 받았음에도 불구하고 다시 이를 구하는 것이므로 권리보호의 이익이 없어 각하하여야 한다. 이는 외국법원에서 민사소송법 217조의 승인요건을 갖춘 승소 확정판결을 받은 당사자가 전소의 상대방을 상대로 다시 우리나라 법원에 동일한 청구의 소를 제기한 경우에도 마찬가지이다(대법원 2025. 6. 12. 선고 2024다315527 판결). 승소 확정판결을 얻은 원고가 변론종결 후의 목적물 승계인을 상대로 제기한 신소도 마찬가지로 부적법하여 각하하여야 한다(대법원 1979. 2. 13. 선고 78다2290 판결). 반대로 확정판결이 원고패소 판결인 경우에는 그 확정판결과 모순되는 판단을 하여서는 안 되는 구속력 때문에 신소에 대하여 청구기각판결을 하여야 할 것이지 소의 이익이 없다는 이유로 소를 각하할 수는 없다(대법원 1999. 12. 10. 선고 99다25785 판결).

다만 ① 확정판결의 원본이 멸실되어 강제집행에 필요한 집행문을 받을 수 없는 특별한 사정이 있는 경우(대법원 1981. 3. 24. 선고 80다1888 판결)나, ② 판결이나 화해조서의 내용이 특정되지 아니하여 강제집행을 할 수 없는 경우(대법원 1995. 5. 12. 선고 94다25216 판결, 대법원 1998. 5. 15. 선고 97다

57658 판결)에는 다시 소송을 제기할 권리보호의 이익이 있다. 또한 ③ 확정판결에 기한 채권에 대한 시효중단의 필요가 있는 경우에도 소의 이익이 긍정된다(대법원 1998. 6. 12. 선고 98다1645 판결). 그러나 시효중단을 위한 경우라도, 예컨대 사찰재산의 양도계약이 관할청의 허가를 받지 못해 무효가 되어 유효한 소유권이전등기를 할 수 없게 됨으로써 확정판결에 기한 청구권을 그대로 유지하는 것이 아무런 실익이 없는 경우에는 소의 이익이 부정된다(대법원 2001. 2. 9. 선고 99다26979 판결).

나아가 위와 같이 시효중단 등 특별한 사정이 있어 예외적으로 신소가 허용되는 경우라고 하더라도, 신소의 판결은 전소의 승소확정판결의 내용에 저촉되어서는 안 되므로, 후소 법원으로서의 그 확정된 권리를 주장할 수 있는 모든 요건이 구비되어 있는지 여부에 관하여 다시 심리할 수는 없다. 따라서 전소인 약속어음금 청구 소송에서 원고의 피고에 대한 약속어음채권이 확정된 이상 그 확정된 채권의 소멸시효의 중단을 위하여 제기한 소송에서 원고의 약속어음의 소지 여부를 다시 심리할 수는 없다(대법원 1998. 6. 12. 선고 98다1645 판결). 다만 전소의 변론종결 후에 새로 발생한 변제, 상제, 면제 등과 같은 채권소멸사유는 후소의 심리대상이 되어 채무자인 피고는 후소 절차에서 위와 같은 사유를 들어 항변할 수 있으나, 법률이나 판례의 변경은 전소 변론종결 후에 발생한 새로운 사유에 해당한다고 할 수 없다(대법원 2019. 8. 29. 선고 2019다215272 판결).

(5) 간이하고 특별한 구제절차가 따로 마련되어 있는 경우

어느 분쟁해결을 위하여 적정한 판단을 받을 수 있도록 마련된 보다 더 간편한 절차를 이용할 수 있었음에도 그 절차를 이용하지 않았다는 사정은 소제기에서 소극적 권리보호의 요건이 된다(대법원 2002. 9. 4. 선고 98다17145 판결).

불법행위 피해자가 법원의 감정명령에 따라 신체감정을 받으면서 그 감정을 위한 제반 검사비용으로 지출하였다는 금액은 예납의 절차에 의하지 않

고 직접 지출하였다 하더라도 감정비용에 포함되는 것으로서 소송비용에 해당하는 것이고, 소송비용으로 지출한 금액은 소송비용확정의 절차를 거쳐 상환받을 수 있는 것이어서 이를 별도로 소구할 이익이 없다(대법원 2000. 5. 12. 선고 99다68577 판결). 또 경매절차에서 매각대금을 완납한 매수인은 민사집행법 144조 1항의 규정에 의하여 경매법원이 매각된 부동산에 대하여 매수인 앞으로 소유권이전등기를 촉탁함으로써 소유권이전등기를 넘겨받을 수 있는 것이므로, 굳이 종전 소유자 등을 상대로 매각을 원인으로 한 소유권이전등기절차의 이행을 소구할 이익이 없다(대법원 1999. 7. 9. 선고 99다 17272 판결).

한편 소유권보존등기나 부동산의 표시에 관한 등기에 관하여도 그 이행을 청구할 소의 이익이 부정된다. 예컨대 미등기 부동산을 소유자로부터 매수하였거나 또는 한 필지의 토지 중 일부만을 매수한 매수인이 매도인을 상대로 소유권이전등기를 청구하면서, 그 소유권이전등기의 전제가 되는 소유권 보존등기 또는 분필등기를 청구하는 경우에는 소의 이익이 없는 것으로 각 하하여야 한다. 그러한 등기는 등기신청권자가 단독으로 신청할 수 있는 것이어서(부등 23조 2항, 65조), 매수인으로서의 소유권이전등기 청구에 관한 승소 확정판결을 받은 후 그 등기청구권에 터 잡아 매도인의 등기신청권을 대위하여 단독으로 그러한 등기를 마칠 수 있으므로, 구태여 매도인을 상대로 소를 제기할 법률상의 이익이 없다.

또한 등기명의인의 표시변경등기는 등기명의인의 동일성이 유지되는 범위 내에서 등기기록상의 표시를 실제와 합치시키기 위하여 행하여지는 것에 불과할 뿐 어떠한 권리변동을 가져오는 것이 아니므로, 그 표시변경이 등기명의인의 동일성을 해치는 방법으로 행하여져 타인을 표상하는 결과에 이른 경우가 아닌 한, 등기명의인은 그 표시변경등기가 잘못되었더라도 다시 소정의 서면을 갖추어 경정등기를 하면 되는 것이고, 소로써 그 표시변경등기의 말소를 구하는 것은 소의 이익이 없어 허용되지 않는다(대법원 2000. 5.

12. 선고 99다69983 판결). 나아가 실체관계상 공유인 부동산에 관하여 단독 소유로 소유권보존등기가 마쳐졌거나 단독소유인 부동산에 관하여 공유로 소유권보존등기가 마쳐진 경우, 진정한 권리자는 소유권보존등기의 일부말소를 소로써 구하고 법원은 그 지분에 한하여만 말소를 명할 수 있으나, 등기기술상 소유권보존등기의 일부말소는 허용되지 않으므로, 그 판결의 집행은 단독소유를 공유로 또는 공유를 단독소유로 하는 경정등기의 방식으로 이루어진다. 이와 같은 일부말소 의미의 경정등기는 등기절차 내에서만 허용될 뿐 소송절차에서는 일부말소를 구하는 외에 경정등기를 소로써 구하는 것은 허용될 수 없다(대법원 2017. 8. 18. 선고 2016다6309 판결).

그 밖에 등기관직권이나 법원의 촉탁에 의하여 마쳐진 등기의 말소등기 또는 말소된 등기의 회복등기는 등기관직권이나 법원의 촉탁에 의하여 행하여져야 하므로, 그 등기명의인을 상대로 말소등기 또는 회복등기를 구하는 소 역시 부적법한 소로서 각하하여야 한다(대법원 1996. 5. 31. 선고 94다27205 판결, 대법원 2002. 4. 12. 선고 2001다84367 판결). 예컨대, 부동산 강제경매개시결정 기입등기는 채권자나 채무자가 직접 등기공무원에게 이를 신청하여 행할 수는 없고 반드시 법원의 촉탁에 의하여 행하여지는데, 이와 같이 당사자가 신청할 수 없는 강제경매개시결정 기입등기가 법원의 촉탁에 의하여 말소된 경우에는 그 회복등기도 법원의 촉탁에 의하여 행하여져야 하므로, 이 경우 강제경매 신청채권자가 말소된 강제경매개시결정 기입등기의 회복등기절차의 이행을 소구할 이익은 없고, 다만 강제경매개시결정 기입등기가 말소될 당시 그 부동산에 관하여 소유권이전등기를 경료하고 있는 사람은 법원이 강제경매개시결정 기입등기의 회복을 촉탁함에 있어서 등기상 이해관계가 있는 제3자에 해당하므로, 강제경매 신청채권자로서는 그 사람을 상대로 하여 법원의 촉탁에 의한 강제경매개시결정 기입등기의 회복절차에 대한 승낙청구의 소를 제기할 수는 있다(대법원 2019. 5. 16. 선고 2015다253573 판결).

(6) 소송의 목적이 이미 실현된 경우

소송으로 달성하려는 목적이 이미 실현되어 있는 경우에는 소의 이익이 없으며, 특히 소송계속 중 그 청구의 목적이 어떠한 이유로든 실현되어 버린 경우에도 소의 이익이 사후적으로 소멸하여 부적법하게 된다.

예컨대 국유지에 대한 취득시효완성을 원인으로 한 소유권이전등기절차 이행 소송의 사실심 심리 도중 국가가 소 제기자에게 대상 토지에 관하여 상환완료를 원인으로 한 소유권이전등기를 마쳐 준 경우, 이미 소유권이전등기를 마친 소 제기자로서는 특별한 사정이 없는 한 더 이상 소유권이전을 구하는 소를 유지할 필요가 없게 되었고, 임의로 소유권을 이전해 준 국가로서도 소 제기자의 소유권이전청구권의 존부에 대하여 다룰 이익을 상실하게 되었으므로, 그 소는 권리보호의 이익을 결한 것으로서 부적법하게 된다(대법원 1996. 10. 15. 선고 96다11785 판결). 또 근저당권설정등기의 말소등기절차의 이행을 구하는 소송 도중에 그 근저당권설정등기가 매각을 원인으로 하여 말소된 경우에는 더 이상 근저당권설정등기의 말소를 구할 법률상 이익이 없으므로, 상고심 계속 중에라도 그러한 사유가 밝혀지면 소의 이익이 없어 부적법함을 이유로 소를 각하하여야 한다(대법원 2003. 1. 10. 선고 2002다57904 판결).

나아가 어느 한 채권자가 동일한 사해행위에 관하여 채권자취소 및 원상회복청구를 하여 승소판결을 받아 그 판결이 확정되었다는 것만으로 그 후에 제기된 다른 채권자의 동일한 청구가 권리보호의 이익이 없어지게 되는 것은 아니지만, 그에 기하여 재산이나 가액의 회복을 마친 경우에 비로소 다른 채권자의 채권자취소 및 원상회복 청구는 그와 중첩되는 범위 내에서 권리보호의 이익이 없게 된다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2003다19558 판결). 즉 선행 채권자의 사해행위취소 판결이 확정된 것만으로는 그 기판력이 뒤의 다른 채권자에게 미치지 않는지만, 그 판결에 의한 집행까지 끝나 이미 사해행위의 취소 및 원상회복이 이루어진 범위 내에서는 다른 채권자로서도 사

해행위취소소송으로써 달성하고자 하는 목적이 이미 실현되었기 때문에 권리보호의 이익이 없게 되는 것이다(이때 선행채권자가 다른 채권자보다 사실상 우선변제를 받는 불공평한 결과가 초래된다고 하더라도 이는 현행 채권자취소 관련 규정의 해석상 불가피하고 특별한 사정이 없는 한 신의성실의 원칙에 위배된다고 할 수 없다. 대법원 2024. 4. 4. 선고 2023다295596 판결).

그 밖에 형성소송에 관하여 보면, 공유물분할은 협의분할을 원칙으로 하고 협의가 성립되지 아니한 때에는 재판상 분할을 청구할 수 있으므로, 공유자 사이에 이미 분할에 관한 협의가 성립된 경우에는 또다시 소로써 그 분할을 청구하거나 이미 제기한 공유물분할의 소를 유지함은 허용되지 않는다(대법원 1995. 1. 12. 선고 94다30348 판결).

다. 확인의 소에 관한 소의 이익

(1) 확인의 대상

확인 소에서 확인의 대상은 원칙적으로 현재의 권리 또는 법률관계이어야 하며, 단순한 사실의 확인은 허용되지 않는다. 예컨대 종손이라는 지위의 확인을 구하는 것(대법원 1961. 4. 13. 선고 4292민상940 판결), 통일교가 기독교의 종교단체인지 여부에 대한 확인을 구하는 것(대법원 1980. 1. 29. 선고 79다1124 판결), 별도로 보존등기된 2개의 건물이 동일건물이라는 확인을 구하는 것 등은 확인의 소의 대상이 되지 못한다.

다만 일부 공동상속인이 다른 공동상속인을 상대로 그 재산이 상속재산임의 확인을 구하는 소를 제기한 경우, 이는 그 재산이 현재 공동상속인들의 상속재산분할 전 공유관계에 있음의 확인을 구하는 소송으로서, 그 승소확정판결에 의하여 그 재산이 상속재산분할의 대상이라는 점에 대하여 다툴 수 없게 되고, 그 결과 공동상속인 간의 분쟁을 종국적으로 해결할 수 있으므로 확인의 이익이 있다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006다40980 판결). 당사자 사이에 제사용 재산의 귀속에 관하여 다툼이 있는 등으로 구체적인 권리

또는 법률관계와 관련성이 있는 경우에 다툼을 해결하기 위한 전제로서 제사주재자 지위의 확인을 구하는 것은 법률상의 이익이 있다고 할 것이지만, 그러한 권리 또는 법률관계와 무관하게 공동선조에 대한 제사를 지내는 중증 내에서 단순한 제사주재자의 자격에 관한 시비 또는 제사 절차를 진행할 때에 종중의 종원 중 누가 제사를 주재할 것인지 등과 관련하여 제사주재자 지위의 확인을 구하는 것은 그 확인을 구할 법률상 이익이 있다고 할 수 없다(대법원 2012. 9. 13. 선고 2010다88699 판결).

한편 확인의 소로써 위험·불안을 제거하려는 법률상 지위는 반드시 구체적인 권리로 뒷받침될 것을 요하지 아니하고 그 법률상 지위에 터 잡은 구체적인 권리 발생이 조건 또는 기한에 걸려 있거나 법률관계가 형성과정에 있는 등 원인으로 불확정적이라고 하더라도 보호할 가치 있는 법적 이익에 해당하는 경우에는 확인의 이익이 인정될 수 있다(대법원 2000. 5. 12. 선고 2000다2429 판결).

종교단체의 징계결의는 종교단체 내부의 규제로서 헌법이 보장하는 종교 자유의 영역에 속하므로 원칙적으로 법원은 그 효력 유무를 판단할 수 없지만, 구체적인 권리 또는 법률관계를 둘러싼 분쟁이 존재하고 그에 관한 판단에 앞서 위 징계의 당부를 판단할 필요가 있는 경우에는 그 판단의 내용이 종교 교리의 해석에 미치지 아니하는 한 법원으로서 위 징계의 당부를 판단하여야 한다(대법원 2005. 6. 24. 선고 2005다10388 판결).

일반적으로 종단에 등록을 마친 사찰의 주지는 비법인사단 또는 단체인 당해 사찰의 대표자 지위를 점유하면서 사찰 재산의 관리처분권 등을 갖게 되는 것이어서, 그 주지 지위의 확인이나 주지해임무효확인 등을 구하는 것이 구체적인 권리 또는 법률관계와 무관한 단순한 종교상의 자격에 관한 시비에 불과하다고 볼 수 없다(대법원 2005. 6. 24. 선고 2005다10388 판결). 마찬가지로 교회의 대표자인 담임 목사는 예배 및 종교활동을 주재하는 종교상의 지위와 아울러 비법인사단의 대표자 지위를 점유하면서 교회 재산의

관리처분과 관련한 대표권을 가지므로, 재산의 관리처분과 관련한 교회 대표자 지위에 관한 분쟁은 구체적인 권리 또는 법률관계를 둘러싼 분쟁에 해당하여 그 대표자 지위의 부존재확인을 구하는 것은 소의 이익이 있다(대법원 2007. 11. 16. 선고 2006다41297 판결).

(2) 확인의 이익과 확인청구의 상대방

확인 이익은 권리 또는 법률상의 지위에 현존하는 불안·위험이 있고 그 불안·위험을 제거함에는 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 수단일 때에 인정된다. 예컨대 법인의 임원선임결의의 무효 또는 부존재를 이유로 임원취임등기의 무효를 주장하는 사람은 그 등기의 원인이 되는 임원선임결의의 무효확인 또는 부존재확인의 소를 제기하여 판결이 확정되면 그 판결을 첨부하여 관할 등기소에 무효인 임원등기의 말소를 구할 수 있으므로, 이와 별도로 그 법인에 대하여 임원취임등기의 무효확인을 구하는 소는 임원취임에 관한 분쟁을 근본적으로 해결하는 가장 유효·적절한 수단이라고 볼 수 없어 확인의 이익이 없다(대법원 2006. 11. 9. 선고 2006다50949 판결). 또한 피고가 매년 구체적인 회비를 산정·고지하는 처분을 하기 전에 원고가 피고를 상대로 구체적으로 정해진 바도 없는 회비납부 의무의 부존재 확인을 곧바로 구하는 것은 현존하는 권리·법률관계의 확인이 아닌 장래의 권리·법률관계의 확인을 구하는 것이어서 허용되지 않는다(대법원 2021. 12. 30. 선고 2018다241458 판결). 반면 보험계약의 당사자 사이에 계약상 채무의 존부나 범위에 관하여 다툼이 있는 경우 그로 인한 법적 불안을 제거하기 위하여 보험회사는 먼저 보험수익자를 상대로 소극적 확인의 소를 제기할 확인의 이익이 있다고 할 것이다(대법원 2021. 6. 17. 선고 2018다257958 전원합의체 판결).

확인 소의 피고는 원고의 보호법익과 대립·저촉되는 이익을 주장하고 있는 자이어야 하고 그와 같은 피고를 상대로 하여야 확인의 이익이 있게 된다(대법원 1991. 12. 10. 선고 91다14420 판결). 따라서 권리관계에 대하여

당사자 사이에 아무런 다툼이 없어 법적 불안이 없으면 원칙적으로 확인의 이익이 없다. 그러나 피고가 권리관계를 다투어 원고가 확인의 소를 제기하였고 당해 소송에서 피고가 권리관계를 다투는 바 있다면 특별한 사정이 없는 한 항소심에 이르러 피고가 권리관계를 다투지 않는다는 사유만으로 확인의 이익이 없다고 할 수 없다(대법원 2009. 1. 15. 선고 2008다74130 판결). 마찬가지로 소제기 전에 피고가 권리관계를 다투는 바 있음을 들어 청구한 경우라면 당해 소송에서 권리관계를 다투지 않더라도 확인청구를 허용하여야 할 것이다.

또한 직접 분쟁의 당사자가 아닌 자에 대하여 확인을 구하는 것은 특별한 사정이 없는 한 그 확인을 받는다고 하여 법률상 지위의 불안 제거에 별다른 실효성이 있는 것은 아니므로 그 확인을 구할 법률상의 이익이 없어 부적법하다(대법원 1995. 10. 12. 선고 95다26131 판결). 예컨대 저당권의 실행으로 이미 소멸된 근저당권의 피담보채권이 존재하지 아니한다거나 이미 종료된 임의경매절차의 무효확인을 구하는 청구는 경매절차에서의 매수인이 아닌 당사자를 상대로 그와 같은 확인판결을 얻는다고 한들 그 확인판결의 효력이 매수인에게 미칠 수 없는 이상 원고의 권리 또는 법적 지위의 불안을 해소하는 유효·적절한 수단이라고 볼 수 없으므로 확인의 이익이 있다고 할 수 없다(대법원 1993. 6. 29. 선고 92다43821 판결). 가장 임차인에게 허위의 임차보증금에 대한 배당이 이루어진 배당표가 확정되었으나 배당금 지급 전에 그 사실을 알게 된 후순위 진정 채권자가 그 배당금지급청구권을 가압류한 경우에도, 후순위 진정 채권자로서는 곧바로 가장 임차인을 상대로 그가 부당이득한 배당금지급청구권의 반환을 구하는 것이 유효·적절한 구제방법이므로, 가장 임차인을 상대로 배당금지급청구권 부존재확인을 구하는 것은 확인의 이익이 없다(대법원 1996. 11. 22. 선고 96다34009 판결). 취득시효가 완성된 토지가 수용된 경우, 수용 당시 등기부상 소유명의자의 취득시효 완성을 원인으로 한 소유권이전등기 의무는 이행불능으로 되었으니, 시

효취득자는 이른바 대상청구권의 행사로서 수용 당시 등기부상 소유명의자에게 수용의 대가로 취득한 보상금청구권의 양도를 구할 수 있고 토지수용 당시 등기부상 소유명의자는 이에 응할 의무를 부담하고 있다 할 것인바, 이러한 지위에 놓여 있는 수용 당시 등기부상 소유명의자가 굳이 시효취득자를 상대로 보상금청구권이 자신에게 있다는 확인을 구하는 것은 무용, 무의미하다고 볼 수밖에 없어 확인판결을 받을 법률상 이익이 있다고 할 수 없다(대법원 1995. 8. 11. 선고 94다21559 판결). 나아가 단체의 임원 혹은 당선인 등의 지위의 적극적 확인을 구하는 단체 내부의 분쟁에 있어서 피고가 되는 자는 그 청구를 인용하는 판결이 선고될 경우 승소판결의 효력이 미치는 단체 자체라 할 것이므로, 달리 특별한 사정이 없는 한 해당 단체 아닌 자를 상대로 지위 확인을 구하는 것은 그 지위를 둘러싼 당사자들 사이의 분쟁을 근본적으로 해결하는 유효·적절한 방법이 될 수 없어 소의 이익을 인정하기 어렵다(대법원 2024. 1. 4. 선고 2023다244499 판결).

확인소의 소는 반드시 원·피고 간의 법률관계에 한하지 아니하고 원·피고의 일방과 제3자 또는 제3자 상호 간의 법률관계도 대상이 될 수 있으나, 그러한 법률관계의 확인은 법률관계에 따라 원고의 권리 또는 법적 지위에 현존하는 위험, 불안이 야기되어 이를 제거하기 위하여 법률관계를 확인의 대상으로 삼아 원·피고 간의 확인판결에 의하여 즉시 확정할 필요가 있고, 또한 그것이 가장 유효·적절한 수단이 되어야 확인의 이익이 있다(대법원 2016. 5. 12. 선고 2013다1570 판결). 자기의 권리 또는 법률상의 지위가 타인들 사이의 사해적 법률행위를 청구원인으로 한 사해소송의 결과로 인하여 침해받을 염려가 있는 경우에 그 타인들을 상대로 하여 사해소송의 청구원인이 된 법률행위가 무효라는 확인을 청구하는 것은, 사해판결이 선고·확정되고 집행됨으로써 자기의 권리 또는 법률상의 지위가 침해되는 것을 방지하기 위한 유효·적절한 수단이 되는 것이므로 확인의 이익이 있다(대법원 1990. 7. 13. 선고 89다카20719 판결). 또한 토지를 수용하는 사업시행자가

‘과실 없이 보상금을 받을 자를 알 수 없는 때’에 해당하여 절대적 불확지의 공탁을 한 경우, 수용 토지의 원소유자가 사업시행자를 상대로 하는 공탁금 출급청구권 확인의 소는 절대적 불확지공탁의 공탁금 출급을 둘러싼 법적 분쟁을 해결하는 유효·적절한 수단이어서 그 확인의 이익이 있다(대법원 1997. 10. 16. 선고 96다11747 전원합의체 판결). 반면 구 도시재개발법(2003. 7. 1. 도시 및 주거환경 정비법 부칙 제6852호 2조에 의하여 폐지되기 전의 것) 22조에 따라 설립된 재개발조합의 조합원은 조합의 운영에 이해관계를 가지고 있다고 하더라도 단순히 일반적인 것에 불과할 뿐 구체적인 법률상의 이해관계를 가진다고는 할 수 없으므로, 조합원이 직접 또는 재개발조합을 대위하여 법인인 재개발조합과 제3자와의 거래관계에 개입하여 조합의 대표기관이 체결한 계약의 무효를 주장할 수는 없을 뿐만 아니라, 조합원 개인의 자격으로 그 계약의 무효확인을 구하는 것이 분쟁을 해결하는 데에 반드시 유효·적절한 수단이라고 인정할 수도 없으므로, 확인의 이익이 인정되지 않는다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2005다9463 판결). 또한 경매절차에서 유치권이 주장되었으나 소유부동산 또는 담보목적물이 매각되어 그 소유권이 이전되어 소유권을 상실하거나 근저당권이 소멸하였다면, 소유자와 근저당권자는 유치권의 부존재 확인을 구할 법률상 이익이 없다. 나아가 경매절차에서 유치권이 주장되지 아니한 경우에는, 담보목적물이 매각되어 그 소유권이 이전됨으로써 근저당권이 소멸하였더라도 채권자는 유치권의 존재를 알지 못한 매수인으로부터 민법 575조, 578조 1항, 2항에 의한 담보책임 추급당할 우려가 있고, 위와 같은 위험은 채권자의 법률상 지위를 불안정하게 하는 것이므로, 채권자인 근저당권자로서는 위 불안을 제거하기 위하여 유치권 부존재 확인을 구할 법률상 이익이 있으나, 채무자가 아닌 소유자는 위 각 규정에 의한 담보책임을 부담하지 아니하므로, 유치권의 부존재 확인을 구할 법률상 이익이 없다(대법원 2020. 1. 16. 선고 2019다247385 판결).

(3) 과거의 법률관계에 대한 확인의 이익

(가) 확인의 이익이 인정되는 경우

과거의 법률관계의 존재확인 원칙적으로 허용되지 않는다. 그러나 과거의 법률관계라고 할지라도 현재의 권리 또는 법률상 지위에 영향을 미치고 있고 현재의 권리 또는 법률상 지위에 대한 위험이나 불안을 제거하기 위하여 그 법률관계에 관한 확인판결을 받는 것이 유효·적절한 수단이라고 인정될 때에는 그 법률관계의 확인소송은 즉시확정의 이익이 있다고 보아야 한다(대법원 1993. 7. 27. 선고 92다40587 판결). 예컨대 매매계약무효확인의 소는 단순히 과거의 법률행위인 매매계약무효확인을 구하는 것에 그치는 것이 아니라 현재 매매계약에 기한 채권채무가 존재하지 않는다는 확인을 구하는 취지로 해석되어 확인의 이익이 긍정된다(대법원 1966. 3. 15. 선고 66다17 판결 참조). 주식양도·양수계약의 부존재 또는 무효확인을 구하는 소도 마찬가지이다(대법원 1987. 7. 7. 선고 86다카2675 판결). 신분관계인 혼인관계는 그것을 전제로 하여 수많은 법률관계가 형성되고 그에 관하여 일일이 효력의 확인을 구하는 절차를 반복하는 것보다 과거의 법률관계인 혼인관계 자체의 무효 확인을 구하는 편이 관련된 분쟁을 한꺼번에 해결하는 유효·적절한 수단일 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 혼인관계가 이미 해소된 이후라고 하더라도 혼인무효의 확인을 구할 이익이 인정된다고 보아야 한다(대법원 2024. 5. 23. 선고 2020므15896 전원합의체 판결). 사실혼관계에 있었던 당사자 일방이 사망하였더라도, 현재적 또는 잠재적 법적 분쟁을 일거에 해결하는 유효·적절한 수단이 될 수 있는 한 그 사실혼관계존부확인청구에는 확인의 이익이 인정된다(대법원 1995. 3. 28. 선고 94므1447 판결, 대법원 2022. 3. 31. 선고 2019므10581 판결). 소속 회사의 취업규칙에 따라 갑이 징계처분으로 인하여 정직기간 동안 임금을 전혀 지급받지 못하는 법률상 불이익을 입게 된 경우 징계처분은 정직기간 동안의 임금 미지급 처분의 실질을 갖는 것이고, 이는 임금청구권의 존부에 관한 현재의 권리 또는 법률상 지위에 영향

을 미치고 있으므로, 비록 징계처분에서 정한 징계기간이 도과하였다 할지라도 징계처분의 무효 여부에 관한 확인 판결을 받음으로써 가장 유효·적절하게 자신의 현재의 권리 또는 법률상 지위에 대한 위협이나 불안을 제거할 수 있어 확인의 이익이 있다(대법원 2010. 10. 14. 선고 2010다36407 판결).

(나) 대학의 교수나 계약직 공무원의 임용기간 만료와 확인소송

교수가 임용기간 만료 전에 해임을 당한 후 임용기간의 만료로 당연히 교수의 신분을 상실하였더라도, 법령에 의하면 교수는 해임처분으로 말미암아 해임처분이 있는 날로부터 3년간 공직 또는 교원으로 임용될 수 없는 결격자로 취급되고, 그 결격기간이 경과한 뒤라도 징계해임을 당한 전력은 공직 또는 교원으로 임용되는 데에 있어서 그러한 전력이 없는 사람보다 불이익한 장애사유로 작용할 것은 의심의 여지가 없으므로 그로서는 공직이나 교원으로 임용될 수 있는 법률상 지위에 대한 위협이나 불안을 제거하기 위하여 해임처분의 무효확인을 구할 이익이 있다(대법원 1993. 7. 27. 선고 92다40587 판결).

이에 반하여 지방자치단체와 채용계약에 의하여 채용된 계약직공무원이 계약기간 만료 이전에 무효인 채용계약 해지로 인하여 불이익을 받은 후 그 계약기간이 만료된 때에는 당연히 공무원의 신분을 상실하고, 또 기간을 정하여 임용된 사립학교 교원이 임용기간 만료 이전에 무효인 직위해제·면직처분으로 불이익 처분을 받은 후 그 임용기간이 만료된 때에도 당연히 교원의 신분을 상실하므로, 그 채용계약 해지 또는 직위해제·면직처분에 대한 무효확인청구는 모두 과거의 법률관계의 확인청구에 지나지 않고, 이러한 채용계약 해지나 직위해제·면직처분으로 법률상의 이익이 침해되었다고 할 수 없는 이상, 무효확인소송은 적절한 권리구제수단이라 할 수 없어 확인의 이익이 없다(대법원 2000. 5. 18. 선고 95제다199 전원합의체 판결, 대법원 2002. 11. 26. 선고 2002두1496 판결).

다만 구 사립학교법(2008. 3. 14. 법률 제8888호로 개정되기 전의 것) 53조

의2 4항 내지 8항의 규정 내용에 비추어 볼 때, 기간제로 임용되어 임용기간이 만료된 사립대학 교원으로서의 능력과 자질에 관하여 합리적인 기준에 의한 공정한 심사를 받아 위 기준에 부합되면 특별한 사정이 없는 한 재임용되리라는 기대를 가지고 재임용 여부에 관하여 합리적인 기준에 의한 공정한 심사를 요구할 권리를 가진다고 할 것이므로, 임면권자가 임용기간이 만료된 사립대학 교원에 대하여 한 재임용을 거부하는 결정 및 통지는 그 대학교원의 권리관계에 영향을 주는 것으로서 임면권자와 사이에 재임용거부결정 및 통지의 효력 여부에 관하여 다툼이 있는 이상 그 대학교원은 그 거부결정 및 통지의 무효확인을 구할 소의 이익이 있다(대법원 2006.

3. 9. 선고 2003다52647 판결).

(4) 국가를 상대로 한 토지 및 건물의 소유권확인청구

국가를 상대로 한 토지소유권 확인청구는 어느 토지가 미등기이고, 토지대장이나 임야대장상에 등록명의자가 없거나 등록명의자가 누구인지 알 수 없을 때와 그 밖에 국가가 등록명의자인 제3자의 소유를 부인하면서 계속 국가 소유를 주장하는 등 특별한 사정이 있는 경우에 한하여 그 확인의 이익이 있다(대법원 2021. 7. 21. 선고 2020다300893 판결). 부동산등기법 65조에 비추어 볼 때 부동산에 관한 소유권보존등기를 하는 경우에 토지대장등본 또는 임야대장등본에 의하여 소유자임을 증명할 수 없다면 판결에 의하여 소유권을 증명하여 소유권보존등기를 할 수밖에 없고, 더욱이 대장소관청인 국가기관이 그 소유를 다투고 있다면 이와 같은 판결을 얻기 위한 소유권 확인소송은 국가를 상대로 제기할 수 있다(대법원 2001. 7. 10. 선고 99다34390 판결).

그러나 토지에 관하여 이미 제3자 명의로 소유권보존등기가 마쳐져 있고 토지대장이나 임야대장상으로도 그 제3자가 소유자로 기재되어 있는 경우에는 국가가 제3자의 소유를 부인하면서 계속 국가 소유를 주장하는 등 특별한 사정이 없는 한 국가를 상대로 하여 그 토지에 관한 소유권확인의 판결

을 받더라도 이를 근거로 하여 소유권보존등기를 할 수 없을 뿐만 아니라, 이러한 경우에는 위 등기명의자를 상대로 하여 자신이 소유자임을 확정하는 내용의 보존등기말소 내지 소유권확인 판결을 받기만 하면 그 판결에 의하여 소유권보존등기를 마칠 수 있으므로 소유권보존등기를 하기 위한 목적으로 별도로 국가를 상대로 소유권확인을 구할 이익은 없다(대법원 1993. 9. 14. 선고 92다24899 판결). 또한 미등기토지에 대하여 토지대장이나 임야대장의 소유자 명의인 표시란에 구체적 주소나 인적사항에 관한 기재가 없어서 그 명의인을 특정할 수 없는 경우에는 그 소유명의인의 채권자가 국가를 상대로 소유명의인을 대위하여 소유권확인의 확정판결을 받더라도 이 확인 판결에는 소유자가 특정되지 않아 특정인이 위 토지의 소유자임을 증명하는 확정판결이라고 볼 수 없어 그에 따른 소유권보존등기를 마칠 수 없으므로, 결국 국가를 상대로 한 소는 소유권확인을 구할 법률상 이익이 없는 경우에 해당한다(대법원 2021. 7. 21. 선고 2020다300893 판결. 반면 토지대장 등에 소유자 명의인의 주소와 주민등록번호 등이 기재되지는 않았지만 국가가 특정된 소유자 명의인 및 그 상속인들을 인정하는 경우에는 소유권확인을 구할 이익이 인정될 수 있다. 대법원 2019. 5. 16. 선고 2018다242246 판결). 문제 된 토지에 관하여 국가가 시효취득하였다고 주장하는 경우에 이는 취득시효 완성을 원인으로 한 소유권이전등기청구권이 있다는 주장에 불과한 것이지 위 토지에 관한 임야대장상 등록명의자의 소유를 부인하면서 국가의 소유라 주장하는 것이라 볼 수 없으므로 별도로 국가를 상대로 소유권확인을 구할 이익이 있다고 할 수 없다(대법원 2003. 12. 12. 선고 2002다33601 판결).

한편 건물의 경우 가옥대장이나 건축물관리대장의 비치·관리업무는 당해 지방자치단체의 고유사무로서 국가사무라고 할 수도 없는 데다가 당해 건물의 소유권에 관하여 국가가 이를 특별히 다루고 있지도 아니하다면, 국가는 그 소유권 귀속에 관한 직접 분쟁의 당사자가 아니어서 이를 확인해 주어야 할 지위에 있지 않으므로, 국가를 상대로 미등기 건물의 소유권 확인을 구하

는 것은 그 확인의 이익이 없어 부적법하다(대법원 1999. 5. 28. 선고 99다 2188 판결). 또한 건축물대장이 생성되지 않은 건물에 대해서는 소유권확인 판결을 받는다고 하더라도 그 판결은 부동산등기법 65조 2호에 해당하는 판결이라고 볼 수 없어 이를 근거로 건물의 소유권보존등기를 신청할 수 없으므로, 이러한 건물에 대하여 소유권보존등기를 마칠 목적으로 제기한 소유권확인청구의 소는 당사자의 법률상 지위의 불안 제거에 별다른 실효성이 없는 것으로서 확인의 이익이 없어 부적법하다(대법원 2011. 11. 10. 선고 2009다93428 판결).

(5) 확인의 소의 보충성 및 수단의 유효·적절성

이행의 소를 제기할 수 있는데도 그 이행청구권 자체의 존재확인을 구하는 것은 불안제거에 실효성이 없고 소송경제에 비추어도 유효·적절한 수단이라 할 수 없으므로 확인의 이익이 없어서 허용되지 아니한다(대법원 1991. 7. 23. 선고 91다6757 판결). 다만 금전지급청구권이 존재함은 확인되지만 금액이 확정되지 않은 경우에는 청구권 존재 확인의 이익이 인정된다(대법원 1969. 3. 25. 선고 66다1298 판결).

한편 소극적 확인의 소에 관하여는 판례가 소의 이익을 부정하는 경우가 많다. 소유권 등 권리가 원고에게 귀속되지 않는다는 점에 관하여 다툼이 있는 경우 특별한 사정이 없는 한 그 소유권 등의 권리자를 상대로 그 권리 귀속에 관한 적극적 확인을 구하여야 하고, 소유권 등 권리가 원고에게 귀속되지 않는다는 내용의 소극적 확인을 구하는 것은 근본적인 분쟁의 해결 방법이라고 볼 수 없어 확인의 이익이 없다(대법원 2003. 7. 25. 선고 2002다3860 판결). 반면 앞서 본 바와 같이 보험회사는 먼저 보험수익자를 상대로 보험계약상 채무의 존부나 범위에 관한 소극적 확인의 소를 제기할 확인의 이익이 있고(대법원 2021. 6. 17. 선고 2018다257958 전원합의체 판결), 실질적으로 보증의 성격을 가진 보증보험계약에서 보험금이 아직 지급되지 않은 상태에서 주계약의 당사자인 보험계약자와 피보험자 사이에 주계약에 따른 채무의

존부와 범위에 관하여 다툼이 있는 경우, 주계약의 채무자이기도 한 보험계약자로서는 우선 그 계약상 채권자인 피보험자를 상대로 주계약에 따른 채무 부존재 확인을 구하는 것이 분쟁을 해결하는 가장 유효적절한 방법일 수 있다(대법원 2022. 12. 15. 선고 2019다269156 판결).

근저당권설정자가 근저당권설정계약에 기한 피담보채무가 존재하지 아니함의 확인을 구함과 함께 그 근저당권설정등기의 말소를 구하는 경우에 근저당권설정자로서는 피담보채무가 존재하지 않음을 이유로 근저당권설정등기의 말소를 구하는 것이 분쟁을 유효·적절하게 해결하는 직접적인 수단일 될 것이므로 별도로 근저당권설정계약에 기한 피담보채무가 존재하지 아니함의 확인을 구하는 것은 확인의 이익이 있다고 할 수 없다(대법원 2000. 4. 11. 선고 2000다5640 판결). 또한 채무인수자를 상대로 한 채무이행청구 소송의 계속 중, 채무인수자가 별도로 그 채무의 부존재확인을 구하는 것은 소의 이익이 없다(대법원 2001. 7. 24. 선고 2001다22246 판결). 그러나 소송요건을 구비하여 적법하게 제기된 본소가 그 후에 상대방이 제기한 반소로 인하여 소송요건에 흠이 생겨 다시 부적법하게 되는 것은 아니므로, 원고가 피고에 대하여 손해배상채무의 부존재확인을 구할 이익이 있어 본소로 그 확인을 구하였다면, 피고가 그 후에 그 손해배상채무의 이행을 구하는 반소를 제기하였다 하더라도 그러한 사정만으로 본소청구에 대한 확인의 이익이 소멸하여 본소가 부적법하게 된다고 볼 수는 없다(대법원 1999. 6. 8. 선고 99다17401 판결). 한편 청구이의의 소는 집행권원이 가지는 집행력의 배제를 목적으로 하는 것으로서 판결이 확정되더라도 당해 집행권원의 원인이 된 실체법상 권리관계에 기판력이 미치지 않으므로, 채무자가 채권자에 대하여 채무부담행위를 하고 그에 관하여 강제집행승낙문구가 기재된 공정증서를 작성하여 준 후 공정증서에 대한 청구이의의 소를 제기하지 않고 공정증서의 작성원인이 된 채무에 관하여 채무부존재확인 소를 제기한 경우, 그 목적이 오로지 공정증서의 집행력 배제에 있는 것이 아닌 이상 청구이의의 소

를 제기할 수 있다는 사정만으로 채무부존재확인소송이 확인의 이익이 없어 부적법하다고 할 것은 아니다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2012다108863 판결).

합명회사나 합자회사의 사원총회결의는 회사의 의사결정으로서 그로 인한 법률관계의 주체는 회사이므로 회사를 상대로 하여 사원총회결의의 존부나 효력 유무의 확인판결을 받음으로써만 그 결의로 인한 원고의 권리 또는 법률상 지위에 대한 위협이나 불안을 유효·적절하게 제거할 수 있는 것이고 회사가 아닌 사원 개인을 상대로 한 무효확인판결은 회사에 그 효력이 미치지 아니하므로 즉시확정의 이익이 없어 그러한 확인판결을 구하는 소송은 부적법하다(대법원 1991. 6. 25. 선고 90다14058 판결). 노동조합과 같은 단체의 임원선거에 따른 당선자 결정의 무효 여부에 대한 확인을 구하는 소에서 당선자를 결정한 그 조합을 상대로 하지 아니하고 당선자를 상대로 한 조합장 당선무효확인 소도 마찬가지로 이유로 확인의 이익이 없어 부적법하다(대법원 1992. 5. 12. 선고 91다37683 판결).

토지소유자가 일반 공중의 통행에 무상으로 제공하여 토지를 내왕하는 사람들에 대하여 배타적 사용·수익권을 주장하며 통행을 방해하는 등의 행위를 할 수 없다고 하더라도, 이러한 권리행사 제약이나 그에 따른 법률상 지위는 채권적인 것에 불과하여 구체적 상황과 맥락에 따라 소유자가 수인하여야 하는 권리행사상 제약의 내용이나 범위가 달라질 수밖에 없으므로, 일반적으로 토지소유자에 대하여 ‘배타적 사용·수익권이 존재하지 않는다.’는 취지의 확인을 구하는 것은 특별한 사정이 없는 한 당사자 또는 제3자 사이의 권리관계 불안이나 위협을 제거할 수 있는 유효·적절한 수단이 된다고 볼 수 없어 확인을 구할 이익이 없다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2010다81049 판결).

(6) 증서의 진정 여부를 확인하는 소에 관한 소의 이익

증서진부확인의 소는 서면이 그 작성명의자에 의하여 작성되었는가 그렇지 않으면 위조 또는 변조되었는가를 확정하는 소송으로서, 서면의 진부라

고 하는 사실의 확정에 대하여 독립의 소가 허용된다(민소 250조). 이는 법률관계를 증명하는 서면의 진부가 판결로 확정되면 당사자 간에서 그 문서의 진부가 다투어지지 않는 결과 그 문서가 증명하는 법률관계에 관한 분쟁 자체도 해결될 가능성이 있거나 적어도 그 분쟁의 해결에 기여함이 크다는 이유에 의한 것이다.

따라서 증서진부확인 소가 적법하기 위해서는 그 서면에 대한 진정 여부의 확인을 구할 이익이 있어야 하므로, 소로써 확인을 구하는 서면의 진부가 확정되어도 서면이 증명하려는 권리관계 내지 법률적 지위의 불안이 제거될 수 없고, 그 법적 불안을 제거하기 위하여서는 당해 권리 또는 법률관계 자체의 확인을 구하여야 할 필요가 있는 경우에는 즉시확정의 이익이 없고(대법원 1991. 12. 10. 선고 91다15317 판결), 어느 서면에 의하여 증명되어야 할 법률관계를 둘러싸고 이미 소가 제기되어 있는 경우에는 그 소송에서 분쟁을 해결하면 되므로 그와 별도로 그 서면에 대한 진정 여부를 확인하는 소를 제기하는 것은 특별한 사정이 없는 한 확인의 이익이 없다(대법원 2007. 6. 14. 선고 2005다29290 판결).

또한 증서진부확인 소의 대상이 되는 서면은 직접 법률관계를 증명하는 서면에 한하고, '법률관계를 증명하는 서면'은 그 기재 내용으로부터 직접 일정한 현재의 법률관계의 존재 여부가 증명될 수 있는 문서를 가리키므로(대법원 2007. 6. 14. 선고 2005다29290 판결) 단지 과거의 사실관계를 증명하는 서면은 여기에 해당하지 아니한다. 예컨대 조합의 대차대조표나 회계결산보고서는 조합의 일정한 시기의 영업재산상태를 밝힌 장부이거나 그 조합의 영업재산의 손익관계를 밝힌 보고문서로서 증서진부확인 소의 대상이 될 수 없고(대법원 1967. 3. 21. 선고 66다2154 판결), 부가가치세법상의 세금계산서도 재화 또는 용역을 공급한 과거의 사실을 증명하기 위하여 작성되는 보고 문서에 불과하여 증서진부확인 소의 대상이 되지 아니한다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001다53714 판결). 또한 임대차계약금으로 일정한 금원을 받았

음을 증명하기 위하여 작성된 영수증은 특별한 사정이 없는 한 임대차 등 법률관계의 성립 내지 존부를 직접 증명하는 서면이 아니므로 증서진부확인인의 소의 대상이 될 수 없다(대법원 2007. 6. 14. 선고 2005다29290 판결).

라. 이행의 소에 관한 소의 이익

(1) 집행이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우

이행의 소는 원칙적으로 원고가 이행청구권의 존재를 주장하는 것으로서 권리보호의 이익이 인정되고, 이행판결을 받아도 집행이 사실상 불가능하거나 현저히 곤란하다는 사정만으로 그 이익이 부정되는 것은 아니다(대법원 2016. 8. 30. 선고 2015다255265 판결).

순차로 마쳐진 소유권이전등기의 각 말소청구 소송은 통상 공동소송이므로 그중의 어느 한 등기명의자만을 상대로 말소를 구할 수 있고, 최종 등기명의자에 대하여 등기말소를 구할 수 있는지에 관계없이 중간의 등기명의자에 대하여 등기말소를 구할 소의 이익이 있다(대법원 1998. 9. 22. 선고 98다23393 판결, 대법원 2017. 9. 12. 선고 2015다242849 판결). 또한 일반적으로 채권에 대한 가압류가 있더라도 이는 채무자가 제3채무자로부터 현실로 급부를 추심하는 것만을 금지하는 것일 뿐 채무자는 제3채무자를 상대로 그 이행을 구하는 소송을 제기할 수 있고 법원은 가압류가 되어 있음을 이유로 이를 배척할 수는 없다(대법원 2002. 4. 26. 선고 2001다59033 판결).

한편 소유권이전등기청구권에 대한 압류나 가압류는 채권에 대한 것이지 등기청구권의 목적물인 부동산에 대한 것이 아니므로 청구권의 목적물인 부동산 자체의 처분을 금지하는 대물적 효력은 없고, 또한 채권에 대한 가압류가 있더라도 채무자는 제3채무자를 상대로 그 이행을 구하는 소송을 제기할 수 있고 법원은 가압류가 되어 있음을 이유로 이를 배척할 수는 없는 것이지만, 소유권이전등기를 명하는 판결은 의사의 진술을 명하는 판결로서 이것이 확정되면 채무자는 일방적으로 이전등기를 신청할 수 있고 제3채무자

는 이를 저지할 방법이 없게 되므로, 이와 같은 경우에는 가압류의 해제를 조건으로 하지 않는 한 법원은 이를 인용하여서는 안 되는 것이며, 가처분이 있는 경우도 이와 마찬가지로 그 가처분의 해제를 조건으로 하여야만 소유권이전등기절차의 이행을 명할 수 있다(대법원 1999. 2. 9. 선고 98다42615 판결. 체비지대장상 소유자명의변경절차의 이행도 마찬가지이다. 대법원 2011. 8. 18. 선고 2009다60077 판결).

(2) 아무런 실익이 없는 청구

매매목적물인 건물이 전부 멸실된 경우에는 매수인은 비록 가등기 가처분에 의하여 위 건물에 대하여 가등기를 하고 등기기록에 그대로 등재되어 있다고 하여도 이에 대한 가등기는 효력이 없어지는 것이므로, 특별한 사정이 없는 한 이에 대한 소유권이전등기나 소유권확인을 구할 수 없다(대법원 1976. 9. 14. 선고 75다399 판결). 또한 건물이 멸실된 경우에 멸실된 건물에 대한 등기기록은 폐쇄될 운명에 있으므로, 그 건물에 관하여 마쳐진 소유권이전등기가 원인무효로 될 사정이 있다 하여도 그 건물의 종전의 소유자로서는 등기기록상의 소유명의자에게 그 말소등기를 소구할 이익이 없다(대법원 1994. 6. 10. 선고 93다24810 판결). 마찬가지로 저장권설정등기가 소송계속 중 저장권 실행에 의한 매각으로 말소된 때에는 그 등기말소를 구하는 소송은 법률상 이익이 없고(대법원 2003. 1. 10. 선고 2002다57904 판결), 소유권이전등기의 말소등기절차의 이행을 구하는 소송 도중에 그 소유권이전등기가 다른 사유에 기하여 이미 말소된 경우에도 더 이상 말소를 구할 법률상 이익이 없으므로 소를 각하하여야 한다(대법원 2005. 9. 28. 선고 2004다50044 판결).

(3) 장래이행을 구하는 소의 이익

(가) 미리 청구할 필요

장래이행의 소, 즉 변론 종결 시를 기준으로 하여 이행기가 장래에 도래하는 이행청구의 소는 ‘미리 청구할 필요’가 있는 경우에 한하여 허용된다

(민소 251조). 판례는 일반적으로 채무자가 채무의 이행기 도래 전부터 채무의 존재나 범위를 다투기 때문에 이행기가 도래하거나 조건이 성취되었을 때에 임의의 이행을 기대할 수 없는 경우에는 장래이행의 소로써 미리 청구할 필요가 인정된다고 한다(대법원 1993. 11. 9. 선고 92다43128 판결). 장래의 이행을 명하는 판결을 하기 위해서는 채무의 이행기가 장래에 도래할 뿐만 아니라 의무불이행 사유가 그때까지 계속하여 존속한다는 것을 변론종결 당시에 확정적으로 예정할 수 있어야 하고, 이러한 책임 기간이 불확실하여 변론종결 당시에 확정적으로 예정할 수 없는 경우에는 장래의 이행을 명하는 판결을 할 수 없다(대법원 2023. 7. 27. 선고 2020다277023 판결). 또한 장래이행의 소는 통상적인 이행의 소의 예외에 해당하는 것일 뿐 채무자의 무자력에 따른 강제집행의 곤란에 대비하기 위해 마련된 것이 아니고, 쌍무계약관계의 이행기가 도래하지 않은 상태임에도 당사자 일방에 대하여 선제적으로 집행권원을 확보할 수 있게 하는 것은 자칫 계약관계의 균형이 상실되어 상대방 당사자의 계약상 권리가 침해될 수 있을 뿐만 아니라 장래의 이행기에 이르기까지 발생할 수 있는 계약상 다양한 변화를 반영하지 못함으로써 이행기 당시 쌍방 당사자의 권리의무관계와 집행권원이 모순·충돌되는 불합리한 결과를 초래할 수 있으므로, 장래이행의 소의 적법 여부는 엄격한 기준에 따라 신중하게 판단하여야 한다(대법원 2023. 3. 13. 선고 2022다286786 판결).

선이행 조건부 청구도 장래이행 청구의 일종이므로 먼저 자기 의무를 이행하여도 상대방의 채무이행을 기대할 수 없는 사정 등의 ‘미리 청구할 필요’가 있어야 허용된다. 예컨대 피고 명의의 소유권이전등기가 채무담보를 위하여 마쳐진 것인데도 피고가 이를 다투고 있는 경우에는 피고로 하여금 원고로부터 피담보채권을 변제받는 것을 조건으로 위 등기를 말소하도록 명할 수 있다(대법원 1996. 11. 12. 선고 96다33938 판결). 원고가 피담보채무의 완제에 의한 소멸을 주장하면서 무조건의 등기말소청구를 하였는데 심리결

과 저당채무나 양도담보채무가 아직 일부 남아 있는 것이 판명된 경우, 판례는 설사 원고가 그 채무를 변제한다고 하더라도 피고가 수액 등을 다투면서 말소등기절차에 협력하지 않을 사정이 있을 때에는 미리 청구할 필요가 인정되므로, 원고의 반대의사표시가 없는 한 원고의 청구를 전부 기각할 것이 아니라 원고의 나머지 채무의 지급을 조건으로 한 선이행판결을 하여야 한다고 한다(대법원 1981. 9. 22. 선고 80다2270 판결, 대법원 1996. 2. 23. 선고 95다9310 판결).

그 밖에 '미리 청구할 필요성'과 관련하여, 공유물분할청구 소송이 확정되기 전에 공유물이 분할될 것을 전제로 미리 자기에게 분할될 부분에 대한 소유권이전등기청구나 소유권확인청구는 허용되지 아니하며(대법원 1969. 12. 29. 선고 68다2425 판결), 또한 지명채권 양도의 대항요건을 갖추지 못한 채권양수인은 아직 채무자와의 사이에 아무런 법률관계가 없으므로, 채무자를 상대로 “채권양도인으로부터 양도 통지를 받은 다음에 채무를 이행하라.”라는 청구는 장래이행의 소로서의 요건을 갖추지 못하여 부적법하다(대법원 1992. 8. 18. 선고 90다9452 판결).

(나) 정기금판결에 대한 변경의 소

2002년 개정전 민사소송법하에서 판례는 장래이행의 판결을 하였다고 하더라도 그 변론종결 후에 손해 산정의 기초가 된 사정이 현저하게 달라져 형평에 반하는 경우 그 차액에 대하여는 다시 소를 제기할 수 있다고 판시하였는데(대법원 1993. 12. 21. 선고 92다46226 전원합의체 판결, 대법원 1999. 3. 9. 선고 97다58194 판결), 2002년 개정 민사소송법은 정기금의 지급을 명한 판결이 확정된 뒤에 그 액수산정의 기초가 된 사정이 현저하게 바뀔으로써 당사자 사이의 형평을 크게 침해할 특별한 사정이 생긴 때에는 그 판결의 당사자는 장차 지급할 정기금 액수를 바꾸어 달라는 소를 제기할 수 있도록 정기금판결 변경의 소를 신설하였다(민소 252조).

정기금판결에 대한 변경의 소는 제1심판결 법원의 전속관할에 속한다(민

소 252조 2항). 이는 정기금판결의 확정 뒤에 발생한 현저한 사정변경을 이유로 확정된 정기금판결의 기판력을 예외적으로 배제하는 것을 목적으로 하므로, 확정된 정기금판결의 당사자 또는 민사소송법 218조 1항에 의하여 확정판결의 기판력이 미치는 제3자만 정기금판결에 대한 변경의 소를 제기할 수 있다(대법원 2016. 6. 28. 선고 2014다31721 판결).

정기금판결에 대한 변경의 소에서 단순히 종전 확정판결의 결론이 위법·부당하다는 등의 사정을 이유로 정기금의 액수를 바꾸어 달라고 하는 것은 허용될 수 없다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2015다243996 판결). 또한 전소의 변론종결일 후 후소의 원심변론종결 당시까지 점유토지의 공시지가가 2.2배 상승하고 ㎡당 연임료가 약 2.9배 상승한 것만으로는, 전소의 확정판결 후에 그 액수 산정의 기초가 된 사정이 현저하게 바뀔으로써 당사자 사이의 형평을 크게 침해할 특별한 사정이 생겼다고 할 수 없으므로, 그 정기금의 증액 지급을 구할 수 없다(대법원 2009. 12. 24. 선고 2009다64215 판결).

마. 형성의 소에 관한 소의 이익

기존 법률관계의 변동 형성의 효과를 발생함을 목적으로 하는 형성의 소는 법률에 명문의 규정이 있는 경우에 한하여 인정되는 것이고 법률상의 근거가 없는 경우에는 허용될 수 없다.

따라서 화해조항의 실현을 위하여 부동산을 경매에 부쳐 그 경매대금에서 경매비용 등을 공제한 나머지 대금을 원고들 및 피고들에게 배당할 것을 구하는 소(대법원 1993. 9. 14. 선고 92다35462 판결), 학교법인 이사장에 대하여 불법행위를 이유로 그 해임을 청구하는 소(대법원 1997. 10. 27. 자 97마 2269 결정), 조합의 이사장 및 이사가 조합업무에 관하여 위법행위 및 정관 위반행위 등을 하였다는 이유로 그 해임을 청구하면서 조합의 이사장 및 이사 직무집행정지 가처분을 구하는 것(대법원 2001. 1. 16. 선고 2000다45020 판결)은 모두 이를 허용하는 법률상 근거가 없어서 부적법하다.

5. 소송중의 소 등 특수한 소송에 관한 사항

소의 병합, 소의 변경, 반소 등 병합의 소 또는 중간확인 의 소 등 소송중 의 소 그리고 공동소송, 예비적·선택적 공동소송, 당사자참가, 필수적 공동 소송인의 추가에서는 각각 그 필요요건을 구비하여야 한다.

또한 사해행위취소나 상속회복 청구 등 제소기간이 정하여져 있는 경우에는 제소기간을 준수하여야 한다.

한편 희생관리인이나 파산관재인이 소를 제기하거나 소송중의 소를 추가 하는 경우, 그 소송행위가 무효로 되지 않으려면 도산법원으로부터 허가를 받아야 한다(채무자회생 61조, 492조).

6. 심사 결과에 대한 조치

가. 보정 또는 소각하판결 및 과태료 결정

재판장은 소송요건에 대한 심사 후 소송요건에 흠이 있다고 판단되면 지휘권(민소 135조)이나 석명권(136조)을 이용하여 당사자에게 그 흠을 보정하도록 명할 수 있다. 그럼에도 당사자가 응하지 아니하거나 처음부터 보정할 수 없는 것으로 판명된 때에는 소각하의 판결을 하게 된다. 특히 보정이 불가능한 때에는 변론을 거치지 않고도 소각하판결을 할 수 있다(219조). 법원의 관할은 소송요건이기는 하나 관할위반은 소각하판결을 할 사유가 아니며 결정으로 관할법원에 이송하여야 한다(34조 1항).

한편 원고가 소권을 남용하여 청구가 이유 없음이 명백한 소를 반복적으로 제기한 경우에도, 법원은 변론 없이 소각하판결을 할 수 있고, 이때 재판장은 직권으로 피고에 대하여 공시송달을 명할 수 있다(민소 194조 4항). 예컨대 최종심인 대법원에서 수회에 걸쳐 같은 이유를 들어 재심 청구를 기각하였음에도 다시 같은 이유를 들어 최종 재심판결에 대해 재심을 청구하는 것은 상대방을 괴롭히는 결과가 되고 사법인력의 불필요한 소모와 사법기능의 혼란과 마비를 조성하는 것으로 소권의 남용에 해당한다(대법원 1999. 5.

28. 선고 98재다275 판결). 또한 위와 같은 경우 법원은 원고에 대하여 결정으로 500만 원 이하의 과태료에 처할 수 있다(219조의2).

나. 소송요건의 존부 판단 기준

소송요건의 존부를 판정하는 시기는 원칙적으로 사실심의 변론종결 당시이다(대법원 1977. 5. 24. 선고 76다2304 전원합의체 판결). 따라서 소제기 당시에는 소송요건이 결여되어도 사실심의 변론 종결 시까지 이를 구비하면 된다(대법원 2021. 6. 24. 선고 2019다278433 판결). 또한 상법 403조 1항, 2항, 3항에서 규정하는 주주의 대표소송이 제소요건을 갖추지 못한 채 소가 제기되었다고 하더라도, 주주로부터 소의 제기를 청구받은 회사가 이사의 책임을 추궁할 소를 제기하지 않을 의사를 명시적으로 밝히는 등 주주의 제소청구에 응하지 않으리라는 특별한 사정이 인정된다면, 이러한 경우까지 그 주주대표소송이 부적법하다고 보는 것은 소송경제에 반하므로 그 하자가 치유된다고 봄이 타당하다(대법원 2025. 6. 12. 선고 2024다216743 판결). 다만 이미 사망한 자를 상대로 한 소의 제기(소제기 후 소장부분이 송달되기 전 피고가 사망한 경우 포함)는 소송요건을 갖추지 않은 것으로서 부적법하고, 이를 간과한 채 제1심판결이 선고되었다 하더라도 당연히 무효이며, 그 판결에 대한 사망자인 피고의 상속인들에 의한 항소나 소송수계신청도 부적법하고, 항소심에 이르러 원고가 당사자표시정정의 방법으로 그 흠결을 보정할 수 없다(대법원 2015. 1. 29. 선고 2014다34041 판결, 대법원 2015. 7. 23. 선고 2015다8360 판결).

소제기 당시에는 소송요건이 구비되어 있었어도 그 뒤에 소멸되면 본안판결을 할 수 없음이 원칙이다. 특히 확인의 이익 등의 소송요건은 직권조사가 항으로서 당사자가 주장하지 않더라도 법원이 직권으로 조사하여 판단하여야 하고, 법률심인 상고심 계속 중에 소의 이익이 없게 된 경우에도 부적법하게 된다(대법원 2003. 1. 10. 선고 2002다57904 판결, 대법원 2020. 1. 16.

선고 2019다247385 판결).

다. 항변사항과 직권조사사항

소송요건에는 항변사항과 직권조사사항이 있다. 전자는 소송요건 가운데 그 존재를 피고가 주장하지 않는 한 문제로 삼지 않는 사항이고, 후자는 법원이 직권으로 조사하여 참작하지 아니하면 안 되는 사항이다. 실무상 본안 전항변이란 소송요건의 흠을 내세우는 피고의 주장 일체를 가리키므로, 여기에는 위 항변사항에 관한 순수한 의미의 항변 이외에도 직권조사사항에 관하여 법원의 직권발동을 촉구하는 의미의 주장까지 모두 포함된다.

항변사항에 해당하는 사유로는 ① 임의관할(민소 30조, 411조) 위반, ② 소송비용의 담보제공 불이행(117조, 119조), ③ 중재합의(중재법 9조) 등이 있으며, 주로 당사자의 이익 보호를 주된 목적으로 하여 소송요건으로 인정된 것이므로 소송절차에 관한 이익권 포기·상실의 대상이 된다. 위 ①, ②, ③의 세 가지 사유는 본안에 관한 최초의 변론(준비)기일에서 진술하기 전까지 이를 주장하지 아니하면 이익권이 상실된다.

반면 위 항변사항들을 제외한 나머지 소송요건의 대부분은 직권조사사항으로서 법원이 당사자의 주장에 구속될 필요 없이 직권으로 조사하여야 하며, 소송절차에 관한 이익권 포기나 자백의 대상이 되지 않는다. 따라서 직권조사사항에 관한 상대방의 항변은 직권발동을 촉구하는 의미에 그친다. 또한 피고가 답변서를 제출하지 않았어도 직권조사사항이 있으면 무변론판결을 할 수 없고, 시기에 늦게 그 흠을 다투는 항변을 제출하여도 실기한 공격·방어방법이라는 이유로 각하할 수 없다.

법원은 직권조사사항인 소송요건에 대하여 상대방이 그 존재를 다투지 않거나 제출된 자료로 보아 그 존재에 의문이 없는 한 이를 석명하거나 심리 판단할 필요는 없다(대법원 1996. 3. 12. 선고 94다56999 판결). 다만 법원이 그 판단의 기초자료가 되는 사실과 증거를 직권으로 탐지할 의무까지는 없

다 하더라도 이미 제출된 자료들에 의하여 그 소송요건의 존재에 의심이 갈 만한 사정이 엿보인다면 상대방이 이를 구체적으로 지적하여 다투지 않아도 이에 관하여 심리·조사할 의무가 있다(대법원 1991. 10. 11. 선고 91다21039 판결). 그리고 부제소합의가 있는 경우에는 당사자들이 그러한 합의의 효력이나 그 범위에 관하여 쟁점으로 삼아 소의 적법 여부를 다투지 아니하는데도 법원이 직권으로 그러한 합의가 있음을 이유로 소가 부적법하다고 판단하기 위해서는 그와 같은 법률적 관점에 대하여 당사자에게 의견을 진술할 기회를 주어야 한다(민소 136조 4항, 대법원 2013. 11. 28. 선고 2011다80449 판결). 그 밖에 당사자적격이나 소의 이익과 같은 것도 직권조사사항이지만 그 판단의 기초가 되는 사실은 당사자의 변론에 나타난 것에 한하여 참작하면 된다.

직권조사사항에 관하여도 그 사실의 존부가 불명한 경우에는 증명책임의 원칙이 적용되어야 할 것인데, 본안판결을 받는다는 것 자체가 원고에게 유리하다는 점에 비추어 직권조사사항인 소송요건에 대한 증명책임은 원고에게 있다(대법원 1997. 7. 25. 선고 96다39301 판결). 다만 부제소합이나 소취하합의가 있는 경우(권리보호이익의 흠결)와 같이 소극적 소송요건이 문제 되는 경우에는 성질상 피고가 그 사유의 존재에 대한 증명책임을 부담한다고 보아야 할 경우도 있을 것이다.